Signature Not Verified
Assinado por ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS:76154238720 em 15/03/2013 08:55:26.691 -0300

Governo do Estado do Espírito Santo
Procuradoria Geral do Estado

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

JOSÉ RENATO CASAGRANDE, Governador do Estado do Espírito Santo, legitimado pelo inciso V do artigo 103 da Constituição da República e das alíneas "a" e "p" do inciso I do seu artigo 102, assistido pela Procuradora Geral do Estado, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, propor a esse Excelso Pretório a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

com as seguintes finalidades: **(i)** obter do Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade e a suspensão da execução do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734, publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2012, e republicada em 15 de março de 2013[1], como decorrência da rejeição, pelo Congresso Nacional, do Veto Presidencial que lhe foi aposto, que concebem nova disciplina jurídica para distribuição dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás a Estados e Municípios; e **(ii)** obter desse Tribunal Constitucional a atribuição à Lei nº 12.351/2010 de interpretação conforme a Constituição, para estabelecer que enquanto não for editada norma válida disciplinando a distribuição a Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha os critérios de distribuição estabelecidos pelas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997; pretensão que se embasa nas razões de fato e de direito que passam a ser explicitadas:

[1] Vide cópia anexada do Diário Oficial da União de 15 de março de 2013.

1. Fatos.

A redação conferida pela Lei nº 12.734/2012 aos dispositivos legais cuja constitucionalidade é questionada nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, inseridos na Lei nº 12.351/2010 (que disciplina a exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção) e na Lei nº 9.478/1997 (que disciplina a exploração de petróleo e gás sob o regime de concessão), inauguram uma nova disciplina jurídica para a distribuição aos Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais pagas ao poder público como decorrência do exercício dessa atividade econômica.

Eis o teor dos preceptivos impugnados:

Lei 12.351

Art. 42-B Os *royalties* devidos em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção serão distribuídos da seguinte forma:

I – Quando a produção ocorrer em terra, rios, lagos, ilhas lacustres ou fluviais:

a) Vinte por cento para os Estados ou o Distrito Federal, se for o caso, produtores;

b) Dez por cento para os Municípios produtores;

c) Cinco por cento para os Municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto fluido, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

d) Vinte e cinco por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" deste inciso, na alínea "a" do inciso II deste artigo, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no inciso II do § 2º do art. 50 da Lei no. 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. O Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

e) Vinte e cinco por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II deste artigo, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no inciso III do § 2º do art. 50 da Lei no. 9.478, de 6 de agosto de 1997;

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá as mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. O Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

f) Três por cento para o Ministério da Defesa, para atender aos encargos decorrentes do emprego dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na fiscalização e proteção das áreas de produção e distribuição;

g) Doze por cento para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

II – Quando a produção ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva:

a) Vinte e dois por cento para os Estados ou o Distrito Federal, se for o caso, produtores;

b) Cinco por cento para os Municípios produtores;

c) Dois por cento para os Municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto fluido, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

d) Vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento (25,5%) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" do inciso I e deste inciso II, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no inciso II do § 2º do art. 50 da Lei no. 9.478, de 6 de agosto de 1997.

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. O Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

e) Vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento (25,5%) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" do inciso I e deste inciso II, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no inciso III do § 2º do art. 50 da Lei no. 9.478, de 6 de agosto de 1997;

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. O Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

f) Três por cento para o Ministério da Defesa, para atender aos encargos decorrentes do emprego dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na fiscalização e proteção das áreas de produção e distribuição;

g) Dezessete por cento para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1º A soma dos valores referentes aos *royalties* devidos aos Municípios nos termos dos incisos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste artigo, com os *royalties* devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II dos arts. 48 e 49 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º do art. 50 da Lei no. 9.478, de 6 de agosto de 1997, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I – os valores que o Município recebeu a título de *royalties* e participação especial em 2011;

II – a duas vezes o valor *per-capita* distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 2º A parcela dos *royalties* de que trata este artigo que contribuiu para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 1º será transferido para o fundo especial de que trata a alínea "e" dos incisos I e II.

§ 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de *royalties* aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos incisos I e II.

§ 4º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" dos incisos I e II poderá ser feita após conhecido o valor dos *royalties* e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

Art. 42-C Os recursos do fundo especial de que tratam os incisos IV e V do art. 42-B terão a destinação prevista no art. 50-E da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.

[...]

Art. 49 [...]

[...]

IV – (revogado)

[...]

§ 1º (revogado)

Lei 9.478

Art. 48. A parcela do valor dos *royalties*, previstos no contrato de concessão, que representar cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:

I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

a) setenta por cento aos Estados onde ocorrer a produção;

b) vinte por cento aos Municípios onde ocorrer a produção; e

c) dez por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP.

II – quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva:

a) vinte por cento para os Estados produtores confrontantes;

b) dezessete por cento para os Municípios produtores confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) três por cento para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) vinte por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei, e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei.

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. O Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

e) vinte por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II, do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. O Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

f) três por cento para o Ministério da Defesa, para atender aos encargos decorrentes do emprego dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na fiscalização e proteção das áreas de produção e distribuição;

g) dezessete por cento para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1º A soma dos valores referentes aos *royalties* devidos aos Municípios nos termos dos incisos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os *royalties* devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste art. 48 e do art. 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I – os valores que o Município recebeu a título de *royalties* e participação especial em 2011;

II – a duas vezes o valor *per-capita* distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 2º A parcela dos *royalties* de que trata este artigo que contribuir para o que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 1º será transferido para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

[...]

§ 4º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos *royalties* e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento. (NR)

Art. 49. [...]

I – [...]

d) três por cento para o Ministério da Defesa, para atender aos encargos decorrentes do emprego dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na fiscalização e proteção das áreas de produção e distribuição.

e) vinte e dois por cento para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

II – [...]

a) vinte por cento para os Estados produtores confrontantes;

b) dezessete por cento para os Municípios produtores confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) três por cento para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) vinte por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei, e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei.

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. O Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

e) vinte por cento para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. Os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II, do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159, da Constituição;

3. O percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item "1" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. O Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item "1";

5. Os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item "4" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea.

f) três por cento para o Ministério da Defesa, para atender aos encargos decorrentes do emprego dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na fiscalização e proteção das áreas de produção e distribuição;

g) dezessete por cento para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1º (revogado)

§ 2º (revogado)

§ 3º (revogado)

§ 4º A soma dos valores referentes aos *royalties* devidos aos Municípios nos termos dos incisos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os *royalties* devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste artigo e do art. 48 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de *royalties* e participação especial em 2011;

II – a duas vezes o valor *per-capita* distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 5º A parcela dos *royalties* de que trata este artigo que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 4º será transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos *royalties* e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

[...]

Art. 49-A. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "b" do inciso II do art. 48 e a alínea "b" do inciso II do art. 49 serão reduzidos:

I – em dois pontos percentuais em 2013 e em cada ano subseqüente até 2018, quando alcançará cinco por cento;

II – em um ponto percentual em 2019, quando alcançará o mínimo de quatro por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de quatro por cento.

Art. 49-B. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "d" do inciso II do art. 48 e a alínea "d" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:

I – em um ponto percentual em 2013 e em cada ano subseqüente até atingir vinte e quatro por cento em 2016;

II – em um inteiro e cinco décimos de ponto percentual em 2017, quando atingirá vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento (25,5%);

III – em um ponto percentual em 2018, quando atingirá vinte e seis inteiros e cinco décimos (26,5%);

IV – em cinco décimos de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de vinte e sete por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de vinte e sete por cento.

Art. 49-C. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "e" do inciso II do art. 48 e a alínea "e" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:

I – de um ponto percentual em 2013 e em cada ano subseqüente até atingir vinte e quatro por cento em 2016;

II – de um inteiro e cinco décimos de ponto percentual em 2017, quando atingirá vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento (25,5%);

III – um ponto percentual em 2018, quando atingirá vinte e seis inteiros e cinco décimos (26,5%);

IV – cinco décimos de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de vinte e sete por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de vinte e sete por cento.

Art. 50. [...]

§2º [...]

I – quarenta e dois por cento à União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;

II – trinta e quatro por cento para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;

III – cinco por cento para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;

IV – nove inteiros e cinco décimos por cento (9,5%) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

a) Os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei, e no inciso II do § 2º deste artigo.

b) O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, de que trata o art. 159, da Constituição;

c) O percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

d) O Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba os recursos referidos na alínea "a";

e) Os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso.

V – nove inteiros e cinco décimos por cento (9,5%) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

a) Os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II, do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2º deste artigo;

b) O rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159, da Constituição;

c) O percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

d) O Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba os recursos referidos na alínea "a";

e) Os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso.

§ 3º [...]

§ 4º (revogado)

§ 5º A soma dos valores referentes aos *royalties* devidos aos Municípios nos termos dos incisos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os *royalties* devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II dos arts. 48 e 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º deste artigo, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I – os valores que o Município recebeu a título de *royalties* e participação especial em 2011;

II – a duas vezes o valor *per-capita* distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata a alínea "d" dos incisos IV e V poderá ser feita após conhecido o valor dos *royalties* e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

§ 7º A parcela da participação especial que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 5º será transferida para o fundo especial de que trata o inciso V do § 2º.

Art. 50-A. O percentual de distribuição a que se refere o inciso I do § 2º do art. 50 será acrescido de um ponto percentual em 2013 e em cada ano subseqüente até 2016, quando alcançará quarenta e seis por cento.

Parágrafo único. A partir de 2016, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de quarenta e seis por cento.

Art. 50-B. O percentual de distribuição a que se refere o inciso II do § 2º do art. 50 será reduzido:

I – em dois pontos percentuais em 2013, quando atingirá trinta e dois por cento;

II – em três pontos percentuais em 2014 e em 2015, quando atingirá vinte e seis por cento;

III – em dois pontos percentuais em 2016, em 2017 e em 2018, quando atingirá vinte por cento.

Parágrafo único. A partir de 2018, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de vinte por cento.

Art. 50-C. O percentual de distribuição a que se referem o inciso III do § 2º do art. 50 será reduzido em um ponto porcentual em 2019, quando atingirá quatro por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de quatro por cento.

Art. 50-D. O percentual de distribuição a que se refere o inciso IV do § 2º do art. 50 será acrescido:

I – em cinco décimos de ponto percentual em 2013, quando atingirá dez por cento;

II – em um ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá doze por cento;

III – em cinco décimos de ponto percentual em 2016, quando atingirá doze inteiros e cinco décimos por cento (12,5%);

IV – em um ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá quatorze inteiros e cinco décimos por cento (14,5%).

V – em cinco décimos de ponto percentual em 2019, quando atingirá quinze por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de quinze por cento.

Art. 50-E. O percentual de distribuição a que se refere o inciso V do § 2º do art. 50 será acrescido:

I – em cinco décimos de ponto percentual em 2013, quando atingirá dez por cento;

II – em um ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá doze por cento;

III – em cinco décimos de ponto percentual em 2016, quando atingirá doze inteiros e cinco décimos por cento (12,5%);

IV – em um ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá quatorze inteiros e cinco décimos por cento (14,5%).

V – em cinco décimos de ponto percentual em 2019, quando atingirá quinze por cento.

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de quinze por cento.

> **Art. 50-E** O fundo especial de que tratam as alíneas "d" e "e" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei, os incisos IV e V do § 2º do art. 50 desta Lei e as alíneas "d" e "e" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão destinados para as áreas de educação, infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, em programas voltados para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e para o tratamento e reinserção social dos dependentes químicos.
>
> **Parágrafo único.** Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão anexo contendo a previsão para a aplicação dos recursos de que trata o *caput* junto aos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis do orçamento anual.

A aplicação conjugada desses dispositivos legais resultará:

(a) na destinação da maior parte dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás a unidades federadas que não são impactadas pelo exercício dessa atividade econômica, comumente designadas como Estados e Municípios não-produtores, reduzindo, com isso, os recursos financeiros distribuídos, a esse título, às unidades federadas impactadas, comumente designadas como Estados e Municípios produtores;

(b) na incidência dessa nova opção político-legislativa sobre operações relativas a áreas já licitadas, e que já se encontram em produção.

A técnica empregada pelo legislador foi a estipulação de novos percentuais para a distribuição dos *royalties*[2] relativos às operações regidas pela Lei nº 12.351/2010 (regime de partilha de produção) e para a distribuição dos *royalties* e participações especiais relativos às operações regidas pela Lei nº 9.478/1997 (regime de concessão); sendo que, para as operações relativas ao regime de concessão, previu-se, ainda, a redução anual dos percentuais fixados, até 2020[3].

[2] Não há pagamento de participações especiais no regime de partilha de produção.

[3] Cfr., a propósito, a redação conferida pela Lei nº 12.734/2012 ao artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, ao artigo 42-C e aos inciso IV e parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2012, bem como ao artigo 48 da Lei nº 9.478/1997 e parágrafo 4º, ao artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º e 6º, ao artigo 49-A e parágrafo único, ao artigo 49-B e parágrafo único, ao artigo 49-C e parágrafo único, aos parágrafos 2º, 4º e 6º do artigo 50, ao artigo 50-A e parágrafo único, ao artigo 50-B e parágrafo único, ao artigo 50-C e parágrafo único, ao artigo 50-D e parágrafo único, ao artigo 50-E e parágrafo único, ao artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997.

Esses números encontram-se consolidados nas seguintes tabelas, apresentadas no parecer do Senador Vital do Rego[4], do Estado da Paraíba, relator da matéria no Senado da República:

Tabela 1: Proposta do Substitutivo para repartição dos *royalties* de 2012 a 2020[5]

ROYALTIES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
União	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Total dos confrontantes	61,25 %	61,25 %	40%	38%	36%	34%	32%	29%	27%	26%	26%
Estados confrontantes	26,25 %	26,25 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Municípios confrontantes	26,25 %	26,25 %	17%	15%	13%	11%	9%	7%	5%	4%	4%
Municípios afetados	8,75 %	8,75%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%
Fundo especial	8,75 %	8,75%	40%	42%	44%	46%	48%	51%	53%	54%	54%
FPE	7%	7%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26,50%	27%	27%
FPM	1,75 %	1,75%	20%	21%	22%	23%	24%	25,50%	26,50%	27%	27%

Tabela 2: Proposta do Substitutivo para repartição da participação especial de 2012 a 2020[6]

ROYALTIES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
União	50%	50%	42%	43%	44%	45%	46%	46%	46%	46%	46%
Total dos confrontantes	50%	50%	39%	37%	34%	31%	29%	27%	25%	24%	24%
Estados confrontantes	40%	40%	34%	32%	29%	26%	24%	22%	20%	20%	20%
Municípios confrontantes	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%
Municípios afetados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Fundo especial	0%	0%	19%	20%	22%	24%	25%	27%	29%	30%	30%
FPE	0%	0%	9,50%	10%	11%	12%	12,50%	13,50%	14,50%	15%	15%
FPM	0%	0%	9,50%	10%	11%	12%	12,50%	13,50%	14,50%	15%	15%

Deles se extrai, com relativa facilidade, que as unidades federadas impactadas pela exploração de petróleo e gás passarão a receber menos *royalties* e participações especiais que as unidades federadas que não são impactadas, a quem serão distribuídos os recursos destinados aos chamados "fundos especiais".

Observe-se, a propósito, que já neste ano de 2013 o percentual de *royalties* destinados aos "fundos especiais" (42%) supera o somatório dos percentuais atribuídos aos Estados e Municípios impactados (38%); sendo que, em 2020, o aporte de recursos direcionado aos "fundos especiais" (54%) corresponderá a mais que o dobro do

[4] Disponível na internet: <http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/pdfs/parecer_%20royalties.pdf>; acesso em 23 de outubro de 2011.

[5] Disponível na internet: <http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/pdfs/parecer_%20royalties.pdf>; acesso em 23 de outubro de 2011. p. 17-18.

[6] Disponível na internet: <http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/pdfs/parecer_%20royalties.pdf>; acesso em 23 de outubro de 2011. p. 18.

somatório dos percentuais conferidos aos Estados e Municípios impactados (26%). Quanto ao particular, os Estados e Municípios impactados sofrerão, ao longo do período, perda percentual de 57,55% (cinqüenta e sete vírgula cinqüenta e cinco por cento).

No que se refere às participações especiais, a distribuição de recursos entre Estados e Municípios impactados e não impactados se iguala em 2017, chegando ao seu ápice em 2020. Quando ao pormenor, a perda percentual de receitas pelos Estados e Municípios impactados, na comparação entre o quantitativo de recursos que recebem atualmente e os percentuais que a lei especifica para recebimento de participações especiais em 2020, corresponde a 62% (sessenta e dois por cento).

Ao ensejo, também merece ser destacado que as modificações impressas pela Lei nº 12.734/2012 às Leis nº 9.478/1997 e 12.351/2010 fazem com que os Municípios produtores de petróleo e gás sejam especialmente prejudicados, porque além de sofrerem redução percentual do seu quinhão na distribuição de *royalties* e participações especiais verão suas receitas minoradas por "limitador" de recursos aplicável à exploração do petróleo e gás no mar, que estabelece como "teto" à distribuição dessa receita pública aos Municípios impactados (i) os valores recebidos a título de *royalties* e participação especial em 2011 ou (ii) o dobro do valor *per capita* distribuído pelo fundo de participação dos Municípios, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município, o que for maior[7]. Essa previsão legislativa impõe severas restrições ao recebimento de *royalties* e participações especiais pelos Municípios que vierem a suportar as conseqüências de aumentos na produção de petróleo e gás, e também por aqueles onde forem descobertas novas jazidas. Esses Municípios, por não terem presenciado produção petrolífera no ano de 2011, ou porque sua produção se deu em patamares inferiores aos que serão praticados após as novas descobertas, passarão a receber *royalties* e participações especiais com base nos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, isto é, pelos mesmos critérios atribuídos pelo legislador aos Municípios que não são impactados pela exploração de petróleo e gás.

[7] Cfr., a propósito, a redação conferida pela Lei nº 12.734/2012 aos parágrafos 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº 9.478/1997, aos parágrafos 4º e 5º do seu artigo 49 e aos parágrafos 5º e 7º do seu artigo 50.

Por induzirem tais efeitos, os dispositivos legais anteriormente transcritos violam regras e princípios insculpidos na Carta de 1988, que serão explicitados na seqüência.

Assim, para impedir que diploma legislativo absolutamente nulo espraie efeitos ilegítimos no corpo social, bem como para restaurar a higidez do sistema jurídico, o Governador do Estado do Espírito Santo, vem, respeitosamente, diante dessa Excelsa Corte, propor a presente Ação Direita de Inconstitucionalidade, e o faz com respaldo na doutrina jurídica e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. Direito.

2.1. Intróito: importância do Supremo Tribunal Federal para preservação do texto constitucional em face das opções políticas majoritárias.

Desde o ano de 2010 o País vem presenciando preocupante dissídio entre unidades federadas sobre como deve se processar a distribuição dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração do petróleo e gás no País. Essa discussão teve lugar no Congresso Nacional, onde Deputados e Senadores procuraram sustentar, cada qual ao seu modo, a solução política que resultasse mais receitas para os seus respectivos Estados e Municípios.

Bem retrata essa situação as declarações prestadas à Central Globo de Jornalismo pelo Deputado Ibsen Pinheiro, um dos artífices da tese da distribuição indistinta desses recursos financeiros a todas as unidades federadas, dias antes da aposição do Veto ao artigo 64 da Lei nº 12.351/2012[8] pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

> "Não imagino um presidente da República vetar uma matéria para agradar dois governadores e entrar em conflito com 25. Posso lembrar aqui aliados importantes do presidente como os governadores Eduardo Campos (PSB-PE) e Cid Gomes (PSB-

[8] Primeiro dispositivo aprovado pelo Parlamento para a modificação da sistemática de distribuição de *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás, que previa a distribuição da integralidade dessa receita pelos critérios dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, mas acabou vetado pela Presidência da República.

CE) que apoiaram desde o começo a nossa emenda. Acho que o presidente não vetará"[9].

Como resultado desse embate, prevaleceu, em âmbito político-parlamentar, a força da maioria, seja quando da aprovação do texto da Lei nº 12.351/2010, com os acréscimos que lhe foram promovidos pela chamada Emenda Ibsen/Simon[10] (que, como dito, foi objeto de Veto Presidencial), seja quando da aprovação da proposta legislativa que redundou na edição da Lei nº 12.734/2012, que concebeu nova disciplina jurídica para a distribuição aos Estados e Municípios de *royalties* e participações especiais. No que interessa ao julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, essa maioria que se formou no Congresso Nacional decidiu que os *royalties* e as participações especiais advindas da exploração de petróleo e gás devem ser distribuídas em maior proporção aos Estados e Municípios que não são impactados pelo exercício dessa atividade econômica.

Essa opção político-legislativa não se compatibiliza com os valores Republicanos subjacentes ao texto da Carta Política brasileira, pautando-se, a bem da verdade, em pragmatismo absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. Assim, o que se pretende com esta Ação Direta de Inconstitucionalidade é por em evidência que a decisão político-parlamentar por distribuir maior parte dos *royalties* e participações especiais que a Constituição confere aos Estados e Municípios a unidades federadas que não são impactadas pela exploração de petróleo e gás, embora resulte de posição majoritária construída no Congresso Nacional, não se sustenta à luz da

[9] Disponível na internet: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/e-natural-veto-emenda-dos-royalties-do-petroleo-diz-lider-do-governo.html>; acesso em 02 de dezembro de 2010.

[10] A chamada Emenda Ibsen-Simon advém, na verdade, de duas Emendas Parlamentares: uma primeira, proposta à Câmara dos Deputados pelo Deputado Federal Ibsen Pinheiro (Emenda Ibsen), e uma outra, apresentada no Senado pelo Senador Pedro Simon (Emenda Simon). O seu tratamento conjunto pelos meios de imprensa, qualificando-as simplesmente como Emenda Ibsen-Simon, decorre da circunstância de serem idênticos os seus conteúdos, com exceção, apenas, de um acréscimo promovido pelo Senador Pedro Simon, que previu o pagamento de compensações financeiras aos Estados e Municípios produtores pelas suas perdas de recursos em termos nominais. Em síntese, ambas as Emendas previam a distribuição indistinta a todos os Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo. Essa expressão cunhada pela imprensa (Emenda Ibsen-Simon) acabou consagrada, de igual modo, nos meios políticos e jurídicos, e por isso também será empregada neste trabalho, no qual, de um modo geral, as referências a essa opção político-legislativa pela distribuição indistinta de *royalties* e participações especiais a todas as unidades federadas serão atribuídas à chamada Emenda Ibsen-Simon.

Constituição da República, e por isso não se apresenta como legítima expressão da democracia[11-12].

Foi Carl Schmitt quem disse que "a crença no sistema parlamentar, numa *government by discussion*, pertence ao mundo intelectual do liberalismo" e não à democracia, enfatizando, adiante, que "o liberalismo e a democracia devem ser separados, para que se reconheça a imagem heterogeneamente montada que constituiu a moderna democracia de massas"[13]. Essa compreensão é deveras importante, pois a circunstância de a democracia ter como suporte ineliminável o princípio majoritário, não significa que o princípio democrático admite o absolutismo (ou o domínio) da maioria[14], como leciona José Joaquim Gomes Canotilho.

A propósito, Canotilho adverte que "a maioria não pode dispor de toda <<legalidade>>, ou seja, não lhe está facultado, pelo simples facto de ser maioria, tornar disponível o que é indisponível", o que implica reconhecer que o direito da maioria sempre estará em concorrência com o direito das minorias, notadamente no que se refere aos direitos, liberdades e garantias e, em geral, a toda a disciplina constitucionalmente fixada, contexto em que "o princípio da constitucionalidade sobrepõe-se ao princípio maioritário"[15].

Exatamente por esse motivo é que não se pode ter por absoluta a separação entre os Poderes, contexto em que o Parlamento assume o papel do Legislativo, mas com limitações[16]; o que torna relativo o racionalismo situado na base da

---

[11] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 27-33, passim.

[12] Quanto ao particular, ler também: MADUREIRA, Claudio Penedo. *Direito e democracia: esforço teórico de delimitação dos papeis do Legislativo e do Judiciário no processo construtivo do Direito*. In: Revista Fórum Administrativo, ano 11, n. 129, p. 31-38, nov. 2011. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

[13] SCHMITT, Carl. *A crise da democracia parlamentar*. Tradução de Inês Lohbauer. São Paulo: Scritta, 1996. p. 10.

[14] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 329.

[15] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 329.

[16] A propósito, confira-se, também, essa outra passagem da obra de Canotilho: "Embora se defenda a inexistência de uma separação absoluta de funções, dizendo-se simplesmente que a uma função corresponde um titular principal, sempre se coloca o problema de saber se haverá um núcleo essencial caracterizador do

idéia do balanceamento (próprio da teoria republicana) e diferencia esse sistema daquele racionalismo absoluto do Iluminismo (próprio da teoria liberal)[17], como leciona Carl Schmitt. Canotilho pontua a distinção entre essas duas abordagens teóricas na seguinte passagem de sua obra:

> "A teoria liberal assenta nos seguintes postulados: (1) a política é um meio para a prossecução de fins, estando estes fins radicados numa esfera de liberdade social preexistente à própria política; (2) o processo democrático serve para colocar o estado ao serviço da sociedade, reduzindo-se este estado a um aparelho administrativo e estruturando-se a sociedade como um sistema econômico baseado no comércio entre pessoas privadas; (3) a política deve orientar-se no sentido de prosseguir estes interesses privados perante um aparelho administrativo que se transformou em poder especializado de prossecução de fins colectivos.
>
> [...]
>
> Segundo a teoria republicana a política é uma dimensão constitutiva da formação da vontade democrática e por isso: (1) assume a forma de um compromisso ético-político referente a uma identidade colectiva no seio da comunidade; (2) não existe espaço social fora do espaço político traduzindo-se a política numa forma de reflexão do bem comum; (3) a democracia é, desta forma, a auto-organização política da comunidade no seu conjunto"[18].

Dentro dessa ótica republicana, que é inerente ao sistema jurídico brasileiro[19], a separação entre os poderes torna-se essencial para a busca da justiça, que vai aqui entendida como um ideal objetivo, desvinculado do sentimento popular, pois, como disse Owen Fiss, "supõe-se que as Cortes fazem o que é certo, e não o que é popular"[20-21]. Essa forma de independência, argumenta o professor norte-americano, "também permite que o Judiciário, ao se manter em consonância com a doutrina de separação de poderes, aja como uma força em contrapeso no Estado, verificando a

---

princípio da separação e absolutamente protegido pela Constituição. Em geral, afirma-se que a nenhum órgão podem ser atribuídas a outro. Quer dizer: o princípio da separação exige, a título principal, a correspondência entre órgão e função e só admite excepções quando não for sacrificado o seu núcleo essencial" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 559).

[17] SCHMITT, Carl. *A crise da democracia parlamentar*, cit., p. 38-39.

[18] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 1.414-1.415.

[19] Afinal, nosso País se apresenta, por disposição expressa dos artigos 1° e 4° da Constituição de 1988, como uma República Federativa.

[20] FISS, Owen. *O correto grau de independência.* In: FISS, Owen. *Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre Jurisdição, Constituição e Sociedade.* Tradução de Daniel Porto Godinho da Silva e Melina de Medeiros Rós, sob a coordenação de Carlos Alberto de Salles. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 155.

[21] Até porque, conforme leciona Raffaele De Giorgi, "a idéia de representação parlamentar exprime publicamente os temas da política, organizando as decisões de modo a produzir consenso, não obstante o dissenso sobre os princípios" (DE GIORGI, Raffaele. *Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro.* Porto Alegre: SAFE, 1998. p. 41).

ocorrência de abusos de poder por parte do Legislativo e Executivo"[22]. Essa é, pois, a conformação e a missão do "sistema de freios e contrapesos", que, nas palavras de Paulo Bonavides, constitui a primeira correção essencial que se impôs ao princípio democrático, como decorrência, até certo ponto empírica, da prática constitucional[23].

Por isso é que, como há muito observaram os *federalistas* Hamilton, Madson e Jay, os Tribunais têm "o dever de declarar nulos todos os atos contrários ao manifesto espírito da Constituição", pois, se assim não fosse, "todas as restrições contra os privilégios ou concessões particulares serão inúteis"[24]. O Poder Judiciário é, pois, instituição estratégica nas democracias contemporâneas, cuja atuação não se limita às funções meramente declarativas do Direito, e por isso deve se impor, entre os Poderes da República, como uma agência indutora de um efetivo *checks and balances* e da garantia individual e cidadã[25], conforme lecionam os cientistas políticos Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Resende de Carvalho, Manuel Palácios Cunha Melo e Marcelo Baumann Burgos.

É pacífica, entre nós, a tese da legitimação democrática do Poder Judiciário para proceder ao controle da constitucionalidade das leis. Essa atividade lhe é conferida pela própria Constituição, que, enquanto "norma fundante", encontra-se plenamente autorizada a estabelecer os contornos da atuação de cada um dos Poderes da República, concebendo, nesse contexto, mecanismos que impeçam a edição de leis que a contradigam, entre os quais se destaca o controle judicial da constitucionalidade das leis. Assim não fosse, não estaria o Supremo Tribunal Federal, dia após dia, a exercê-lo, seja de forma indireta (controle difuso), quando processa recursos extraordinários interpostos no corpo de ações judiciais mantidas entre particulares, ou entre eles e a Administração Pública, seja de forma direta, ou abstratamente (controle concentrado), quando aprecia ações declaratórias da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis.

---

[22] FISS, Owen. *O correto grau de independência*, cit., p. 155.

[23] BONAVIDES, Paulo. *Do Estado liberal ao Estado social*. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 74.

[24] HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. *O federalista*. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 2ª ed. Campinas: Russel, 2005. p. 471.

[25] VIANNA, Luiz Werneck; MELO, Manuel Palácios Cunha; e BURGOS, Marcelo Baumann. *A judicialização da política e das relações sociais no Brasil*. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 24.

Nisso não reside qualquer ofensa ao princípio democrático. Canotilho alude, em sua obra, a diversas dimensões do princípio democrático, dispondo, adiante, que somente a partir delas é que "se conseguirá explicar a relevância dos vários elementos que as teorias clássicas procuravam unilateralmente transformar em *ratio* e *ethos* da democracia"[26]. Em tal conjuntura, o professor português refere à "democracia representativa", que ele qualifica, entre outros fatores, pela existência de órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário, separação de poderes; e à "democracia participativa", que ele coliga à "estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos processos de decisão, exercer controlo crítico na divergência de opiniões"[27]. Noutra passagem, após discorrer sobre as particularidades da aplicação do Direito de nosso tempo, refere à "democracia deliberativa", cujos contornos principais seriam a existência de uma política deliberativa assente na idéia de "virtude cívica", assim como a possibilidade de que se promova a igualdade entre os participantes no processo político, o consentimento universal nas disputas normativas através da razão prática e os direitos de participação dos cidadãos na vida pública, pela via do controle dos seus representantes[28-29].

---

[26] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 288.

[27] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 288.

[28] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 1.416.

[29] Canotilho refere, ainda, à "democracia discursiva", que atribui a Habermas, e que, em sua opinião, distingue-se do "republicanismo liberal" norte-americano, e da "democracia deliberativa", por não se assentar "em direitos universais do homem (ou direitos preexistentes na perspectiva liberal) nem na moral social de uma comunidade determinada (como sustenta a visão republicana), mas em regras de discussão, formas de argumentar, institucionalização de processos [...], cujo fim é proporcionar uma solução nacional e universal a questões problemáticas, morais e éticas da sociedade" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, cit., p. 1.416-1.417). Mas é possível compreendê-las, a "democracia deliberativa" e a "democracia discursiva", como uma mesma acepção de democracia, designada simplesmente como "democracia deliberativa". André Ramos Tavares, tendo em vista essa distinção feita por Canotilho entre a democracia participativa discursiva da deliberativa, admite que dessas opções terminológicas possam "ocasionar confusões conceituais de correntes de armadilhas da linguagem" (TAVARES, André Ramos. *Democracia deliberativa: elementos, aplicações e implicações.* In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 1, n. 1, jan./mar. 2007. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 79-Nota de rodapé), e a elas refere como sendo uma só categoria, quando, adiante, observa que a "democracia deliberativa é também conhecida como dialógica, consensual, inclusiva ou discursiva" (TAVARES, André Ramos. *Democracia deliberativa: elementos, aplicações e implicações*, cit., p. 79). Demais disso, Habermas, em seus escritos, refere reiteradamente a uma "política deliberativa", por ele qualificada como o âmago do processo democrático, e que ele procura distinguir da concepção do Estado tido como protetor de uma sociedade econômica e do conceito republicano de uma comunidade ética institucionalizada na forma de Estado (HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia entre facticidade e validade – Volume II.* Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 18). Tal não bastasse, mesmo Alexy, celebrizado pelo desenvolvimento da teoria do discurso, designa essa dimensão do princípio democrático como "democracia deliberativa", dispondo

Sobre essa acepção de democracia, André Ramos Tavares acentua que "uma das obras contemporâneas que mais influenciou o debate sobre o assunto, considerada como referencial obrigatório, é a de Amy Gutmann e Dennis Thompson"[30]. Para esses professores norte-americanos "a democracia deliberativa afirma a necessidade de justificar decisões tomadas por cidadãos e seus representantes", num contexto em que se espera "que ambos justifiquem as leis que eles imporiam um ao outro"[31-32].

Ainda acerca dessa acepção de democracia, Claudio Pereira de Souza Neto leciona que "a democracia deliberativa surge, nas duas últimas décadas do século XX, como alternativa às teorias da democracia então predominantes, as quais a reduziam a um processo de agregação de interesses particulares, cujo objetivo seria a escolha de elites governantes"[33]. Conforme Souza Neto, a "democracia deliberativa" contrapõe-se a essas "teorias agregativas", e assume como premissa a compreensão de que o processo democrático não pode se restringir à prerrogativa popular de eleger representantes (já que a experiência histórica demonstra que democracia assim concebida, pode ser amesquinhada e manipulada), devendo, portanto, "envolver, além da escolha de representantes, também a possibilidade efetiva de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas"[34]. Sob essa ótica, o Poder Judiciário,

---

taxativamente que "*o princípio do discurso exige a democracia deliberativa*" (ALEXY, Robert. *A institucionalização da razão.* In: ALEXY, Robert. *Constitucionalismo discursivo.* Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 35). Para Alexy, "a democracia deliberativa é mais do que um procedimento para a produção de uma compensação de interesses ótima abaixo do limite de ditadura ou guerra civil", pois, "nela, o plano dos interesses e do poder é coberto por um plano dos argumentos, no qual todos os participantes lutam por uma solução política correta" (ALEXY, Robert. *A institucionalização da razão*, cit., p. 35).

[30] TAVARES, André Ramos. *Democracia deliberativa: elementos, aplicações e implicações*, cit., p. 81.

[31] GUTMAN, Amy e THOMPSON, Dennis. *O que significa democracia deliberativa.* Tradução de Bruno Oliveira Maciel. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 1, n. 1, jan./mar. 2007. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 19.

[32] Esse texto, publicado no primeiro número da Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, editado sob a coordenação de André Ramos Tavares e Pedro Buck, compõe o primeiro capítulo da obra "Why Deliberative Democracy?" (GUTMAN, Amy e THOMPSON, Dennis. *Why Deliberative Democracy?* Princeton: Princeton University Press, 2004).

[33] SOUZA NETO, Claudio Pereira de. *Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação democrática.* In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 1, n. 1, jan./mar. 2007. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 104.

[34] SOUZA NETO, Claudio Pereira de. *Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação democrática*, cit., p. 104.

quanto exerce o controle de constitucionalidade das leis, não contraria, ou ofende, o princípio democrático, mas, em verdade, o confirma[35]. Até porque, como disse o professor fluminense, "não há verdadeira democracia sem respeito aos direitos fundamentais"[36-37].

Assim, o que se espera do Supremo Tribunal Federal, como Tribunal Constitucional, e portanto como foro técnico designado pela Carta Política para a preservação dos valores constitucionais, é que faça valer o texto da Constituição, e que restaure o direito dos Estados e Municípios produtores de petróleo e gás de receberem a necessária contraprestação pelos ônus suportados pela exploração desses recursos naturais em seu território, na plataforma continental correspondente a esses territórios, no mar territorial correspondente a esses territórios e na zona econômica exclusiva correspondente a esses territórios.

Do contrário, não triunfará o Direito, nem a democracia, mas o arbítrio e a opressão da maioria sobre a minoria.

---

[35] Souza Neto observa, ao ensejo, que as Cortes Constitucionais, quando garantem a fruição de direitos fundamentais contra a vontade da maioria ou diante da sua inércia, "não estão violando o princípio democrático, mas estabelecendo as condições para sua plena realização" (SOUZA NETO, Claudio Pereira de. *Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação democrática*, cit., p. 105).

[36] SOUZA NETO, Claudio Pereira de. *Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação democrática*, cit., p. 105.

[37] Confira-se, a propósito, a seguinte passagem de Alexy: "Tudo isso explica porque em todos os estados, dotados com catálogo de direitos fundamentais e jurisdição constitucional, sobre a interpretação dos direitos fundamentais, não só é refletido com calma, mas também litigado na arena política. Pode falar-se de uma luta pela interpretação dos direitos fundamentais. Juiz arbitral nessa luta, porém, não é o povo, mas o tribunal constitucional respectivo. Isso é compatível com o principio democrático, cujo núcleo, no artigo 1°, parágrafo único, da constituição brasileira, assim como no artigo 20 alínea 2, proposição 1, da lei fundamental, é expressado com a formulação clássica: "Todo poder estatal provém do povo"? Os direitos do homem parecem converter-se em um problema para a democracia quando eles são levados a sério e de um mero ideal transformados, por institucionalização, em algo real. É exata essa impressão? É o ideal, do qual se trata no preâmbulo da declaração dos direitos do homem universal, uma quimera que leva ao arrebentamento uma contradição entre direitos fundamentais e democracia?" (ALEXY, Robert. *Direitos fundamentais no estado constitucional democrático.* In: ALEXY, Robert. *Constitucionalismo discursivo.* Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 51-52).

2.2. Inconstitucionalidade da opção político-legislativa por distribuir de forma indistinta a todas as unidades federadas os *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás.

Como se terá a oportunidade de adiante expor e demonstrar, a opção político-legislativa por distribuir a unidades federadas que não são impactadas pela exploração do petróleo e gás (Estados e Municípios produtores) a maior parte dos *royalties* e participações especiais arrecadadas como decorrência do exercício dessa atividade econômica, instrumentalizada pelos dispositivos legais impugnados, que têm redação dada pela Lei nº 12.734/2012:

> **(a)** contraria do disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, na acepção que lhe conferiu o constituinte e na interpretação que lhe é correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
>
> **(b)** ofende o princípio da isonomia (CRFB, art. 5º, *caput*);
>
> **(c)** ofende o princípio federativo (CRFB, art. 1º e art. 60, p. 4º, I);
>
> **(d)** ofende o princípio da segurança jurídica (art. 5º, *caput* e inciso XXXVI).
>
> Vejamos:

2.2.1. Violação ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição.

A Constituição da República assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, assim como a órgãos da administração direta da União, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou

compensação financeira por essa exploração[38]. Tal se infere da simples leitura do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que resta vazado nos seguintes termos:

> **CRFB**
>
> **Art. 20.** São bens da União:
>
> [...]
>
> **§ 1º** - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

Esse é o contexto em que se inserem os *royalties* e as participações especiais que as empresas exploradoras recolhem ao poder público como contrapartida pela exploração do petróleo e do gás natural. Ao ensejo, cumpre referir ao magistério de Rodrigo Caramori Petry, que leciona que "as empresas envolvidas na exploração de petróleo e gás natural estão sujeitas a uma série de cobranças, chamadas genericamente de 'participações governamentais'", dispondo, ao ensejo, que a principal dessas participações "é denominada de *royalties*, cuja cobrança é administrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com base na Lei 9.478/1997 e seu regulamento (Dec. 2.705/1998)"[39]; e dispõe, ainda, que "a Lei do Petróleo em vigor também prevê no inc. III de seu art. 45 uma outra cobrança a ser paga pelas concessionárias nas atividades ligadas ao petróleo e gás", chamada "participação especial", que se apresenta como "espécie de adicional da participação comum (os *royalties*, já comentados no item anterior), arrecadada em benefício dos Estados, dos Municípios e de órgãos da União Federal"[40], e que "será devida apenas nos casos de grande volume de produção ou de rentabilidade na exploração e produção de petróleo e gás"[41]. A propósito, Luiz Henrique Travassos Machado observa que essas duas modalidades de participações governamentais (*royalties* e participações especiais) "são

[38] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 35-86, passim.

[39] PETRY, Rodrigo Caramori. *Compensações financeiras, participações e outras cobranças estatais sobre empresas dos setores de mineração, energia, petróleo e gás.* In: Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo, ano 17, n. 89, nov./dez. 2009. p. 263.

[40] PETRY, Rodrigo Caramori. *Compensações financeiras, participações e outras cobranças estatais sobre empresas dos setores de mineração, energia, petróleo e gás*, cit., p. 268.

[41] PETRY, Rodrigo Caramori. *Compensações financeiras, participações e outras cobranças estatais sobre empresas dos setores de mineração, energia, petróleo e gás*, cit., p. 269.

responsáveis pela quase totalidade dos recursos distribuídos a esse título, correspondendo a cerca de 95,75% entre janeiro de 2005 e julho de 2010"[42].

O primeiro diploma legal a disciplinar o pagamento dessas retribuições financeiras aos Estados e Municípios após a promulgação da Constituição de 1988 foi a Lei nº 7.990/1989, que dispõe sobre aspectos[43] da "Compensação pela Utilização de Recursos Hídricos"[44] e institui a "Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais"[45], comumente designada como CFEM. No que se refere especificamente à atividade de exploração de petróleo e gás, o artigo 8º da Lei nº 7.990/1989, que tem redação dada pela Lei nº 8.001/1990, dispõe sobre a forma como será paga a compensação financeira devida pela exploração do petróleo e do gás natural, e a designa taxativamente e textualmente como "indenização". Nos precisos termos da lei:

> **Lei 7.990**
>
> **Art. 8º** O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, **inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural** será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal (destaques pessoais).

[42] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. *Federalismo e os royalties do petróleo.* In: Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo, ano 19, vol. 98, maio/jun. 2011. p. 44.

[43] Como se infere de seus artigos 3º, 4º e 5º.

[44] Atualmente regida, nos termos seguintes, pelo artigo 17 da Lei Federal nº 9.648/1998, que tem redação dada pela Lei Federal nº 9.984/2000: "Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da União. § 1º Da compensação financeira de que trata o *caput*: – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1o da Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, com a redação dada por esta Lei; II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei. § 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 1997".

[45] Como se infere do texto de seu artigo 6º: "Art. 6º A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial".

Dispondo desse modo, o legislador recuperou a qualificação atribuída pela redação original do artigo 27 da Lei nº 2.004/1957 às participações governamentais advindas da exploração de petróleo e gás. Eis a redação literal do dispositivo:

> **Lei 2.004**
>
> **Art. 27.** A Sociedade e suas subsidiárias **ficam obrigadas a pagar** aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, ***indenização*** **correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás** (destaques pessoais).

Esse ato legislativo inaugurou uma nova fase na regulamentação legislativa dessa atividade econômica, como observa o professor Gustavo Kaercher Loureiro, da Universidade de Brasília, no seu excelente estudo sobre as participações governamentais na indústria do petróleo e gás[46]. Nesse trabalho, esse professor gaúcho radicado na Capital Federal faz uma análise histórica da legislação que regula a exploração de recursos naturais, abordando a disciplina jurídica dessa atividade econômica desde o Período Colonial até a Constituição de 1988. Dessa análise se pode inferir que desde sempre a legislação tratou as participações governamentais advindas da exploração de recursos naturais como "indenização".

Essa descrição taxativa e textual da retribuição financeira paga aos Estados e Municípios como indenização foi mantida na redação dada ao artigo 27 da Lei nº 2.004/1953 pelas Leis nº 3.257/1957[47] e 7.453/1985[48]. Na verdade, somente em 1989, com a edição da Lei nº 7.990/1989, é que o texto desse artigo 27 da Lei nº 2.004/1953 deixou de empregar o termo indenização, passando a qualificar a referida contraprestação simplesmente como "compensação financeira". Confira-se a redação atual do preceito:

---

[46] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução normativa.* Porto Alegre: SAFE, 2012.

[47] Lei 2.004. "Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar **indenização** correspondente a 4% (quatro por cento) sôbre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra do petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, de indenização de 1% (um por cento) aos Municípios onde fizerem a mesma lavra ou extração. (Redação dada pela Lei nº 3.257, de 1957)" (destaques pessoais).

[48] Lei 2.004. "Art. 27 - A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar **indenização** correspondente a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios e 1% (um por cento) aos Municípios, sobre o valor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraídos de suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do petróleo. (Redação dada pela Lei nº 7.453, de 1985)" (destaques pessoais).

Lei 2004

Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias **ficam obrigadas a pagar a compensação financeira** aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 7.990, de 1989) (destaques pessoais).

Mas isso não quer dizer, em absoluto, que a partir de então a retribuição financeira paga aos Estados e Municípios como decorrência da exploração de petróleo e gás deixou de ser considerada indenização.

Em primeiro lugar porque a Lei nº 8.001/1990 incorporou ao ordenamento jurídico-positivo nova referência ao caráter indenizatório da referida retribuição financeira, o que se infere da simples leitura da redação atual do artigo 8º da Lei nº 7.990/1989, dantes referenciado, que tem redação dada por esse novo diploma[49]. Conquanto a Lei nº 8.001/1990 seja norma posterior, e por isso represente a última expressão da vontade legislativa, não se opera, na hipótese, a revogação tácita do artigo 27 da Lei nº 2.004/1953, na redação que lhe dá a Lei nº 7.990/1989, precisamente porque a expressão "compensação financeira", empregada nesse dispositivo, não é semanticamente incompatível com a expressão "indenização", empregada na redação original do mesmo artigo 27 da Lei nº 2.004/1953 e na redação atual desse artigo 8º da Lei nº 7.990/1989. Mas é fato que essa redação conferida pela Lei nº 8.001/1990 a esse artigo 8º da Lei nº 7.990/1998 reforça a noção de que a referida retribuição financeira ostenta natureza indenizatória.

Em segundo lugar porque, como se terá a oportunidade de adiante expor e demonstrar, a Constituição de 1988, quando disciplinou a matéria no parágrafo 1º do seu artigo 20, qualificou as participações governamentais devidas às unidades federadas pela exploração de recursos naturais como espécie de indenização. Essa conclusão decorre claramente dos limites semânticos do texto desse dispositivo

[49] Lei 7.990. "Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da ***indenização*** **pela exploração do petróleo,** do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal" (destaques pessoais).

constitucional, e também das deliberações parlamentares relativas à sua construção em âmbito político (*mens legislatoris*) e da interpretação que correntemente lhe é atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (*mens legis*).

2.2.1.1. Limites semânticos do texto do parágrafo 1º de artigo 20 da Constituição.

A leitura do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição revela que o constituinte originário conferiu aos Estados e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo e ou gás natural, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou a compensação financeira pelo exercício dessa atividade econômica[50-51].

Diante do texto da Constituição, duas interpretações são possíveis[52]:

[50] CRFB. "Art. 20 [...] § 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

[51] Observe-se, a propósito, a distinção conceitual entre a participação no resultado da exploração de petróleo e gás e compensação financeira pelo exercício dessa atividade econômica é irrelevante para os fins a que se propõe esta Ação Direta de Inconstitucionalidade. A uma porque, como leciona Kiyoshi Harada "a lei optou pelo regime da compensação financeira por ser o mais prático do ponto de vista operacional, o que permite concluir "que a compensação financeira surge como sucedâneo da participação no resultado da exploração de recursos naturais" (HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário.* 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 55). Nesse mesmo sentido se posiciona Regis Fernandes de Oliveira, para quem "o constituinte não foi técnico ou juridicamente preciso, ao utilizar os termos constantes do §1º do art. 20 da Constituição", porque "ambos quiseram referir-se à mesma coisa", ou, em síntese, "o constituinte utilizou duas palavras, sem dar-lhes conteúdo específico e jurídico, querendo dizer que, nas hipóteses mencionadas, haverá divisão dos resultados da produção" (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Curso de direito financeiro.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 219-220). A duas porque, como se verá adiante, tanto os constituintes, quanto os intérpretes da Constituição, com destaque para os posicionamentos da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qualificam essa retribuição financeira como espécie de indenização, que visa a compensar os Estados e Municípios afetados pela exploração de recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações, ou seja, pelos riscos e custos inerentes à atividade extrativista.

[52] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 40-43, passim.

(a) ou se admite que o "respectivo" contido no parágrafo 1º do seu artigo 20 refere-se apenas ao território, o que em tese autorizaria a distribuição a todos os Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva;

(b) ou se admite que essa expressão refere-se não apenas ao território, mas também à plataforma continental, ao mar territorial e à zona econômica exclusiva correspondentes a esse território, o que indica que essas retribuições financeiras devem ser distribuídas tão-somente (ou, quando menos, preponderantemente) aos Estados e Municípios confrontantes com as áreas de exploração de petróleo e gás situadas na costa brasileira.

Essa circunstância foi destacada pelo professor Gustavo Kaercher Loureiro, na seguinte passagem doutrinária:

> "A bem guardar, gramaticalmente, o termo em questão pode reger tanto apenas o 'território' quanto o que se segue ('plataforma continental', 'mar territorial' e 'zona econômica exclusiva').
>
> Na primeira hipótese, a Lei de que fala a norma constitucional deveria reconhecer uma vinculação precisa entre exploração, participação e território estadual/municipal; menos rígido poderia ser este vínculo em se tratando de distribuir a participação oriunda da exploração na plataforma continental, pois que a Constituição não exigiria o nexo (o 'respectivo' não rege a plataforma continental). De consequência, poder-se-ia pensar em uma distribuição total dos recursos, entre todos os sujeitos aí referidos, em condições de absoluta igualdade.
>
> Já pela segunda interpretação, alcançando o termo 'respectivo' todas as localizações indicadas, manter-se-ia o tratamento diferenciado em qualquer circunstância. Direito possui o Estado ou Município em cujo território ou em cuja plataforma continental se realiza a exploração"[53].

A propósito, Loureiro observa que contra a prevalência dessa segunda interpretação pode ser objetado que "juridicamente não existe plataforma continental estadual ou municipal", de maneira que o "respectivo" mencionado no texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição deveria ser referido apenas ao território, o

[53] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa.* Porto Alegre: SAFE, 2012. p. 170-171.

que em tese autorizaria ao legislador repartir como lhe aprouver o resultado da exploração de recursos naturais fora do respectivo território, ou seja, na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva[54]. Mas adverte, em resposta a semelhante objeção, que, "rigor por rigor, sequer 'órgão da União' possui uma sua plataforma continental"[55]. Assim, sob essa ótica, nenhum dos destinatários desse dispositivo constitucional poderia ser beneficiado pelas retribuições financeiras devidas pela exploração de recursos naturais na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva.

Acrescente-se a isso que os órgãos da União Federal tampouco possuem território. Destarte, essa interpretação conduziria à total inaplicabilidade do dispositivo aos órgãos da União Federal (que formalmente não têm território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva) e à sua aplicação apenas parcial aos Estados e Municípios (que formalmente não têm plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva).

Aliás, a prevalência dessa interpretação impediria, em qualquer hipótese, o recebimento de participações governamentais por Estados e Municípios não-produtores. A uma porque essa atividade econômica não é desenvolvida em seus respectivos territórios[56], o que obsta o recebimento de *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás em terra. A duas porque, como os Estados e Municípios produtores, essas unidades federadas também não possuem plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, de modo que a mesma conseqüência que se pretende impor aos Estados e Municípios produtores também lhes seria aplicável. A três porque é imprecisa a afirmação de que, sob esse ponto de vista, o legislador poderia distribuir esses recursos como melhor lhe aprouvesse. Com efeito, a prevalecer essa interpretação, a Constituição teria fechado as portas para o pagamento a Estados e Municípios (a todos eles) de participações governamentais advindas da

[54] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 171.

[55] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 171.

[56] Se houvesse exploração de recursos naturais em seus territórios essas unidades federadas seriam afetadas pelo exercício dessa atividade econômica, e por isso passariam a ser qualificadas como Estados e Municípios produtores.

exploração de recursos naturais fora dos seus respectivos territórios (ou seja, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva correspondentes aos seus territórios); e, como se sabe, não pode a lei, quando do disciplinamento da distribuição desses recursos, contrariar a Constituição, dada a posição de supremacia assumida por essa Carta Política na ordem jurídica[57].

A rigor, a lógica da interpretação segundo a qual os Estados e Municípios produtores, porque não possuem plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, somente podem ser compensados, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, pela exploração de recursos naturais em seus respectivos territórios, quando aplicada aos órgãos da União Federal e às demais unidades federadas, esvazia por completo o sentido da expressão "plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva", contida no texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Carta da República; o que por si só revela o seu equívoco (dessa interpretação), vez que, tal como a lei, a Constituição não contém palavras inúteis. Conforme Loureiro, "conquanto não tenha sido feliz a redação - que deixa na dúvida o alcance do termo 'respectivo' - a 'respectiva plataforma continental' não se refere a uma juridicamente impossível circunstância, mas está, simplesmente, a indicar a idéia precisa – que se perdeu ao longo do processo de elaboração da Constituição – de Estado/Município 'litorâneo' ou 'confrontante'"[58]. Até porque, como expressa Loureiro, nos documentos que retratam a deliberação político-parlamentar tendente à construção do texto desse dispositivo constitucional, "não aparece, em momento algum, intenção de uma partilha absoluta na plataforma continental"[59].

Essas considerações são suficientes a demonstrar, a par dos limites semânticos do texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que os *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás devem ser distribuídos exclusivamente, ou quando menos preponderantemente, às unidades federadas impactadas por essa atividade econômica. No entanto, para que não haja

[57] Cfr., a propósito: HESSE, Konrad. *A força normativa da constituição*. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: SAFE, 1991.

[58] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 171.

[59] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 171.

dúvidas sobre o encaminhamento que deve ser dado ao tema, recorrer-se-á, nos tópicos que se seguem, a duas fontes interpretativas da maior importância: a palavra dos autores da Constituição (*mens legislatoris*) e a interpretação correntemente atribuída ao dispositivo constitucional analisado pela doutrina jurídica e pelo Supremo Tribunal Federal, Corte a quem a Constituição conferiu a tarefa de interpretá-la e aplicá-la (*mens legis*).

2.2.1.2. Evolução da redação do parágrafo 1º de artigo 20 da Constituição no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte (*mens legislatoris*).

O professor Gustavo Kaercher Loureiro discorre sobre a evolução da redação dada pelos constituintes ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição ao longo do processo de deliberação da Assembléia Nacional Constituinte[60-61]. Como introdução a essa sua exposição, Loureiro apresenta uma síntese de como se processaram os trabalhos dos constituintes para chegar ao texto final da Carta de 1988; a saber:

> "Sem um texto básico comum de onde iniciar, o conjunto dos Constituintes/Congressistas foi organizado em oito grandes grupos temáticos, denominados Comissões, por sua vez subdivididos em três grupos de menor amplitude, as Subcomissões, dedicadas a temas específicos da grande área da respectiva Comissão. Cada uma delas, independentemente das demais, discutia e elaborava o seu respectivo texto, na área que lhe dizia respeito.
>
> No interior desses grupos, a ordem dos trabalhos era, grosso modo, a seguinte:
>
> 1.) texto proposto pelo relator da Subcomissão (Anteprojeto do Relator da Subcomissão);
>
> 2.) discussão e emendas ao texto proposto;
>
> 3.) Anteprojeto da Subcomissão, encaminhado à Comissão.
>
> Na Comissão a ordem era semelhante, finalizando-se com o Projeto da Comissão.
>
> Passada esta fase de dispersão, os textos todos foram levados à Comissão de Sistematização, relatada pelo Constituinte Bernardo Cabral. Ali a ordem era a seguinte:
>
> 1.) Anteprojeto de Constituição;
>
> 2.) discussões e emendas de mérito ao Anteprojeto;
>
> 3.) emendas de adequação ao Anteprojeto;
>
> 4.) Projeto de Constituição;

[60] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit.

[61] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 43-62, passim.

> 5.) Emendas de Plenário e Populares;
>
> 6.) Substitutivo 1 do Relator;
>
> 7.) Discussão e emendas ao Substitutivo 1;
>
> 8.) Substitutivo 2 do Relator.
>
> Apresentado tal Substitutivo 2, ia-se para o Plenário onde se discutiam e votavam três grandes propostas: (i.) o chamado 'Projeto A', que (ii.) dava origem ao 'Projeto B' que, por sua vez, (iii.) desembocava no 'Projeto C'. Este iria para a Comissão de Redação, para ajustes de correção do texto, do que resultava o Projeto D – este objeto, apenas, de votação.
>
> Esta, sucintamente, a ordem dos trabalhos e as fases pelas quais passaram as diferentes propostas, até a redação final do dispositivo"[62].

No caso específico do dispositivo analisado, Loureiro observa que os trabalhos se iniciaram na "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios e foram levados à Comissão da Organização do Estado"[63], e ressalta que o texto original apresentado pelo Relator da Subcomissão foi o seguinte:

> **Art. 3º** - Incluem-se entre os bens da União Federal:
>
> [...]
>
> **§ 1º** - É assegurada aos Estados e Municípios **litorâneos** a participação no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei complementar.
>
> **§ 2º** - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da lei complementar, a participação no resultado da exploração econômica dos recursos minerais do subsolo, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo (grifos do original)[64].

Loureiro destaca, já a partir dessa redação originária, a intenção dos constituintes de ampliar a "base imponível" das contraprestações pagas pela exploração de recursos naturais, já que o dispositivo projetado não se restringia apenas ao petróleo e ao gás natural, "mas fazia devida a 'participação' quando da 'exploração econômica da plataforma continental', assim como quando da 'exploração econômica dos recursos minerais do subsolo', com o que criava, também para a mineração, um *royalty* 'federativo'"[65]. E registra que a proposta não falava em indenização, como se colhe da

---

[62] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 152-153.

[63] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 154.

[64] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 154.

[65] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 154.

redação original do artigo 27 da Lei nº 2.004/1953[66], "mas em 'participação no resultado da exploração econômica', expressão mais ampla e genérica que evoca outras ideias que não, necessariamente, aquela de prejuízo"[67].

Com a continuação dos trabalhos no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte, três aspectos principais foram debatidos nas discussões que conduziram à redação atual do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição; a saber: (i) a necessidade da atribuição de recursos à União Federal; (ii) a necessidade de ampliação (para alguns), ou de redução (para outros), do rol de recursos naturais sujeitos ao pagamento de retribuições financeiras; e (iii) a inclusão de alternativa à participação no resultado, doravante qualificada como "compensação financeira"[68]. Mas, conforme Loureiro, "em momento algum [...] fugiu-se da ideia de beneficiar especificamente os Estados/Municípios afetados"[69].

Ainda no âmbito interno da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios", o parágrafo 2° do dispositivo projetado recebeu outra redação, proveniente da aprovação da Emenda 2A0089-4, de autoria do Senador Alfredo Campos, constituinte pelo Estado de Minas Gerais, apresentada em 17/05/1987. Loureiro ressalta que essa Emenda "incluía a expressão faltante (mas aparentemente subentendida) do 'respectivo território', e ampliava a base da incidência da participação, de 'recursos minerais do subsolo' para 'recursos naturais, renováveis ou não renováveis'"[70]. Assim, o Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios", doravante levado à "Comissão da Organização do Estado", que a abrangia, continha, quanto ao particular, o seguinte texto:

---

[66] Lei 2.004. "Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás".

[67] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 155.

[68] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.156.

[69] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.156.

[70] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.156.

> **Art. 3°** - Incluem-se entre os bens da União:
>
> [...]
>
> **§ 1°** - É **assegurada aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e patrimonial**, na forma prevista em lei complementar.
>
> **§ 2°** - É **assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**, nos termos da lei complementar, **a participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerais do subsolo, em seu território** (destaques pessoais)[71].

Esse texto foi acolhido pela "Comissão da Organização do Estado", que não lhe fez emendas ou propostas de alteração. De concreto, a única modificação depreendida nesse contexto foi que o dispositivo, no "Anteprojeto da Comissão", foi renumerado, tornando-se, por questão de adequação da redação, artigo 7º e parágrafo 1º e 2º[72].

A fase seguinte das deliberações da Assembléia Nacional Constituinte desenvolveu-se na "Comissão de Sistematização". Loureiro observa que nessa etapa "o texto sofreu ligeiras alterações (eliminou-se a exigência de lei complementar no § 1º) e foi renumerado para art. 48, §§ 1º e 2º"[73].

Na seqüência, foi elaborado o "Projeto de Constituição", também a encargo da "Comissão de Sistematização". Nessa fase, conforme Loureiro, "o texto ainda permaneceu como estava, tendo sido novamente renumerado, agora para art. 52, §§ 1º e 2º"[74].

Foi nessa etapa que ocorreram os debates sobre os três pontos citados anteriormente (atribuição de recursos à União Federal, ampliação/redução do rol de recursos naturais sujeitos ao pagamento de retribuições financeiras e inclusão da "compensação financeira" como alternativa à participação no resultado). Desses debates

---

[71] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.156.

[72] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.157.

[73] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.157.

[74] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.157.

sobressaem manifestações formais de constituintes que deixam claro que a inclusão desse dispositivo no texto da Constituição de 1988 tem por objetivo a compensação (ou indenização) das unidades federadas impactadas pelos reflexos da atividade de exploração de determinados recursos naturais sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações[75]. Essas manifestações foram colhidas pelo professor Gustavo Kaercher Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[76].

A propósito, cumpre referir ao posicionamento do parlamentar Prisco Viana, constituinte pelo Estado da Bahia, que obteve de seu pares a inclusão da Marinha do Brasil entre os beneficiários dos pagamentos pela exploração de recursos naturais na plataforma continental, pela via da inclusão da expressão "órgãos da administração direta da União" no parágrafo 1º do artigo 52 do "Projeto de Constituição"[77]. Ocorre que, o "Primeiro Substitutivo" do Relator, constituinte Bernardo Cabral, quando acolheu essa proposta defendida pelo constituinte Prisco Viana, modificou sensivelmente o texto do dispositivo[78], que passou a assumir a seguinte redação:

> **Art. 30** – Incluem-se entre os bens da União:
>
> [...]
>
> **§ 1º** - A lei disporá sobre a forma e condições de **participação, por instituições de direito público federais, estaduais e municipais, nos resultados da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais**, renováveis ou não, da plataforma continental e do mar territorial.
>
> **§ 2º** - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da lei, **participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerais em seu território** (destaques pessoais)[79].

Ao ensejo, Loureiro destaca que, sob essa redação, "apartavam-se mais as hipóteses (território/plataforma continental)". Em suas próprias palavras, "no caso de exploração da plataforma continental, os beneficiários eram genericamente

---

[75] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.157.

[76] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit.

[77] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.157.

[78] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

[79] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

indicados como 'instituições de direito público federais, estaduais e municipais', que participariam segundo 'forma e condições' estabelecidas em lei federal", ao passo que "para a exploração no território a Constituição garantia a participação dos Estados/Municípios diretamente interessados ('em seu território'), sem, inclusive, a participação da União"[80].

Mas essa redação não durou muito tempo[81]. Com efeito, o texto alterou-se novamente com o "Segundo Substitutivo" do mesmo Relator, passando a assumir a seguinte redação:

> **Art. 19** - Incluem-se entre os bens da União:
>
> [...]
>
> **§ 1º** - É **assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**, nos termos da lei, **participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, em seus territórios, bem como da plataforma continental e do mar territorial, respectivos** (destaques pessoais)[82].

Loureiro observa que essa nova redação promoveu um retorno à idéia original, estampada no Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios", que posteriormente foi acolhido pela "Comissão da Organização do Estado", e que foi reproduzido, na seqüência, no "Anteprojeto de Constituição" e no "Projeto de Constituição", ambos a encargo da "Comissão de Sistematização", no sentido de conferir "aos Estados e Municípios litorâneos a participação no resultado da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e patrimonial" (parágrafo 1º do artigo 3º da redação originária) e "aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios [...] a participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais [...] em seu território" (parágrafo 2º do artigo 3º da redação originária). Mas destaca que isso foi feito por meio da construção de um "texto único, que juntava as duas hipóteses de aproveitamento"[83].

---

[80] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

[81] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

[82] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

[83] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.159.

Essa modificação reforça a tese segundo a qual a compensação financeira deva ser direcionada exclusivamente aos Estados e Municípios impactados pela exploração de recursos naturais. É que, conforme Loureiro:

> "Para preservar a vinculação ao ente público diretamente interessado no caso de exploração fora do território, o Relator acrescentou um "respectivos" que claramente regia a "plataforma continental e mar territorial" (e não o território, eis que a vinculação, aí, já estava expressa: "aproveitamento de todos os recursos naturais, em seus territórios"). Conquanto juridicamente imprecisa – pois entes subnacionais não tinham plataforma continental e mar territorial, como se encarregaria de confirmar a própria Constituição – é compreensível a referência, que parece estar expressando a ideia de 'Estado/Município confrontante' ou 'adjacente'"[84].

A propósito, Loureiro destaca o debate travado entre os parlamentares Oswaldo Lima Filho, constituinte pelo Estado de Pernambuco, e Sandra Cavalcanti, constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro, que considera bastante ilustrativo para a compreensão do alcance do termo "respectivo" na redação atual do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição[85].

Oswaldo Lima Filho propunha a eliminação no dispositivo da referência à plataforma continental e da expressão "respectivos", e postulava um retorno ao sistema consagrado na primeira regra relativa a este problema, colhida do artigo 27 da Lei nº 2.004/1953, que previa o pagamento da compensação financeira apenas pelo petróleo e gás explorado em terra, embora admitindo a ampliação da sua base de incidência para abarcar também os "recursos minerais"[86]. Eis a proposta de redação apresentada por esse constituinte pernambucano:

> **Art. 19** [...]
>
> **§ 1º** - É assegurado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da lei, participação no resultado da exploração econômica dos recursos minerais, em seu território[87].

[84] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.160.

[85] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.160.

[86] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.160.

[87] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.160.

Sandra Cavalcanti critica essa proposição de Oswaldo Lima Filho, em especial no que se refere à exclusão da referência à plataforma continental, lembrando que a expressão "recurso mineral em território" não abarca, por exemplo, o petróleo e gás explorado *offshore* em todo o País[88]. Em suas palavras:

> "[...] os estados que não têm forma terrestre de exploração de petróleo ficariam fora da participação desta produção e de uma riqueza econômica que, no caso, por exemplo, do meu Estado, significa para nós uma riqueza importantíssima, uma vez que somos hoje, no Brasil, o Estado que mais produz petróleo, e que carrega sozinho com mais da metade da produção de petróleo e de gás natural"[89].

Como resultado dessa discussão, ficaram mantidos o termo "respectivos" e a referência à plataforma continental[90]. Mas, por lapso do Relator Bernardo Cabral, ainda não havia sido incorporado ao novo texto a participação da União Federal, concebida como forma de beneficiar a Marinha do Brasil, conforme anteriormente solicitado pelo constituinte Prisco Viana e devidamente acolhido pelo Relator no "Primeiro Substitutivo"[91-92].

Isso ensejou uma nova manifestação do constituinte Prisco Viana, reiterando a necessidade de se incluir a Marinha do Brasil no texto, sob a expressão "órgãos da administração direta da União"[93]. Loureiro destaca que Viana, nesse seu pronunciamento, "aproveita para observar a importância da positivação, na Constituição,

---

[88] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.160.

[89] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161.

[90] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161.

[91] Recobre-se, a propósito, a redação construída naquela oportunidade: "Art. 30 [...] § 1° - A lei disporá sobre a forma e condições de participação, por instituições de direito público federais, estaduais e municipais, nos resultados da exploração econômica e do aproveitamento dos recursos naturais, renováveis ou não, da plataforma continental e do mar territorial. § 2° - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos recursos minerais em seu território.

[92] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161.

[93] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161.

desse direito dos 'Estados e Municípios produtores'"[94]. Eis o teor da manifestação do parlamentar baiano, colhida por Loureiro do Diário da Assembléia Nacional Constituinte[95]:

> "Explico, Sr. Presidente: primeiro, o interesse de que conste do texto constitucional esse dispositivo.
>
> Votei aqui, no Congresso Nacional, pelo menos quatro projetos de lei tratando de regulamentação da indenização aos Estados e Municípios produtores de petróleo, na forma de *royalty*. O Executivo, por três vezes, vetou esta proposta por inconstitucional.
>
> De fato, a Constituição em vigor deixa dúvidas quanto a esse direito dos Estados e Municípios. **O que se quer, agora, é deixar bastante claro, bem definido, que esses Estados que pagam um alto preço pela exploração de petróleo em seus territórios, tenham esta indenização.**
>
> A lei atualmente em vigor, sancionada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente José Sarney, em fins do ano de 1985, estabelece a participação dos Estados, dos Municípios e da Marinha de Guerra do Brasil.
>
> O que pretendo com essa emenda é preservar a participação da Marinha de Guerra neste processo. (...).
>
> Portanto, o que venho pedir, neste instante, aos Srs. Constituintes da Comissão de Sistematização, é que aprovem a inserção desta expressão no texto do substitutivo: 'e órgãos da administração direta da União', por quem estaremos mantendo a situação que hoje tem a Marinha e garantindo a continuidade dos seus programas de reaparelhamento naval, técnico e científico" (grifos do original)[96].

Essa observação de Prisco Viana induziu a conclusão de Loureiro no sentido de que o objetivo desse dispositivo constitucional é retirar da avaliação discricionária da União Federal a atribuição (ou não) de retribuição financeira aos Estados e Municípios impactados pela exploração de petróleo e gás, entre outros recursos naturais, que até então permanecia à disposição do ente federal, que poderia ou não conferir-lhes, por lei, contraprestação pela exploração desses recursos naturais, por serem bens de sua titularidade[97]. Assim, como essa Emenda do constituinte Prisco Viana foi devidamente aprovada[98], não há razão para supor que à União Federal seja dado distribuir esses recursos a outros Estados e Municípios que não aqueles que sejam afetados pela exploração de recursos naturais.

---

[94] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161.

[95] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 13/05/1987, cit., p. 1.490.

[96] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

[97] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

[98] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

Muito mais debatida foi a segunda questão levantada no processo de discussão da redação do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, afeta à ampliação/redução do rol de recursos naturais sujeitos à retribuição. Esse debate, conforme Loureiro, "não só deu a oportunidade de reiterar o alcance da regra, que vinculava o benefício à área onde a produção ocorreria [...], mas também mostrava que tal ampliação da lista de bens estava relacionada com uma necessidade de resguardo da isonomia federativa"[99].

Quanto ao pormenor, o parlamentar José Lins, constituinte pelo Estado do Ceará, opunha-se ao que considerava um abuso do Estado, consistente na pretensão de auferir benefícios econômicos pela exploração de todos os recursos naturais do País[100]. Para José Lins, a retribuição financeira de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição deveria limitar-se à exploração de petróleo e gás; como se verifica do seguinte trecho da sua manifestação, destacado por Loureiro a partir do que restou assentado no Diário da Assembléia Nacional Constituinte[101]:

> "Ora, Sr. Presidente, isto significa que o Estado será sócio de todos os empreendimentos que digam respeito à exploração de riquezas de qualquer natureza em seus territórios. (...)
>
> Ora, Sr. Presidente, **o que se deseja, certamente, são os *royalties* que a Petrobrás pagará sobre o petróleo que extrair em determinados territórios ou sobre o gás natural que explorar na costa da Bahia ou do Rio de Janeiro.**
>
> Isso nada tem a ver com o texto do parágrafo. Este é um caso especial que foi objeto de uma lei própria para isso, ao passo que o parágrafo, tal como está redigido, estatizará todas as atividades extrativas ou exploratórias que se realizem dentro do território" (destaques pessoais)[102].

Dessa "fala" do constituinte José Lins sobressai que o que se desejava nas discussões empreendidas na Assembléia Nacional Constituinte acerca da elaboração do texto desse dispositivo constitucional era promover o pagamento de *royalties* sobre o produto da exploração de recursos naturais em determinados territórios e na costa de determinadas unidades federadas.

---

[99] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

[100] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.163.

[101] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.484.

[102] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

Também o parlamentar José Serra, constituinte pelo Estado de São Paulo, manifestou-se contra a amplitude da base econômica abrangida pelo dispositivo, que considerava excessiva[103]. Serra defendeu, então, na Assembléia Nacional Constituinte, a necessidade de se identificar precisamente o tipo de recurso natural ensejador do benefício, como se depreende do seguinte excerto, colhido por Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[104]:

> "Creio que este é o primeiro e bastante sério problema: estamos incluindo com este parágrafo na Constituição um dispositivo de extraordinária amplitude, porque assegura aos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos da lei é bem verdade, a participação nos resultados da exploração econômica e aproveitamento de todos os recursos naturais em seus territórios, da plataforma continental e da plataforma submarina.
>
> **Todos os recursos naturais!**
>
> **Estamos colocando isso numa Constituição e muitos dos companheiros Constituintes que aqui estão ficam pensando no petróleo, no Município que fica pauperizado a partir da exploração de certos recursos minerais e outros, como no caso dos companheiros do Paraná, em áreas inundadas dentro de seu Estado por hidrelétricas.**
>
> Só que através desse dispositivo, nós perpetuaremos uma possibilidade de cobrança de um quase tributo porque é um quase tributo - não é juridicamente mas é do ponto de vista econômico - a exploração de todos os recursos naturais renováveis e não-renováveis, inclusive da agricultura, da atmosfera, da atividade da pesca...
>
> Não obstante requerer lei, através de processos de negociação ao longo dos anos, nós podemos realmente estruturar todo um sistema tributário paralelo, sem a disciplina e sem os critérios que formam a organização do Sistema Tributário. Esta é a razão essencial da minha oposição a este artigo e esta é a razão pela qual venho aqui explicitar porque me parece um dever que essa posição seja explicitada (grifo no original)[105].

Por tais razões, Serra propôs nova redação para o dispositivo constitucional; a saber:

> **§1º** - Lei Complementar disporá sobre a forma e condições de participação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos resultados da exploração econômica das jazidas de petróleo e gás natural, localizada em seus territórios, inclusive na plataforma continental e no mar territorial[106].

---

[103] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

[104] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.488.

[105] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

[106] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.167.

A redação proposta por Serra ao dispositivo constitucional, e também a sua manifestação, colhida do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte", revelam que, mesmo para os que questionavam a ampliação da extensão da retribuição financeira em discussão, estava claro que essa retribuição paga a Estados e Municípios deve abarcar a exploração de recursos naturais (para Serra, só do petróleo e do gás natural) "em seus territórios, inclusive na plataforma continental e no mar territorial", como consta da literalidade do texto proposto, precisamente porque, como disse Serra, "muitos dos companheiros Constituintes que aqui estão ficam pensando no petróleo, no Município que fica pauperizado a partir da exploração de certos recursos minerais e outros, como no caso dos companheiros do Paraná, em áreas inundadas dentro de seu Estado por hidrelétricas".

A crítica de José Lins e de José Serra foi rebatida pelo parlamentar Pimenta da Veiga, constituinte pelo Estado de Minas Gerais, que defendeu na Assembléia Nacional Constituinte uma efetiva distribuição de rendas aos diferentes entes federativos, segundo as suas peculiaridades, ou seja, segundo as suas respectivas riquezas[107]. Para Pimenta da Veiga, o benefício específico do petróleo aos Estados e Municípios produtores, que então passava a ser encampado pela Constituição, deveria ser alargado para outros recursos naturais, de modo a espraiar riqueza[108]. Confira-se, a propósito, a literalidade da sua manifestação quanto a esse particular, colhida por Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[109]:

> "Não socorre razão ao Constituinte José Lins. **O que se pretende apenas é proteger o interesse do Município e do Estado contra uma injusta espoliação que ocorre hoje, quando suas riquezas são retiradas, não ficando ao Estado e ao Município pouco mais do que nada.** [...]
>
> Não é apenas essa a situação de Minas Gerais, mas é de grande interesse a manutenção do texto do relator, pois garante o direito, além de Minas Gerais, do Pará, do Maranhão, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, especialmente dos Estados produtores de petróleo, a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, para não dizer daqueles que têm grandes extensões alagadas por usinas hidrelétricas, como o Paraná e novamente Minas Gerais (destaques pessoais)"[110].

[107] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

[108] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

[109] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.484.

[110] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

Loureiro extrai desses pronunciamentos que os constituintes não cogitaram de instituir participação igualitária a todos os entes da Federação na exploração de petróleo e gás, mas de ampliar o rol dos recursos naturais ensejadores do benefício, para alcançar o maior número possível de Estados e Municípios da Federação[111]. Prova disso é que as propostas restritivas formuladas nessa fase, manifestadas pelos parlamentares José Lins e José Serra, entre outros, foram rejeitadas pela maioria que se formou na Assembléia Nacional Constituinte[112]. Com efeito, a única proposta aprovada nessa etapa foi a do constituinte Prisco Viana[113], que, como já exposto, pugnava pela inclusão da expressão "órgãos da administração direta da União" entre os destinatários das retribuições financeiras concebidas pelo dispositivo, como o objetivo específico de remunerar a Marinha do Brasil pelo policiamento marítimo nas áreas de exploração de petróleo e gás no litoral brasileiro[114-115].

Com isso, o "Projeto A de Constituição", ainda relatado pelo constituinte Bernardo Cabral, apresentou o dispositivo constitucional analisado sob a seguinte redação:

> **Art. 22** – Incluem-se entre os bens da União [...]
>
> **§ 1°** - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da Administração Direta da União, nos termos da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais **em seus territórios**, bem como na plataforma continental e no mar territorial **respectivos** (destaques pessoais)[116].

A propósito, merece destaque que esse texto deixava bastante clara a opinião dos constituintes no sentido de que as retribuições financeiras tratadas no dispositivo decorrem da exploração de recursos naturais não apenas no território, mas também na plataforma continental e no mar territorial correspondentes a esse território.

---

[111] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.165.

[112] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.165.

[113] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.165.

[114] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 13/05/1987, cit., p. 1.490.

[115] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

[116] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.165.

Tal se infere, sem maiores dificuldades, da utilização, no dispositivo, de fórmula semântica pouco usual, e talvez desnecessária, consistente na utilização, ao final do período, da expressão "respectivos".

Adiante, o parlamentar Renato Johnsson, constituinte pelo Estado do Paraná, apresentou a Proposta de Emenda 2P00963-8, que, conforme Loureiro, "estabelecia uma articulada ordenação de diferentes hipóteses de exploração de (diferentes) recursos naturais, que ensejavam diferentes retornos econômicos, mais precisamente, 'participações' e 'compensações', conforme o caso"[117]. Eis a proposta de redação apresentada pelo constituinte paranaense:

> **Art. 22** – Incluem-se entre os bens da União: (...)
>
> **§ 1º** – É assegurada, na forma da lei, à União ou a órgão de sua administração direta, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado da exploração econômica de petróleo e de gás natural em seus territórios, bem como de recursos minerais da plataforma continental e da zona econômica que lhes corresponda.
>
> **§ 2º** – É assegurada, na forma da lei, compensação financeira, aos Estados e Municípios cujos territórios forem afetados pela utilização de recursos naturais para fins de geração de energia elétrica.
>
> **§ 3º** – A União transferirá aos Estados e Municípios afetados os recursos financeiros que a ela couberem a título de compensação em aproveitamentos de recursos hídricos realizados por acordos internacionais"[118].

Renato Jonhsson justificou essa sua proposta por meio da seguinte manifestação, colhida por Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[119]:

> "A redação dada pelo §. 1º do Projeto é excessivamente abrangente pois engloba todos os recursos naturais.
>
> Assim a nova redação preserva no seu § 1º a participação financeira no resultado da exploração econômica do petróleo e nos §§ 2º e 3º contempla compensação financeira pela exploração econômica dos recursos naturais para fim de energia elétrica.
>
> **As unidades da Federação e os Municípios devem auferir uma renda a título de compensação pelo uso de recursos naturais** para a produção de eletricidade, que frequentemente é consumida e utilizada em grande medida fora de seus limites. A emenda procura assegurar que o aproveitamento de recursos naturais beneficie efetivamente e mais amplamente as Unidades da Federação e os Municípios onde eles se localizam. **Os recursos naturais integram o conjunto de fatores produtivos no qual se deve apoiar o processo de desenvolvimento econômico e social das comunidades. A receita**

[117] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.165.

[118] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 166.

[119] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., 08/03/88, p. 8.068.

> **correspondente a essa compensação propiciará recursos financeiros aos Municípios e às Unidades da Federação** – para projetos de desenvolvimento – **cujos recursos naturais deixam de propiciar, plenamente, os benefícios ao desenvolvimento das comunidades em que eles se localizam**" (destaques pessoais)[120].

Em síntese, Renato Jonhsson postula a extensão da retribuição financeira projetada pelo dispositivo constitucional analisado também à utilização de recursos hídricos para a produção de energia elétrica. Essa sua manifestação reforça a tese de que era assente na Assembléia Nacional Constituinte a noção segundo a qual a retribuição financeira de que trata o dispositivo constitucional analisado tem por finalidade compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pela exploração de determinados recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. E isso porque, nas palavras do constituinte paranaense, "as unidades da Federação e os Municípios devem auferir uma renda a título de compensação pelo uso de recursos naturais", porque "os recursos naturais integram o conjunto de fatores produtivos no qual se deve apoiar o processo de desenvolvimento econômico e social das comunidades", de modo que "a receita correspondente a essa compensação propiciará recursos financeiros aos Municípios e às Unidades da Federação – para projetos de desenvolvimento – cujos recursos naturais deixam de propiciar, plenamente, os benefícios ao desenvolvimento das comunidades em que eles se localizam".

A proposta, como se sabe, acabou acolhida pela Assembléia Nacional Constituinte, o que se demonstra pela circunstância de o texto atual do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição também atribuir retribuição financeira pela exploração de recursos hídricos para a produção de energia elétrica e prever, ao lado da "participação no resultado", o pagamento de "compensação financeira" pela exploração de recursos naturais. Mas o texto inicial construído após essa intervenção do constituinte Renato Jonhsson tinha redação diferente, embora muita próxima da sua conformação atual; a saber:

> **Art. 22** [...]
>
> **§ 1º** – É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da administração direta da União, compensação financeira ou participação no resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de petróleo ou gás natural e de outros recursos minerais **em**

[120] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.166.

> **seus territórios**, bem como na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva **respectivos**[121]. (grifou-se)

Fica mantido, aqui, o mesmo sentido da redação anterior acolhida nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, que constava do "Projeto A de Constituição", e que dispunha ser "assegurada aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e órgãos da Administração Direta da União, nos termos da lei, participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais em seus territórios, bem como na plataforma continental e no mar territorial respectivos".

No entanto, quando da elaboração do "Projeto B de Constituição" o texto do dispositivo constitucional analisado sofreu pequenas modificações, que se relacionam exclusivamente a aspectos semânticos, em especial o deslocamento da expressão "respectivo" do final para o meio da frase, passando a assumir, assim, a seguinte redação:

> **Art. 20** – São bens da União [...]
>
> **§1°** É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

Esse foi, como se sabe, o texto que prevaleceu na redação final da Constituição de 1988, e que foi estampado no parágrafo 1º de seu artigo 20, donde se infere que não ocorreram novas modificações nas etapas subseqüentes (construção do "Projeto C" pela "Comissão de Sistematização" e do "Projeto D" pela "Comissão de Redação", assim como da votação do texto em Plenário). Loureiro expressa que com essas modificações "estavam criadas as condições para futuras dificuldades hermenêuticas em torno do § 1º do art. 20 da Constituição, causadas, sobretudo, por 'migrações' e deslocamentos do termo 'respectivo' que acabou finalmente sendo arranjado de modo diferente e menos preso à hipótese que, aí, explicitamente regulava (plataforma continental e mar territorial)"[122]. No entanto, não se pode interpretá-lo à

[121] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.167.

[122] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 156.

desconsideração da vontade dos constituintes (*mens legislatoris*), expressada nas manifestações dantes referidas, proferidas pelos parlamentares Prisco Viana, Oswaldo Lima Filho, Sandra Cavalcanti, José Lins, José Serra e Renato Johnsson, todas elas colhidas pelo professor Gustavo Kaercher Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[123].

Essas manifestações, e também a evolução do texto construído pelos constituintes ao longo das suas deliberações sobre o tema, revelam que a intenção do legislador (*mens legislatoris*) era compensar (ou indenizar), de alguma forma, os Estados e Municípios impactados pela exploração de determinados recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. É o que se verifica, com muita nitidez, dessa outra manifestação encontrada por Loureiro no "Diário da Assembléia Nacional Constituinte"[124], formulada pelo parlamentar Sérgio Spada, constituinte pelo Estado do Paraná:

> "A Assembléia Nacional Constituinte, na semana passada, historicamente corrigiu uma injustiça que vinha sendo cometida há muito tempo contra Estados produtores de energia elétrica e contra Estados fornecedores de matéria prima, mais especificamente o minério.
>
> Venho do Estado do Estado do Paraná, onde constatei, com os próprios olhos, perante a população do Estado, o seu reconhecimento a **essa votação histórica que ocorreu na semana passada, onde ficou definido que ficará assegurada, na futura Constituição, através do seu próprio texto, uma compensação financeira pelos danos, pelos prejuízos que esses Estados**, como é o caso de Paraná, de Minas Gerais, do Pará e da Bahia **que perdem inúmeros quilômetros quadrados de terra e recebem como herança as crateras pela exploração do minério**" (destaques pessoais)[125].

Também resta evidente da evolução das deliberações da Assembléia Nacional Constituinte quando da construção do texto do dispositivo constitucional analisado que essa retribuição financeira paga a Estados e Municípios não se repousa exclusivamente sobre a exploração de recursos naturais em seus territórios, mas também abarca a atividade extrativista empreendida na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva correspondente a esse território. Tal se

---

[123] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit.

[124] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., vol. 1, Suplemento C, p. 1.091.

[125] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.167.

infere, sem maiores dificuldades, da redação que lhe foi conferida pelos constituintes após a integração ao texto do dispositivo da Emenda apresentada pelo constituinte Renato Johnsson, que dispunha que "é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da administração direta da União, compensação financeira ou participação no resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de petróleo ou gás natural e de outros recursos minerais em seus territórios, bem como na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva respectivos". É que, a rigor, a redação final dada ao dispositivo, constante do "Projeto B de Constituição", que acabou mantida no "Projeto C", e também no "Projeto D", aprovado pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, apenas corporifica o transporte da expressão "respectivo" do final para o meio da frase; como se percebe da comparação entre os seus textos:

TEXTO QUE RESULTOU DA DISCUSSÃO NA A.N.C.	**TEXTO DO "PROJETO B DE CONSTITUIÇÃO"**
É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a órgãos da administração direta da União, compensação financeira ou participação no resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de petróleo ou gás natural e de outros recursos minerais **em seus territórios**, bem como na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva **respectivos**.	É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no **respectivo** território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

Semelhante alteração de forma no texto do dispositivo constitucional analisado não tem o condão de modificar a interpretação autêntica que lhe foi conferida pelos próprios constituintes. Do contrário, estar-se-ia a derrogar a expressão máxima da soberania popular, estampada no Preâmbulo da Constituição, de que o poder constituinte emana do povo, que esteve representado, quando da elaboração da Carta Política de 1988, por parlamentares eleitos nos seus respectivos Estados, então "reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias".

Mesmo que assim não fosse, idêntica conclusão decorre da circunstância de a retribuição financeira de que trata o dispositivo analisado fundar-se, para os constituintes, na afetação dos Estados e Municípios pelo exercício de atividades de exploração de recursos naturais em benefício da União Federal. Fincada essa premissa, e considerando que a exploração de recursos naturais, em especial do petróleo e do gás natural, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva tem a potencialidade de afetar as contas públicas de Estados e Municípios e o modo de vida de suas respectivas populações[126], é evidente que a intenção dos constituintes foi no sentido de retribuí-los também pela exploração de recursos naturais fora dos seus respectivos territórios, isto é, na plataforma continental correspondente a esses territórios, no mar territorial correspondente a esses territórios e na zona econômica exclusiva correspondente a esses territórios.

2.2.1.3. Interpretação correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição (*mens legis*).

Não refuta essa conclusão o argumento segundo o qual a circunstância de o petróleo e o gás serem propriedade da União Federal (CRFB, art. 20, V, VIII, IX e X[127]), e não dos Estados e Municípios, desnaturaria a tese vinculação das contraprestações financeiras devidas pela sua exploração aos Estados e Municípios produtores[128]. A propósito, o professor Gustavo Kaercher Loureiro leciona que "ainda que o bem seja da União, os benefícios econômicos que advêm de sua exploração por terceiros (privados), não são apropriáveis exclusivamente por ela – seja na forma de

[126] Nesse sentido se posicional Kiyoshi Harada, quando assevera, em sede doutrinária, que a retribuição financeira de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição é devida "mesmo em se tratando de extração de petróleo ou gás natural, do mar territorial ou da plataforma continental", pois "sempre haverá instalações marítimas ou terrestres, de embarque ou desembarque" (HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 52). Outro não é o entendimento de Regis Fernandes de Oliveira, quando se refere, em doutrina, à compensação financeira relativa "às explorações feitas no mar territorial e na zona econômica exclusiva", com relação às quais considera "irrelevante que a lei não disponha a respeito, uma vez que o §1º da art. 20 da Constituição Federal não faz exceção" (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Curso de direito financeiro*, cit., p. 212).

[127] CRFB. "Art. 20. São bens da União: [...] V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; [...] VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos".

[128] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 62-80, passim.

'participação', seja na forma de 'compensação' - em razão de quanto se encontra disposto na norma do § 1º do art. 20 da Constituição"[129]. Conforme Loureiro a afirmação de que o petróleo é propriedade da União Federal "pouco ajuda a resolver a questão", porque "a propriedade da riqueza mineral não é nem pressuposto do recebimento (exclusivo) de rendas nem, aparentemente, dá um 'direito maior' ao seu *dominus*", de modo que "nesse arranjo que pode ser considerado *sui generis*, a propriedade federal parece servir, sobretudo, para legitimar uma ação de conformação setorial (normativa/fiscalizadora) do ente central, mas não uma sua maior participação no resultado da respectiva exploração"[130].

Nesse mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao ensejo, confira-se, a título de exemplo, o julgamento do Mandado de Segurança nº 24.312/DF, relatado pela Ministra Ellen Gracie. Na oportunidade, o Tribunal Constitucional assentou que, muito embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União Federal, as participações governamentais de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição são receitas originárias dos Estados (inclusive do Distrito Federal) e dos Municípios[131]. Confira-se a Ementa do julgamento:

> MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. **EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU RESULTADO**, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, **ART. 20, § 1º**. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 - Não tendo sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de Contas da União que autoriza a realização de auditorias nos municípios e Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF. 2 - **Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União** (CF, art.

[129] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 169.

[130] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.169.

[131] A propósito, Kiyoshi Harada leciona que as "receitas originárias são aquelas que resultam da atuação do Estado, sob o regime de direito privado, na exploração de atividade econômica", ou seja, "as resultantes do domínio privado do Estado" (HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 35), ao passo que as receitas derivadas decorrem do "*jus imperii* do Estado, que lhe faculta impor sobre as relações econômicas praticadas pelos particulares, assim como sobre seus bens, o tributo que, na atualidade, se constitui em principal fonte da receita pública" (HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 42-43). Conforme Roberto Wagner Lima Nogueira, são exemplos de receitas originárias as doações, os bens vacantes, a prescrição aquisitiva, o preço público, os ingressos comerciais (p. ex.: correios e loterias), e também a "compensação financeira na forma do art. 20, §1° da Constituição Federal" (NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. *Direito financeiro e justiça tributária.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 95).

> 20, V e IX), **a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos** (CF, art. 20, § 1º). 3 - É inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI da Carta Magna que se refere, especificamente, ao repasse efetuado pela União - mediante convênio, acordo ou ajuste - de recursos originariamente federais. 4 - Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, abandonado para participar das razões prevalecentes. 5 - Segurança concedida e, ainda, declarada a inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e 198, inc. III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991 (STF. MS 24312/DF. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 19/02/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 19-12-2003, PP-00050, EMENT VOL-02137-02 PP-00350) (destaques pessoais).

Demais disso, conforme entendimento há muito consolidado na jurisprudência do Excelso Pretório, a previsão constitucional quanto à distribuição a Estados e Municípios dessas participações governamentais não tem por fundamento a hipotética propriedade dessas unidades federadas sobre o produto extraído, mas, a rigor, a necessidade de compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pela exploração de determinados recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações, ou seja, de atribuir a essas unidades federadas a necessária contraprestação pelos riscos e pelos custos inerentes à atividade extrativista.

Assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 228.800/DF; cuja Ementa resta vazada nos seguintes termos:

> **Bens da União**: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica): **participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por sua exploração** (CF, art. 20, e § 1º): **natureza jurídica**: constitucionalidade da legislação de regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90). 1. O tratar-se de prestação pecuniária compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo da **participação nos resultados** ou da **compensação financeira** previstas **no art. 20, § 1º, CF**, que **configuram receita patrimonial**. 2. A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de "compensação financeira pela exploração de recursos minerais" (CFEM) não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; não obstante, **é constitucional, por amoldar-se à alternativa de "participação no produto da exploração" dos aludidos recursos minerais**, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição (STF. RE 228800/DF. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 16-11-2001, PP-00021, EMENT VOL-02052-03 PP-00471) (destaques pessoais).

Nesse julgamento, a Corte Suprema procurou determinar a natureza jurídica da "Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais", comumente designada como CFEM. Na oportunidade, o Tribunal identificou a CFEM com

as retribuições financeiras disciplinadas pelo parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, dispondo, a propósito, que essa retribuição, dada a sua destinação constitucional, não tem natureza tributária, mas de simples receita patrimonial (ou originária), e que a sua cobrança é constitucional, porque se amolda ao conceito de "participação no produto da exploração dos aludidos recursos minerais". Em seu Voto, o Ministro Sepúlveda Pertence, Relator do processo, assentou que **essa "compensação financeira se vincula** [...] **não à exploração em si, mas aos problemas que gera", vez que "a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente ambientais** [...], **sociais e econômicos, advindos do crescimento da população e da demanda por serviços públicos".** Em referência a esse julgamento, Romeu Thomé observa que o Tribunal Constitucional, na oportunidade, "abraçou a tese segundo a qual a natureza jurídica da CFEM, também designada *royalty ad valorem,* é indenizatória"[132].

Outro não foi o posicionamento externado mais recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 453.025/DF. Eis, em literalidade, o que consta da emenda do julgado:

> Agravo de instrumento. 2. **Compensação financeira pela exploração de recursos minerais**. 3. Leis 7.990/89 e 8.001/90. Constitucionalidade. Arts. 20, § 1º, 154, I, e 155, § 3º, da CF. Precedentes: RE 228.800 e MS 24.312. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STF. AI 453025 AgR/DF. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 09/05/2006. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 09-06-2006, PP-00028, EMENT VOL-02236-04, PP-00646, RTJ VOL-00201-01 PP-00367) (destaques pessoais).

Nesse julgamento, o Tribunal Constitucional reconheceu a constitucionalidade de dispositivos das Leis nº 7.990/89[133] e 8.001/90[134], por considerá-los compatíveis com as disposições constitucionais atinentes à distribuição aos Estados e Municípios produtores dos recursos financeiros advindos à exploração de recursos

[132] THOMÉ, Romeu. *A função socioambiental da CFEM (compensação financeira por exploração de recursos minerais).* In: Revista de direito ambiental. São Paulo, ano 14, n. 55, jul./set. 2009. p. 180-181.

[133] Que "institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF)".

[134] Que "define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências".

naturais, colhidas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Na oportunidade, o Relator do processo, Ministro Gilmar Mendes, firmou posicionamento no sentido de que "**a causa à compensação não é a propriedade do bem, pertencente exclusivamente à União, mas sim a sua exploração e o dano por ela causado**". Nessa ocasião, aderiram a esse posicionamento firmado pelo Ministro Gilmar Mendes os Ministros Celso de Mello, Joaquim Barbosa e Eros Graus, que com ele compunham a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Também a Primeira Turma do Excelso Pretório manifestou-se, muito recentemente, pela natureza patrimonial da CFEM, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 381.830/DF; que segue assim ementado:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como objetivo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a chegar-se a exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS - NATUREZA. O que previsto no artigo 20, § 1º, da Constituição Federal não consubstancia tributo, estando alcançado pelo gênero indenização** (STF. RE 381830/DF. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 23/08/2011. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011. EMENT VOL-02587-01 PP-00051) (destaques pessoais).

Em seu Voto, o Ministro Marco Aurélio, relator do processo, reportou-se ao posicionamento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 453.025/DF, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, e também ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 228.800/DF, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, ambos referidos anteriormente, dos quais se extrai que a previsão constitucional quanto à distribuição a Estados e Municípios das participações governamentais de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição tem por fundamento a necessidade de compensar os Estados e Municípios impactados pela exploração de determinados recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações, isto é de atribuir a essas unidades federadas a necessária contraprestação pelos riscos e pelos custos inerentes à atividade extrativista. Além disso, quando reconheceu semelhante finalidade às referidas

retribuições financeiras, qualificou-as textualmente como indenização; como vinha fazendo a legislação infraconstitucional desde a redação originária do artigo 27 da Lei nº 2.004/1953[135] até a redação dada pela Lei nº 8.001/1990 ao artigo 8º da Lei nº 7.990/1989[136].

Nesse julgamento, acompanharam o posicionamento do Ministro Marco Aurélio a Ministra Carmen Lúcia e os Ministros Dias Tóffoli e Luiz Fux. Assim, **pelo menos sete Ministros entre os atualmente integram o Supremo Tribunal Federal já votaram no sentido de que a retribuição financeira prevista no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição destina-se compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pela exploração de recursos naturais pelos riscos e pelos custos inerentes a essa atividade econômica**; a saber: Celso de Mello (AI 453.025-AgR/DF), Gilmar Mendes (AI 453.025-AgR/DF), Joaquim Barbosa (AI 453.025-AgR/DF), Marco Aurélio (RE 381.830/DF), Carmen Lúcia (RE 381.830/DF), Dias Tóffoli (RE 381.830/DF) e Luiz Fux (RE 381.830/DF).

Não há dúvidas sobre ser essa interpretação aplicável aos *royalties* e participações especiais devidos aos Estados e Municípios pela exploração de petróleo e gás. Afinal, a instituição, por lei, dessas participações governamentais, assim como da CFEM, tem por fundamento o disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal assim o reconheceu nesse último julgamento, cuja Ementa relaciona a esse dispositivo constitucional não apenas à CFEM, mas também às compensações financeiras pela exploração de petróleo, gás natural e recursos hídricos[137].

---

[135] Lei 2.004. "Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, *indenização* correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás"

[136] Lei 7.990. "Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da *indenização* pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal".

[137] Eis, em literalidade, o que consta, a esse respeito, na ementa do julgamento: "COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS – NATUREZA. O que previsto no artigo 20, § 1º, da Constituição Federal não consubstancia tributo, estando alcançado pelo gênero indenização".

Disso decorre a observação do jurista Luís Roberto Barroso, em parecer elaborado em resposta a consulta que lhe foi formulada pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que, "na linha da clara posição do STF [...] o direito a *royalties* não decorre quer da propriedade do recurso — que sempre é da União — quer da titularidade direta da área de produção, mas da circunstância de o estado e o município estarem na esfera de impacto ambiental e socioeconômico da atividade, por se tratar de seu território ou por serem confrontantes da área de exploração"[138].

Também a doutrina jurídica é taxativa ao afirmar que a distribuição das participações governamentais de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição não se relaciona à propriedade do bem, mas, verdadeiramente, à opção do constituinte por compensar os Estados e Municípios produtores pelos riscos assumidos e pelos ônus suportados.

Conforme José Afonso da Silva, a participação no resultado da exploração dos recursos naturais tem "sentido compensador", e "é **prevista exatamente porque a exploração no território traz ônus, encargos, exigências de serviços por parte da entidade beneficiada**"[139]. Ricardo Lobo Torres, de seu turno, leciona que a distribuição de tais receitas aos Estados e Municípios produtores justifica-se "como **contraprestação pelas despesas que as empresas exploradoras de recursos naturais causam aos poderes públicos, que se vêem na contingência de garantir a infraestrutura de bens e serviços e assistência às populações envolvidas em atividades econômicas de grande porte**"[140]. Romeu Thomé, de igual modo, acentua que o objetivo do repasse de contraprestação financeira por exploração de recursos naturais aos Estados e Municípios "não é simplesmente participá-los economicamente (visão estritamente econômica, superada no atual estado sócio-ambiental de Direito), mas, sobretudo, **compensá-los pelos impactos ambientais e**

[138] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo.* Parecer. Disponível na internet: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/royalties_do_petroleo.pdf>; acesso em 02 de dezembro de 2010. p. 18.

[139] SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição.* São Paulo: Malheiros, 2005. p. 258-258.

[140] TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário.* Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 191.

sociais advindos da exploração mineral em seus territórios"[141]. Tais premissas orientam a conclusão de Barroso no sentido de que, "**se a participação/compensação é devida em razão dos ônus suportados pelos estados-membros em decorrência de uma atividade econômica de interesse da União, parece claro que tal participação só será devida aos entes que, de fato, sofram essas conseqüências**"[142].

Conclusões semelhantes são extraídas do magistério de Kiyoshi Harada. Para o professor paulista "a verdade é que **essa compensação veio à luz como sucedâneo da difícil e inconveniente participação das entidades políticas no resultado da exploração de bens e recursos hídricos ou minerais pertencentes a uma delas**, ou seja, à União"[143]. Harada leciona, ainda, que essa compensação financeira, "**em relação às entidades políticas não titulares dos recursos naturais, tem uma natureza contraprestacional**", pois "**não há como negar que a exploração de recursos naturais**, que se caracteriza como atividade de grande porte, **obriga os poderes públicos a efetuar investimentos maciços na formação de completa infraestrutura material e pessoal, capaz de suportar as movimentações de bens e pessoas dela decorrentes**"[144]. Com efeito, "**notadamente o poder público local é obrigado a manter um programa ou serviço de assistência à população direta ou indiretamente envolvida na atividade econômica da espécie**"[145], como expressa Harada na seqüência.

Nesse mesmo sentido se posiciona Regis Fernandes de Oliveira, que destaca a propriedade da União Federal sobre os recursos naturais do subsolo e da plataforma continental, mas adverte que, ao lado de se encontrar a jazida no Estado Federal, ela também se situa em um determinado Estado, e dentro de um determinado Município, de modo que "os três entes federais repartem o resultado da exploração"[146].

---

[141] THOMÉ, Romeu. *A função socioambiental da CFEM (compensação financeira por exploração de recursos minerais)*, cit., p. 183.

[142] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 18.

[143] HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 54.

[144] HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 55.

[145] HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 55.

[146] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Curso de direito financeiro*, cit., p. 219.

Oliveira afirma que "***a compensação* advém do dano possível ou real que o ente federativo possa sofrer", pois "em virtude das obras para a exploração de energia elétrica ou de qualquer exploração mineral, incluindo petróleo e gás natural, decorrem danos momentâneos ou permanentes**", reportando-se, a propósito, à "destruição ambiental, movimentação de veículos, colocação de postes ou estruturas metálicas de qualquer natureza, movimentação de terras, possível poluição ambiental", que geram prejuízos, e que por isso devem ser indenizados[147]; indenização que decorre "não de comportamento infracional, de ato ilícito ou de conduta ilegítima que ocasione dano", mas "de comportamento plenamente legítimo, quando é cabível a atuação, mas, em decorrência dele, há dano a alguém"[148].

Também refere ao caráter indenizatório, ou contraprestacional, da retribuição financeira de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição o professor Roberto Wagner Lima Nogueira, que dispõe, textualmente, que essa receita pública tem natureza de indenização, e que "pode ser vista [...] como uma **contraprestação pelas despesas que as empresas exploradoras de recursos naturais, causam aos poderes públicos, que se vêem na contingência de garantir a infraestrutura de bens e serviços, e a assistência às populações envolvidas em atividades econômicas de grande porte**, *e.g.*, no Rio de Janeiro, os municípios de Campos e Macaé"[149]. Por isso é que, conforme Nogueira, "as leis 7.990/1989, 8.001/1990 e 9.993/2000, dispõem, respectivamente, sobre a exploração de recursos energéticos e compensação financeira, e ainda, sobre os percentuais da distribuição da compensação, rateando-os entre os Estados, Municípios, Ministério da Marinha e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT"[150].

Vê-se, pois, que tanto a doutrina jurídica quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que as participações governamentais de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição têm por finalidade a compensação (ou indenização) dos Estados e Municípios impactados pela exploração de petróleo e gás pelos reflexos dessa atividade econômica sobre suas contas

[147] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Curso de direito financeiro*, cit., p. 219.

[148] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Curso de direito financeiro*, cit., p. 217.

[149] NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. *Direito financeiro e justiça tributária*, cit., p. 96.

[150] NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. *Direito financeiro e justiça tributária*, cit., p. 96.

públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. Enfim, essas retribuições financeiras destinam-se a cobrir os riscos e custos inerentes à atividade de exploração de recursos naturais, entre eles o petróleo e o gás natural.

Tendo em vista especificamente a exploração de petróleo e gás, Barroso considera pertinente que se faça, ainda, uma interpretação histórica do dispositivo, dispondo, a propósito, que "quando o constituinte de 1988 decidiu trazer para a Constituição a matriz da disciplina dos *royalties*, eles já eram tratados pela legislação ordinária desde 1953, quando promulgada a lei de criação da Petrobras"[151]. Quanto ao particular, o professor fluminense recobra, em apertada síntese[152]:

> **(a)** que a obrigação de "compensar" Estados e Municípios produtores pela exploração de petróleo e gás natural existe desde o começo da indústria petrolífera no Brasil, pois o artigo 27 da Lei nº 2.004/1953[153] impunha àquela empresa estatal o pagamento aos Estados, aos Territórios e aos Municípios onde ocorresse a lavra de petróleo e gás o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do produto explorado[154];
>
> **(b)** que na década de 1980, com o início da exploração marítima do petróleo e gás, a Lei nº 7.453/1985 previu o pagamento dessa "compensação" também quando o óleo ou o gás natural fossem extraídos da plataforma continental, o que passou a ser feito não apenas com relação aos Estados e Municípios confrontantes com

[151] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 13.

[152] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 07-10.

[153] Lei 2.004. "Art. 27 - A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás".

[154] Conforme Barroso, "nos termos do art. 27, § 3°, da Lei nº 2.004/53, o pagamento era feito diretamente aos Estados e Territórios, que deveriam repassar 20% do valor aos Municípios produtores, proporcionalmente à produção de cada um. Posteriormente, a Lei nº 3.257/57 alterou o dispositivo para determinar que o pagamento fosse feito diretamente aos Municípios, sem intermediação" (BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 07- nota de rodapé).

os poços produtores, mas também aos Municípios integrantes da área geoeconômica dos Municípios confrontantes[155], qualificados pela Lei nº 7.525/1986 como Municípios contíguos que suportassem as conseqüências sociais ou econômicas da produção e exploração de petróleo e gás[156];

(c) que a matéria ganhou tratamento constitucional com a promulgação da Carta de 1988, que assegurou às unidades federadas afetadas pela indústria de petróleo, gás natural e outros recursos naturais pertencentes à União a participação no resultado da exploração desse recurso natural ou compensação financeira pelo exercício dessa atividade econômica, como se depreende do texto do parágrafo 1º de seu artigo 20[157];

[155] Lei 7.453. "Art. 1° - O artigo 27 e seus parágrafos da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei nº 3.257, de 2 de setembro de 1957, passam a vigorar com a seguinte redação: [...] § 4°. É também devida a indenização aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Territórios; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios e suas respectivas áreas geo-econômicas, 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas, e 1% (um por cento) para constituir um Fundo Especial a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios".

[156] Lei 7.525. "Art. 4° - Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 (uma) zona de produção secundária e 1 (uma) zona limítrofe à zona de produção principal. § 1°. Considera-se como zona de produção principal de uma dada área de produção petrolífera marítima, o Município confrontante e os Municípios onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações dos seguintes tipos: I – instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, excluindo os dutos; II - instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo e gás natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, armazéns e escritórios. § 2°. Consideram-se como zona de produção secundária os Municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão e bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, até o final do trecho que serve exclusivamente ao escoamento da produção de uma dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para fins de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição secundários, feitos com outras finalidades. § 3°. Consideram-se como zona limítrofe à de produção principal os Municípios contíguos aos Municípios que a integram, bem como os Municípios que sofram as conseqüências sociais ou econômicas da produção ou exploração do petróleo ou do gás natural".

[157] CRFB. "Art. 20 [...] § 1°. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

(d) que esse dispositivo constitucional foi regulamentado pelo artigo 7º da Lei nº 7.990/1989, que impôs à Petrobrás o pagamento de tais contraprestações aos Estados e Municípios em cujo território se fizesse a lavra, bem como àqueles confrontantes às áreas de produção marítima[158];

(e) que os recursos financeiros devidos aos Estados e Municípios produtores também foram contemplados pela Lei nº 9.478/1997, comumente designada como Lei do Petróleo, que reproduziu a previsão tradicional, determinando o pagamento mensal de *royalties* aos Estados produtores, fixando-os em montante equivalente a 10% (dez por cento) da produção de petróleo e gás natural, mas previu que esse percentual pode ser reduzido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP até o mínimo de 5% (cinco por cento), tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes, mediante previsão no edital de licitação do campo correspondente[159-160].

---

[158] A propósito, Barroso acentua que o artigo 7º da Lei nº 7.990/89 alterou o *caput* e o § 4º do artigo 27 da Lei nº 2.004/53 (BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 07-nota de rodapé), que, com a modificação legislativa, passaram a assumir a seguinte redação: "Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios: I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores; II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores; III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. (...) § 4º. É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios".

[159] Lei 9.478. "Art. 49 - A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção; b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção; c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas

Posto isso, Barroso destaca que, "a despeito de pequenas modificações, um elemento essencial permaneceu inalterado na regulamentação legislativa da matéria, desde o início da exploração do petróleo e gás no Brasil: a existência de uma retribuição a ser paga em favor dos estados e municípios produtores a fim de compensar os ônus e riscos decorrentes da atividade de exploração, seja em terra, seja na plataforma continental"[161]. Esse retrospecto histórico revela, conforme Barroso, que o constituinte, quando resolveu "constitucionalizar a matéria, da forma como fez, [...] claramente manifestou a intenção de manter o regime jurídico até então existente". Se assim não fosse, acrescenta Barroso, o constituinte "teria feito menção expressa de que as participações e compensações passariam a ser devidas a todos os estados e municípios, diferentemente do que vigorara até então", arrematando que, "como não procedeu assim, resulta clara a sua intenção de chancelar o modelo que sempre fora praticado e que, aliás, continuou a ser praticado nos mais de 20 anos de vigência da Constituição de 1988"[162].

Destarte, também razões históricas induzem a compreensão de que o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição restringe a atividade legislativa a ser desenvolvida pelo Parlamento ao disciplinamento da magnitude das receitas destinadas a Estados e Municípios impactados (Estados e Municípios produtores) como contraprestação pela exploração do petróleo e gás, e de que é vedado ao Congresso

---

operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis; II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores confrontantes;b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios produtores confrontantes;c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção; d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios; f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis".

[160] Ao ensejo, Barroso observa que "nos termos da Lei do Petróleo, a parcela básica de 5% continua a ser distribuída 'segundo os critérios estipulados pela Lei 7.990/89'", e que "a repartição da parcela que exceder a 5% segue critérios próprios, definidos no artigo 49" (BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 10).

[161] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 10.

[162] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 13-14.

Nacional distribuir parcela desses recursos (sobretudo a maior parte deles) a Estados e Municípios que não sofrem os reflexos dessa atividade econômica (Estados e Municípios não-produtores).

Nesse mesmo sentido opina o professor Gustavo Kaercher Loureiro, quando acentua que nos documentos que retratam a deliberação político-parlamentar tendente à construção do texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição "não aparece, em momento algum, intenção de uma partilha absoluta na plataforma continental"[163]. Conforme Loureiro:

> "[...] se a Constituição não reproduziu – como poderia ter feito, p.ex., relativamente às quotas de participação – algumas das regras das Leis anteriores (1985 e 1986), positivou, pela primeira vez em nossas Constituições, um direito aos Estados e Municípios, eliminando da esfera de disposição da União o que até então aí estava, i.e., a existência de direitos de apropriação das rendas da exploração de petróleo em favor de entes não proprietários. O que era derivado e dependente de iniciativa legislativa privativa da União, tornou-se originário e obrigatório *ex constitutione*. **Originário e obrigatório em favor, não de todos os Estados/Municípios do Brasil, mas daqueles entes da Federação que, desde 1953, batiam-se pelo reconhecimento de suas situações peculiares**. Esta, pelo menos, parece ter sido a intenção dos Constituintes"[164] (destaques pessoais).

Essa foi, de fato, a intenção dos constituintes, como se demonstrou anteriormente, que retrata a *mens legislatoris* desse dispositivo constitucional. Em especial o demonstram as seguintes manifestações dos constituintes Prisco Viana, José Lins, José Serra, Pimenta da Veiga, Renato Johnsson e Sérgio Spada por ocasião dos debates travados na Assembléia Nacional Constituinte, colhidas por Loureiro do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte":

> "De fato, a Constituição em vigor deixa dúvidas quanto a esse direito dos Estados e Municípios. **O que se quer, agora, é deixar bastante claro, bem definido, que esses Estados que pagam um alto preço pela exploração de petróleo em seus territórios, tenham esta indenização**" (Prisco Viana, constituinte pelo Estado da Bahia)[165-166].

---

[163] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 171.

[164] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 150.

[165] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.161-162.

[166] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível na internet: <http://imagem.camara.gov.br/constituinte_principal.asp>. p. 1.490.

"[...] **o que se deseja**, certamente, **são os *royalties* que a Petrobrás pagará sobre o petróleo que extrair em determinados territórios ou sobre o gás natural que explorar na costa da Bahia ou do Rio de Janeiro**" (José Lins, constituinte pelo Estado do Ceará)[167-168].

"[...] **muitos dos companheiros Constituintes que aqui estão ficam pensando no petróleo, no Município que fica pauperizado a partir da exploração de certos recursos minerais e outros, como no caso dos companheiros do Paraná, em áreas inundadas dentro de seu Estado por hidrelétricas**" (José Serra, constituinte pelo Estado de São Paulo)[169-170].

"[...] **O que se pretende apenas é proteger o interesse do Município e do Estado contra uma injusta espoliação que ocorre hoje, quando suas riquezas são retiradas, não ficando ao Estado e ao Município pouco mais do que nada**" (Pimenta da Veiga, constituinte pelo Estado de Minas Gerais)[171-172].

"**As unidades da Federação e os Municípios devem auferir uma renda a título de compensação pelo uso de recursos naturais** para a produção de eletricidade, que frequentemente é consumida e utilizada em grande medida fora de seus limites. A emenda procura assegurar que o aproveitamento de recursos naturais beneficie efetivamente e mais amplamente as Unidades da Federação e os Municípios onde eles se localizam. Os recursos naturais integram o conjunto de fatores produtivos no qual se deve apoiar o processo de desenvolvimento econômico e social das comunidades. **A receita correspondente a essa compensação propiciará recursos financeiros aos Municípios e às Unidades da Federação** – para projetos de desenvolvimento – **cujos recursos naturais deixam de propiciar, plenamente, os benefícios ao desenvolvimento das comunidades em que eles se localizam**" (Renato Johnsson, constituinte pelo Estado do Paraná)[173-174].

"[...] **A Assembléia Nacional Constituinte**, na semana passada, **historicamente corrigiu uma injustiça que vinha sendo cometida há muito tempo contra Estados produtores de energia elétrica e contra Estados fornecedores de matéria prima**, mais especificamente o minério. [...] **ficou definido que ficará assegurada, na futura Constituição, através do seu próprio texto, uma compensação financeira pelos danos, pelos prejuízos que esses Estados**, como é o caso de Paraná, de Minas Gerais, do Pará e da Bahia **que perdem inúmeros quilômetros quadrados de terra e recebem como herança as crateras pela exploração do minério**" (Sérgio Spada, constituinte pelo Estado do Paraná)[175-176].

---

[167] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.162.

[168] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.484.

[169] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 163.

[170] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.488.

[171] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.164.

[172] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., Suplemento C, de 27/01/88, p. 1.484.

[173] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.166.

[174] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., 08/03/88, p. 8.068.

[175] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p.167.

[176] BRASIL. Diário da Assembléia Nacional Constituinte, cit., vol. 1, Suplemento C, p. 1.091.

Essas manifestações dos constituintes demonstram que a *mens legis* atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição não destoa da sua *mens legislatoris*. Sob um ou outro ponto de vista, a retribuição financeira de que trata esse dispositivo constitucional tem por finalidade compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pela exploração de recursos naturais (Estados e Municípios produtores) pelos reflexos dessa atividade econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida das suas respectivas populações. Destarte, não há espaço para que o legislador distribua parcela dessas receitas (sobretudo a maior parte delas) a Estados e Municípios que não são impactados pela exploração de recursos naturais (Estados e Municípios não-produtores).

Mas há uma última razão a embasar semelhante conclusão. É que a Constituição deve ser analisada em seu todo, em interpretação sistemática, que leve em conta a integralidade de suas disposições. Quanto ao particular cumpre recobrar a basilar lição de Carlos Maximiliano, que caracteriza a interpretação sistemática como aquela que consiste na comparação do "dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto", com vistas a que "por umas" se conheça "o espírito das outras"[177]. Assim, a interpretação desse parágrafo 1º do artigo 20 da Carta de 1988 não pode ser feita à desconsideração do que estabelece a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155[178], que impõe aos Estados e Municípios[179] produtores, como salvaguarda dos interesses de Estados e Municípios não-produtores, relevante perda financeira, pautada na imunidade para a tributação pelo ICMS das operações relativas à saída de petróleo e derivados para outras unidades federadas. Quanto a esse aspecto, assim se pronunciou Barroso, no parecer a que dantes se referiu:

[177] MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1957. p. 164.

[178] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[179] Estes atingidos de forma reflexa, dada a repartição constitucional das receitas tributárias, de que trata o inciso IV do artigo 158 da Constituição; que tem a seguinte redação: "Art. 158. Pertencem aos Municípios: [...] IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

> "[...] A Constituição tem uma unidade interna e, além disso, é responsável pela unidade geral do sistema. No ponto aqui relevante, deve-se assinalar que o artigo 20, § 1º deve ser lido em conjunto com outras normas que afetam o ciclo econômico da produção do petróleo. Merece destaque, para os fins visados nesse estudo, a disciplina do imposto sobre circulação de mercadorias, especialmente o artigo 155, § 2º, X, b, também da Constituição. É possível afirmar que a regra geral, em relação a esse tributo, é o seu pagamento na origem, isto é, no estado onde se dá a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Todavia, o dispositivo acima destacado cria, em relação ao petróleo — e, também, à energia elétrica —, uma exceção: o ICMS, nesse caso, é pago no estado de destino do produto. Como já apontou o STF, essa disciplina foi criada para beneficiar o 'estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo'.
>
> Tal sistemática, em relação ao petróleo, se deveu ao fato de que os estados produtores, em lugar da tributação do ICMS, receberiam *royalties* e participações especiais, nos termos do artigo 20, § 1º. Uma coisa, então, compensaria a outra"[180].

Essa circunstância foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 24.312/DF[181]. Na oportunidade, o Ministro Nelson Jobim apresentou ao Tribunal Constitucional importante relato histórico, colhido da sua experiência parlamentar como constituinte, que restou consignado no seguinte trecho da sua manifestação naquele processo:

> "Em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? Houve uma grande discussão na constituinte sobre se o ICMS tinha que ser na origem ou no destino.
>
> A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, os Estados do Sul continuavam gratuitamente tributando as poupanças consumidas nos Estados do Norte e do Nordeste.
>
> Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia elétrica - recursos hídricos - e petróleo.

---

[180] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 14-15.

[181] Recobre-se a emenda do julgado: "MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU RESULTADO, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 20, § 1º. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 - Não tendo sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de Contas da União que autoriza a realização de auditorias nos municípios e Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF. 2 - **Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União** (CF, art. 20, V e IX), **a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos** (CF, art. 20, § 1º). 3 - É inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI da Carta Magna que se refere, especificamente, ao repasse efetuado pela União - mediante convênio, acordo ou ajuste - de recursos originariamente federais. 4 - Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, abandonado para participar das razões prevalecentes. 5 - Segurança concedida e, ainda, declarada a inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e 198, inc. III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991" (STF. MS 24312/DF. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 19/02/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 19-12-2003, PP-00050, EMENT VOL-02137-02 PP-00350).

> Ocorreu o seguinte: os estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a produção de energia elétrica acabariam recebendo ICMS incidente sobre o petróleo e energia elétrica.
>
> O que se fez? Participei disso diretamente, lembro-me que era, na época, o Senador Richard quem defendia os interesses do Estado do Paraná e o Senador Almir Gabriel quem defendia os interesses do Estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às plataformas de petróleo.
>
> Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois dispositivos na Constituição? Daí porque preciso ler o § 1º do Art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos da Constituição Federal.
>
> O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados - petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica, - ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS.
>
> [...]
>
> Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos Estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o § 1º do artigo 20 [...]".

Esse relato do Ministro Jobim revela que o poder constituinte concebeu conjuntamente os dispositivos encartados no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e na alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155. E que a intenção do legislador constitucional quando idealizou esse parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição foi compensar os Estados produtores também pela perda de receitas que lhes foi imposta pela regra imunizante consignada nessa alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155.

Esse argumento foi empregado pela Advocacia Geral da União, órgão a quem a Constituição conferiu a representação jurídica e a consultoria e assessoramento do Poder Executivo Federal (art. 131[182]), por ocasião da sua manifestação na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.846, ainda pendente de julgamento, no corpo da qual se questiona a constitucionalidade do artigo 9º da Lei Federal nº 7.990/1989. Consta do referido documento, que foi ratificado pelo Advogado Geral da União, comandante supremo da Advocacia Geral da União (art. 131, p. 1º[183]) e autoridade pública encarregada pela Constituição da defesa dos textos legais impugnados

[182] CRFB. "Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo".

[183] CRFB. "Art. 131 [...] § 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada".

em controle abstrato de constitucionalidade das leis (art. 103, p. 3º[184]), que os *royalties* de petróleo foram instituídos pelo constituinte também como forma de compensar as perdas dos Estados e Municípios produtores com a imunidade tributária estabelecida por essa alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Tal se infere dos seguintes excertos daquela manifestação jurídica:

> "[...] o direito à participação no resultado ou à compensação financeira (CF, art. 20, § 1º) não tem como razão exclusiva a necessidade de recompor os entes afetados por prejuízos reais ou eventuais.
>
> 19. É o que se pode depreender do valioso relato histórico proferido pelo então Ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim, em seu voto no MS 24.312/DF, cuja relevância para a causa impõe a seguinte transcrição:
>
> > "Em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? Houve uma grande discussão na constituinte sobre se o ICMS tinha que ser na origem ou no destino.
> >
> > A decisão foi que o ICMS tinha de ser na origem, ou seja, os estados do Sul continuavam gratuitamente tributando as poupanças consumidas nos estados do Norte e do Nordeste.
> >
> > Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia elétrica - recursos hídricos -e petróleo.
> >
> > Ocorreu o seguinte: os estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a produção de energia elétrica acabariam recebendo ICMS incidente sobre o petróleo e energia elétrica.
> >
> > O que se fez? Participei disso diretamente, lembro-me que era, na época, o Senhor Richard quem defendia os interesses do Estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às plataformas de petróleo.
> >
> > Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois dispositivos na Constituição? Daí porque preciso ler o § 10 do Art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos da Constituição Federal.
> >
> > O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados - petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica -, ou seja, tirou-se da origem a incidência de ICMS.
> >
> > Veja bem, toda a produção de petróleo realizada no Estado do Rio de Janeiro, ou toda produção de energia elétrica, no Paraná e no Pará, eram decorrentes de investimentos da União, porque o monopólio era da União. Toda a arrecadação do País contribuiu para aquela produção.
> >
> > Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita.
> >
> > Aí criou-se o § 1º do art. 20, dizendo:
> >
> > > "Art. 20. § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União" - já se falava na possibilidade de criação das agências que poderiam ser financiadas em face da autonomia financeira - "participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica" - leia-se ITAIPU, que estava na base da discussão do Paraná - "e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica

[184] CRFB. "Art. 103 [...] § 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado".

> exclusiva" -que eram as plataformas de petróleo de Sergipe -"ou compensação financeira por essa exploração" (não há grifos no original)

20. O testemunho histórico do constituinte e então Ministro do Supremo Tribunal Federal é de fundamental relevância para se compreender o verdadeiro propósito que inspirou o art. 90 da Lei 7.990, de 1989.

[...]

Retomando a análise sobre o caso concreto, não se nega que existam diversas manifestações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de que tal receita tem natureza patrimonial, e sua destinação feita pelo § 1º do art. 20 da CF é endereçada diretamente a Estados e Municípios.

28. Não procede, todavia, a idéia de que o direito a participação ou compensação do § 1º do art. 20 seja decorrente apenas dos potenciais custos gerados para cada ente atingido.

29. Pelo que se pode verificar a partir da vertente histórica, autêntica, acima transcrita, a prerrogativa concedida pelo § 1º do art. 20 deve ser lida em conjunto com o disposto na línea b do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, que assim dispõe, em sua redação atual (EC nº 3, de 1993):

> Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
>
> (...)
>
> II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
>
> (...)
>
> § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
>
> (...)
>
> X - não incidirá:
>
> (...)
>
> b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

30. Não é demais lembrar a contundente lição do Ministro Eros Grau, que igualmente já compôs a nossa E. Corte Constitucional, "a Constituição não se interpreta em tiras".

31. Ora, em se tratando de "perda de receita" de ICMS (termo usado pelo Ministro Nelson Jobim), haveria, consequentemente, diminuição proporcional da repartição de receitas tributárias a que todos os Municípios têm direito.

32. Em que pese não serem tributárias as receitas oriundas da participação ou compensação conferidas pelo § 1º do art. 20, elas só existem - como se depreende do testemunho histórico retro transcrito - em razão da isenção imposta pelo art. 155, § 2º, X, b, fruto de uma vontade legislativa de compor os interesses de todos os entes da federação, sem lhes impor prejuízos".

A propósito, o professor Gustavo Kaercher Loureiro observa que "antes de 1988, os Estados/Municípios 'produtores' recebiam *royalties*, além da parte que lhes cabia no Imposto Único (a título de 'produção')", e que "o que ocorreu em 1988 é que estes sujeitos passaram a ter direitos originários sobre as participações, ao mesmo tempo em que perderam a receita tributária que até então tinham"[185]. Loureiro recobra

[185] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 152.

que o Imposto Único foi extinto[186], e que sua base foi incorporada ao ICMS, imposto de competência estadual, mas que em razão dessa excepcionalidade narrada pelo Ministro Jobim não incide em favor do Estado produtor de petróleo e derivados, mas dos Estados consumidores[187]. Em suas próprias palavras:

> "Em apertada síntese, a tributação setorial:
>
> • deixou de ser realizada pelo Imposto Único, que foi abolido.
>
> • passou a ser realizada, primordialmente, pelo novo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de titularidade dos Estados da Federação;
>
> • de modo tal que não beneficiaria o Estado de origem da mercadoria ('produtor'), mas sim destinatário dela ('consumidor')"[188].

Essa excepcionalidade impôs aos Estados produtores de petróleo e gás uma perda arrecatadória, pois, como expressa Loureiro, "ao tempo do Imposto Único recebiam parte do que cabia a todos os Estados, via critério da produção de óleo cru"[189].

Sendo assim, a conclusão a que se chega é que a regra jurídica encartada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição visa a compensar os Estados e Municípios produtores de petróleo e gás não apenas pelos riscos e custos assumidos com a atividade petrolífera, como se infere das manifestações dos constituintes e da interpretação correntemente atribuída a esse dispositivo pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas também pela perda financeira decorrente da instituição da imunidade tributária incidente sobre as operações de saída de petróleo e derivados, de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155. Por um ou outro argumento, a distribuição das participações governamentais advindas da exploração do petróleo e gás em maior proporção a Estados e Municípios

---

[186] Conforme Loureiro: "À época da Constituinte, o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes encontrava-se regulado pelo Decreto-Lei 335, de 1967, que, em seu art. 2o, partilhava a receita do tributo da seguinte forma: (i.) 60% à União; (ii.) 32% aos Estados e Distrito Federal e (iii.) 8% aos Municípios. A aplicação destes recursos era vinculada, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 61 de 1966 (por remissão expressa do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 335/67), a aumentos de capital da Rede Ferroviária Federal e da Petrobrás (9,4% e 14,4%, respectivamente), e à utilização em programas rodoviários, através do Fundo Rodoviário Nacional" (LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 172).

[187] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 152.

[188] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 173.

[189] LOUREIRO, Gustavo Kaercher. *Participações governamentais na indústria do petróleo: Evolução Normativa*, cit., p. 173-174.

que não são impactados pelo exercício dessa atividade econômica (Estados e Municípios não-produtores) afronta o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, não encontrando, assim, fundamento de validade naquela Carta Política.

2.2.1.4. Inexistência de razão válida para se abandonar a *mens legislatoris* do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e para se modificar a interpretação correntemente atribuída a esse dispositivo constitucional pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (*mens legis*).

Mas há quem afirme, em resposta a esses argumentos, que o potencial aumento da base de produção de petróleo e gás, preordenada pela descoberta de jazidas no pré-sal, faria com que os Estados e Municípios produtores se desenvolvessem em ritmo superior ao desenvolvimento das regiões vizinhas, tendo em vista a correspondente elevação das suas receitas com as participações governamentais de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição (com destaque para os *royalties* e participações especiais), criando, com isso, disparidades regionais[190-191].

O que se dá é que, como relatou o Consultor Geral da União, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, em parecer publicado na Revista de Arbitragem e Mediação, "especula-se que a camada de petróleo de pré-sal que se pode explorar supere cinco vezes as reservas atuais do país", e que, ao que tudo indica, "a confirmação da expectativa nos colocaria entre os grandes produtores de petróleo do mundo, a exemplo da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, do Kuwait e dos Emirados Árabes"[192]. Para se ter uma idéia das expectativas do Governo Federal quanto às potencialidades das jazidas de petróleo encontradas no pré-sal cumpre referir, ainda, ao seguinte trecho da manifestação do Ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, por ocasião da divulgação ao País da descoberta de jazidas no pré-sal, reproduzido por Godoy no mesmo parecer: "um novo horizonte se descortinou para a indústria petrolífera no País. A expectativa é de que

[190] A propósito, cfr., por todos, a manifestação do professor Flávio Dino em palestra proferida no II Seminário Brasileiro do Pré-Sal, realizado no Rio de Janeiro entre nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2011.

[191] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 80-86, passim.

[192] GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. *Arbitragem internacional nos contratos de cessão onerosa de petróleo nas camadas de pré-sal.* Parecer. In: Revista de arbitragem e mediação. São Paulo, ano 8, vol. 28, jan./mar. 2011. p. 270.

a nova província do pré-sal posicionará o Brasil entre os dez países com as maiores reservas de petróleo e gás natural"[193].

Tal circunstância justificaria, então, sob essa específica visão do problema, o abandono da *mens legislatoris* do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e a modificação da interpretação correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a esse dispositivo (*mens legis*). Enfim, ter-se-ia, na espécie, a modificação da interpretação constitucional, proporcionada pela intervenção do elemento histórico.

Entretanto, em que pese ser saudável que o pensamento constitucional evolua para acompanhar o desenvolvimento da sociedade e as mudanças dos costumes e valores que imperam no meio social, não há motivos para que assim se faça na hipótese analisada. Sobretudo tendo em vista a afirmação de que a elevação da base produtiva do petróleo enriqueceria somente os Estados e Municípios que recebem *royalties* e participações especiais.

É que essa é, em tudo e por tudo, uma suposição equivocada. Com efeito, o ordenamento jurídico-positivo já confere aos Estados e Municípios não-produtores parcela apreciável da receita pública auferida com a atividade de exploração de petróleo e gás, mais especificamente as receitas decorrentes da tributação pelo ICMS das suas respectivas operações.

Não sobeja lembrar, a propósito, que o ICMS é tributo não-cumulativo. Como se sabe, o princípio da não-cumulatividade está assegurado, para o ICMS, por força do disposto no inciso I do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta da República; que tem a seguinte redação:

> **CRFB**
>
> **Art. 155** [...]
>
> **§2º.** O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
>
> **I -** será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o cobrado nas

[193] GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. *Arbitragem internacional nos contratos de cessão onerosa de petróleo nas camadas de pré-sal*, cit., p. 275.

> anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (destaques pessoais).

Em razão da não-cumulatividade, o contribuinte fica autorizado a deduzir o imposto cobrado nas operações anteriores (que, para a hipótese, seria recolhido pelos Estados produtores) do imposto devido nas operações subseqüentes, mediante creditamento. Como, no caso, não há tributação na operação anterior, dada a incidência da imunidade tributária prevista na alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição[194], o imposto, na prática, acaba transferido, em sua integralidade, para os Estados a que se destinam as mercadorias comercializadas.

Nesse sentido é o posicionamento pretoriano há muito consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para quem a referida imunidade tributária foi instituída apenas para efeito de evitar a tributação do petróleo e derivados pelo Estado de origem, possibilitando, com isso, que o Estado de destino proceda à cobrança do tributo em sua totalidade. É o que se infere, a título exemplificativo, do seguinte julgado:

> TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. **Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo**. Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido (STF. RE 198088/SP. Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento: 17/05/2000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJ 05-09-2003 PP-00032).

Deve ser destacado, por oportuno, que, dada a incidência da não-cumulatividade, a desoneração tributária ora mencionada acaba beneficiando toda a cadeia de consumo, favorecendo, com isso, todo e qualquer Estado em cujo território se realizarem operações de circulação de petróleo e derivados (gasolina, gás natural, lubrificantes, etc.). Também os Municípios localizados nos Estados não-produtores

[194] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

acabam beneficiados, pois a Constituição confere a eles parcela do ICMS arrecadado pelos seus respectivos Estados (art. 158, IV[195]).

Assim, supondo que a Petrobrás, ou qualquer outra empresa exploradora, destine determinada quantidade do petróleo extraído no Estado do Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro, a refinaria localizada no Estado da Bahia, não incidiria ICMS nessa operação, dada a imunidade tributária prevista na alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, de modo que o imposto seria recolhido em sua totalidade pelo Estado da Bahia. Imaginemos, então, que o produto beneficiado seja vendido, sob a forma de gasolina, ou de óleo diesel, a uma distribuidora domiciliada no Estado do Maranhão, e que essa distribuidora apenas comercialize esses derivados de petróleo no Maranhão. Nesse caso, o Estado do Maranhão ficará com o ICMS incidente sobre a primeira operação, que consiste na remessa do produto beneficiado do Estado da Bahia, e também tributará as operações seguintes, realizadas dentro do seu território, seja aquelas consistentes na remessa dos derivados de petróleo da distribuidora maranhense para postos de distribuição localizados no próprio Estado, seja aquelas referentes às vendas desses combustíveis ao consumidor final. Concebamos, por fim, que parte das vendas realizadas pela distribuidora maranhense destinem-se a postos de distribuição localizados no Estado do Piauí. Nessa hipótese, caberá a essa unidade federada tributar as transferências realizadas entre a distribuidora e os postos de distribuição de combustíveis, e também as operações de venda ao consumidor final.

Foi dito que, dada a incidência da regra da não-cumulatividade, o vendedor está autorizado a deduzir, a cada operação, o imposto anteriormente recolhido, mediante creditamento. No entanto, isso não faz com que os Estados que ficam na ponta da cadeia de consumo sejam privados de recursos financeiros advindos da tributação incidente sobre a exploração e comercialização do petróleo e derivados. É que essa atividade, como qualquer outra atividade empresarial, visa à obtenção de lucro, o que faz com que, a cada operação, o vendedor agregue valor ao produto comercializado, majorando-lhe ao preço de venda. Com isso, todos Estados acabam contemplados com

[195] CRFB. "Art. 158. Pertencem aos Municípios: [...] IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

receitas advindas da exploração do petróleo[196]. A medida da sua participação nesse aporte de recursos corresponde, em regra, ao seu consumo interno de derivados de petróleo. Mas também é afetada por decisões empresariais, vez que a escolha, pela indústria petrolífera, dos locais onde serão instaladas refinarias e outros estabelecimentos destinados ao beneficiamento desse recurso natural faz com que as unidades federadas que sediam essas plantas produtivas fiquem com o ICMS que incidiria sobre as saídas do petróleo e derivados dos Estados produtores (que não podem tributar essas operações, dada a imunidade tributária de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição) e sobre as operações subseqüentes realizadas em seu território, como a transferência do petróleo beneficiado para as distribuidoras e também para os postos combustíveis. Os Municípios também são beneficiados, nesse contexto, dada a previsão constitucional de distribuição a essas unidades federadas de parte das receitas tributárias dos seus respectivos Estados, contexto em que se insere o ICMS (art. 158, IV[197]).

Essa receita tributária não pode ser desprezada quando da avaliação da necessidade do "abandono" da opinião dos constituintes e da interpretação correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Com efeito, estudos econômicos apontam que o produto da arrecadação do ICMS sobre a exploração do petróleo e derivados é deveras superior ao montante de *royalties* e participações especiais pagos pelas empresas exploradoras pelo exercício dessa atividade econômica.

[196] Inclusive os Estados produtores, que participam da tributação pelo ICMS dos derivados de petróleo vendidos em seus mercados internos, com resultados financeiros para os seus Municípios, sejam eles produtores ou não-produtores desse recurso natural. Se o legislador constitucional não houvesse instituído a imunidade tributária de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, essas unidades federadas teriam uma substancial arrecadação de receitas com esse tributo, pois é inegável a sua perda financeira na remessa de petróleo e derivados a outros Estados, para beneficiamento, ou da remessa do óleo beneficiado para outros Estados, para consumo, precisamente porque aos Estados produtores, em uma ou outra circunstância, é vetada a tributação das saídas para outras unidades federadas.

[197] CRFB. "Art. 158. Pertencem aos Municípios: [...] IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

Ao ensejo, cumpre referir, a título exemplificativo, aos números apontados em trabalho publicado pelos economistas José Roberto Afonso[198] e Kleber Pacheco de Castro[199], intitulado "Carga tributária sobre petróleo no Brasil: evidências e opções"[200]. Na apuração desses economistas, no ano de 2010, a arrecadação tributária com a incidência do ICMS sobre a exploração de petróleo correspondeu a 1,11% (um vírgula onze por cento) do PIB brasileiro, ao passo que as chamadas "rendas de exploração", que abrangem *royalties* e participações especiais, entre outras contraprestações financeiras arrecadadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, atingiram o patamar de 0,59% (zero vírgula cinqüenta e nove por cento). Números semelhantes são encontrados na comparação das receitas relativas aos anos anteriores[201]. Disso se infere que a receita tributária auferida com a incidência do ICMS sobre a indústria petrolífera (parte considerável da qual seria arrecada pelos Estados produtores se não existisse a imunidade prevista na alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição) corresponde a pouco menos que o dobro das receitas patrimoniais levantadas com *royalties*, participações especiais e outras participações governamentais advindas da exploração do petróleo e gás.

No entanto, deve ser destacado, a propósito, que os números apresentados pelos economistas, no que se refere a essas "rendas de exploração", não abarcam exclusivamente os *royalties* e participações especiais distribuídos aos Estados e Municípios produtores, mas também compreendem (i) as participações governamentais destinadas à União Federal (*royalties*, participações especiais, bônus de assinatura e

---

[198] José Roberto Afonso é Doutor em Economia pela UNICAMP e Mestre pela UFRJ, e trabalha como consultor técnico do Senado Federal.

[199] Kleber Pacheco de Castro é Mestre em Economia pela UFF.

[200] AFONSO, José Roberto; CASTRO, Kleber Pacheco de. *Carga tributária sobre petróleo no Brasil: evidências e opções.* Disponível na internet: <http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/111101_tributacao_petroleo_v6.pdf>; acesso em 20 de novembro de 2011.

[201] Em 2009, a proporção foi de 1,15% por 0,52%; em 2008, de 1,27% por 0,75%; em 2007, de 1,26% por 0,55%; em 2006, de 1,37% por 0,70%; em 2005, de 1,31% por 0,61%; em 2004, 1,33% por 0,53%; em 2003, de 1,30% por 0,55%; em 2002, de 1,31% por 0,39%; em 2001, de 1,33% por 0,31%; e em 2000, de 1,26% por 0,25% (AFONSO, José Roberto; CASTRO, Kleber Pacheco de. *Carga tributária sobre petróleo no Brasil: evidências e opções.* Disponível na internet: <http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/111101_tributacao_petroleo_v6.pdf>; acesso em 20 de novembro de 2011).

pagamento pela ocupação e retenção de áreas[202]), (ii) o montante distribuído ao fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.479/1997[203], que destina parte dessas receitas aos Estados e Municípios não-produtores, e (iii) o quantitativo distribuído pelos Estados produtores aos seus Municípios nos termos do artigo 9º da Lei nº 7.990/1989[204]. Assim, o ICMS sobre essas operações certamente supera o dobro os *royalties* e participações especiais recebidos em contrapartida pelos Estados e Municípios produtores.

Tanto essa receita tributária quanto os *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração do petróleo e gás são calculados pela aplicação de percentual (alíquota) sobre o resultado da produção petrolífera. Por isso, um aumento na produção faz com que se ampliem, em idêntica proporção, não apenas a receita patrimonial com *royalties* e participações especiais, mas também a receita tributária dos Estados e Municípios.

Pelo exposto, não há dúvidas de que os Estados e Municípios produtores e não-produtores de petróleo e gás serão igualmente beneficiados pela ampliação dos níveis da atividade petrolífera, preordenada pela descoberta de jazidas no pré-sal; e de que tal ocorrerá mesmo se forem mantidas as bases atuais da distribuição dos recursos advindos dessa exploração às unidades federadas; pelo que não há razão válida para se abandonar a *mens legislatoris* do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e para se modificar a interpretação correntemente atribuída pela doutrina

[202] Essas são as participações governamentais pagas às unidades federadas pela exploração de petróleo e gás (Lei 9.478, art. 45). Como se sabe, os *royalties* e as participações especiais são pagos à União Federal, aos Estados e aos Municípios (Lei 9.478, arts. 48, 49 e 50). Já os bônus de assinatura (Lei 9.478, art. 46) e o pagamento pela ocupação e retenção de áreas (Lei 9.478, art. 51) são pagos somente à União, ou a órgãos de sua estrutura (Cfr., a propósito: PETRY, Rodrigo Caramori. *Compensações financeiras, participações e outras cobranças estatais sobre empresas dos setores de mineração, energia, petróleo e gás*, cit.).

[203] Lei 9.479. "Art. 49. A parcela do valor do *royalty* que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: [...] II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: [...] d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP".

[204] Lei 7.990. "Art. 9º Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2º, § 1º, 6º, § 3º e 7º desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos, estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação".

jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a esse dispositivo (*mens legis*).

2.2.1.5. Sobre a absoluta necessidade de a lei referida pelo parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição conter disposições compatíveis com essa interpretação constitucional.

Também já se afirmou[205], com o intuito de contraditar a tese jurídica sustentada nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, que a Constituição não disciplina por completo o direito dos Estados e Municípios ao recebimento de participações governamentais (inclusive *royalties* e participações especiais), porque emprega no parágrafo 1º do seu artigo 20 a expressão "na forma da lei"[206]. Sob essa específica visão do problema, supõe-se que o legislador teria liberdade para dispor como bem entendesse, sem quaisquer limites ou condicionantes, sobre a distribuição dessas retribuições financeiras a Estados e Municípios.

Mas essa ilação é incompatível com a idéia de supremacia da Constituição. Em especial, porque é inconciliável a compreensão segundo a qual as Cartas Políticas ostentam (como já não mais se discute no meio jurídico[207]) inequívoca força normativa, que lhe permite, inclusive, interferir no modo como são produzidos os textos legislativos que conferem completude aos direitos e deveres estabelecidos em seu corpo.

Ao ensejo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello nos recobra de que uma Constituição "define-se como um corpo de normas jurídicas", dispondo, a propósito, que "as normas jurídicas não são conselhos, opinamentos,

---

[205] Essa afirmação foi verbalizada por Parlamentares dos Estados não produtores na sessão do Congresso Nacional que derrubou o veto aposto pela Presidência da República aos dispositivos do PL 2.565 que dispunham sobre a distribuição de *royalties* e participações especiais entre os Estados e Municípios.

[206] CRFB. "Art. 20 [...] § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

[207] A propósito, cfr. por todos: HESSE, Konrad. *A força normativa da constituição*, cit..

sugestões", mas são, em verdade, "determinações", pois "o traço característico do Direito é precisamente o de ser disciplina obrigatória de condutas"[208]. Daí que, para Bandeira de Mello, "a feição específica da prescrição jurídica é a imposição, a exigência"[209].

Bandeira de Mello não ignora a existência, nas Constituições, ao lado de preceitos que "outorgam imediatamente, sem a necessidade de qualquer regramento ulterior, tanto o desfrute imediato e positivo de certos benefícios quanto a possibilidade de exigi-los, se acaso forem negados"[210], também de dispositivos que, "em decorrência de sua dicção, dependem de normação infraconstitucional para desprenderem a plenitude dos efeitos a que se destinam e que neles se encontram virtualmente obrigados"[211]. Mas adverte que mesmo essas normas que dependem de disciplina infraconstitucional (como ocorre, por exemplo, com as regras constitucionais que prescrevem que determinadas prestações serão fruídas "na forma da lei") ostentam nítida eficácia normativa, precisamente porque "surtem a conseqüência de impor ao exegeta, na análise de quaisquer atos ou relações jurídicas [...] o dever jurídico irrecusável de interpretá-los na mesma linha e direção estimativa para que aponte o dispositivo constitucional"[212].

O que se dá é que, como nos ensina Bandeira de Mello, "todas as disposições constantes de uma Constituição, inclusive as programáticas [...] são normas jurídicas"[213]. Nesse mesmo sentido é a lição de José Afonso da Silva, para quem "não há norma constitucional de valor meramente moral ou de conselho, avisos ou lições", pois "todo princípio inserto numa Constituição rígida adquire dimensão jurídica, mesmo aqueles de caráter mais acentuadamente ideológico-progamático [...]"[214]. Disso decorre

[208] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 11.

[209] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 11.

[210] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 14.

[211] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 15.

[212] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 15.

[213] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 13.

[214] SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 80.

a observação desse notável constitucionalista, endossada por Bandeira de Mello[215], no sentido de que "não há norma constitucional alguma destituída de eficácia", pois "todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre numa inovação da ordem jurídica preenxistente a entrada em vigor da Constituição a que aderem e a ordenação instaurada"[216]. Daí que, nas palavras de Bandeira de Mello, a Constituição deve ser tomada como "um conjunto de dispositivos que estabelecem comportamentos obrigatórios para o Estado e para os indivíduos"[217].

Ocorre que, como expôs, adiante, o professor paulista, "a Constituição não é um mero feixe de leis, igual a qualquer outro corpo de normas"[218]. Com efeito, as Cartas Políticas diferenciam-se das demais espécies legislativas porque comportam "um corpo de normas qualificado pela posição altaneira, suprema, que ocupa no conjunto normativo"[219]. Por esse motivo é que, conforme Bandeira de Mello, todos lhes devem obediência, inclusive o Poder Legislativo[220].

Posto isso, **o Congresso Nacional**, quando da edição da lei ordinária reclamada pelo parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição (cuja finalidade é disciplinar a distribuição às unidades federadas da compensação financeira/participação no resultado da exploração de recursos naturais), **não pode se afastar da finalidade atribuída a essa retribuição financeira pelos constituintes (*mens legislatores*) e pelos intérpretes da Constituição (*mens legis*)**. Como essa retribuição financeira destina-se, na opinião dos constituintes (*mens legislatores*) e na interpretação correntemente atribuída a esse dispositivo constitucional pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (*mens legis*) à compensação (ou indenização) dos impactos dessa atividade econômica, **não pode o legislador**, validamente, **determinar a distribuição dessa receita pública a Estados e Municípios não impactados pela exploração de petróleo e gás** (entre outros recursos naturais), **sobretudo para destinar a essas unidades federadas não**

[215] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 13.

[216] SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 81.

[217] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 12.

[218] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 12.

[219] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 12.

[220] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais*, cit., p. 12.

impactadas a maior parte dessa receita pública, como sobressai da redação conferida pela Lei nº 12.734/2012 aos dispositivos legais impugnados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

2.2.2. Ofensa ao princípio da isonomia (CRFB, art. 5º).

Demonstrou-se que a regra jurídica encartada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição visa a compensar os Estados e Municípios produtores de petróleo pelos riscos e custos inerentes à atividade petrolífera (como sobressai das manifestações dos constituintes e da interpretação que lhe é correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal) e também pela perda financeira decorrente da instituição da imunidade tributária incidente sobre as operações de saída de petróleo, de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155[221]. Disso se concluiu que a distribuição dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração do petróleo a todas as unidades federadas, e não apenas aos Estados e Municípios impactados por essa atividade econômica, afronta aquele dispositivo constitucional, não encontrando, assim, fundamento de validade na Carta Política.

Mas essa não é a única razão jurídica a embasar a inconstitucionalidade de semelhante opção político-legislativa. Na verdade, a distribuição dessas receitas a todos os Estados e Municípios, proposta como meio de promover a igualdade entre as unidades federadas, traduz, ao contrário, ofensa ao princípio da isonomia[222].

O princípio da isonomia encontra-se positivado, na Carta Política de 1988, no *caput* do seu artigo 5º, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Confira-se a redação literal do dispositivo:

[221] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[222] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 87-104, passim.

CRFB

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]

Ocorre que, consoante posicionamento pretoriano há muito consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a isonomia não admite a atribuição de tratamento paritário a desiguais. Tal se infere, a título de exemplo, dos seguintes julgados:

> INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL QUE TERIA VIOLADO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. **O TRATAMENTO DESIGUAL** - AINDA QUE POSSA SER ACOIMADO DE INJUSTO - **DE SITUAÇÕES DESIGUAIS, NA MEDIDA DE SUA DESIGUALDADE ATENDE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA**. SE VIOLADO ESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL, CABERIA AO PODER JUDICIARIO DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA, NÃO, POREM COMO PRETENDE A RECORRENTE, - ESTENDE-LA PARA ALCANCAR HIPÓTESES EXPRESSAMENTE AFASTADAS DO ÂMBITO DE SUA INCIDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (STF. RE 80767/SC. Relator(a): Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 13/08/1976. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Publicação: DJ 24-09-1976) (destaques pessoais).

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77 DA LEI FEDERAL N. 9.504/97. PROIBIÇÃO IMPOSTA AOS CANDIDATOS A CARGOS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NOS TRÊS MESES QUE PRECEDEM O PLEITO ELETIVO. SUJEIÇÃO DO INFRATOR À CASSAÇÃO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. ARTIGO 5O, CAPUT E INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 1. A proibição veiculada pelo preceito atacado não consubstancia nova condição de elegibilidade. Precedentes. 2. O preceito inscrito no artigo 77 da Lei federal n. 9.504 visa a coibir abusos, conferindo igualdade de tratamento aos candidatos, sem afronta ao disposto no artigo 14, § 9º, da Constituição do Brasil. 3. A alegação de que o artigo impugnado violaria o princípio da isonomia improcede. **A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais**. 4. Os atos normativos podem, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. É necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente (STF. ADI 3305/DF. Relator(a): Min. EROS GRAU. Julgamento: 13/09/2006. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 24-11-2006, PP-00060, EMENT VOL-02257-03, PP-00555, LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 98-110) (destaques pessoais).

Enfim, a atribuição de tratamento isonômico pressupõe igualdade de posições perante o problema, pré-condição que não é atendida na hipótese analisada. E isso porque, como se terá a oportunidade de adiante expor e demonstrar, Estados e Municípios produtores e não-produtores não se encontram equiparados.

(a) frente aos riscos e custos inerentes à atividade de exploração de petróleo; e

(b) frente ao discrimine estabelecido pela imunidade tributária de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição.

2.2.2.1. Desequiparação entre Estados e Municípios produtores e não-produtores frente aos riscos e custos inerentes à atividade de exploração de petróleo e gás.

Uma opção político-legislativa pela distribuição dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração do petróleo e gás a todos os Estados e Municípios (tratamento paritário) vai de encontro à constatação de que, frente a essa atividade econômica, Estados e Municípios produtores não se encontram em situação semelhante a Estados e Municípios não-produtores (diversidade de situações)[223].

A concretização dos efeitos de semelhante opção político-legislativa fará com que os Estados e Municípios produtores deixem de receber a necessária contraprestação pelos ônus decorrentes, entre outros itens, das despesas com infraestrutura e de prejuízos ambientais. Tal circunstância foi destacada pelo jurista Luís Roberto Barroso, quando ressaltou, na linha do que se sustentou anteriormente nesta peça processual, que a finalidade dos recursos especificados no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição é compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios produtores pelos riscos inerentes à exploração de petróleo e pelos custos que decorrem do exercício dessa atividade econômica, que ensejam o "aumento da demanda por serviços públicos e atividades governamentais, como distribuição de água, energia elétrica e gás natural, segurança pública, transportes, habitação, urbanismo, defesa civil, proteção ao meio ambiente, dentre outros", além de "elevados impactos e riscos ambientais", cuja

[223] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 89-101, passim.

"existência e gravidade foram tristemente demonstradas por recente acidente de grandes proporções, ocorrido no Golfo do México"[224].

É fato que a indústria do petróleo, embora traga investimentos, também gera ônus para os Estados e Municípios nos quais se instala. A propósito, vejamos, a título de exemplo, a realidade da cidade de Marataízes, situada no sul do Estado do Espírito Santo, que muito se assemelha a tantos outros Municípios litorâneos afetados pela exploração do petróleo, sobretudo àqueles que vivenciam a fase inicial da instalação das plantas empresariais para a exploração desse recurso natural nas proximidades de suas praias.

Marataízes é um Município com trinta e seis mil habitantes, que fica a cento e vinte sete quilômetros de Vitória, Capital do Estado. Parte de sua população vive da pesca, e outra parte é ocupada nos serviços que prestam suporte à indústria do turismo (hotelaria, bares, restaurantes, comércio, etc.)[225].

Para uma cidade com essas características, um vazamento de petróleo, como o que ocorreu no Golfo do México, citado por Barroso, tem a potencialidade de desagregar o funcionamento da economia local, vez que tanto a pesca quanto o turismo dependem de praias limpas. É certo que eventos dessa natureza impõem a reparação dos prejuízos ambientais e econômicos pelas empresas exploradoras. Mas até que isso ocorra, o Município, com o apoio do Estado, precisará lançar mão de recursos financeiros para, de alguma forma, minimizar o sofrimento daqueles que tiveram seu meio de vida prejudicado[226]. E isso porque, por razões óbvias, a cidade precisa continuar funcionando, as crianças precisam continuar freqüentando as escolas, os alimentos precisam continuar chegando às mesas das famílias, os serviços

[224] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 16.

[225] Informações disponíveis na internet: <http://www.marataizes.es.gov.br/default.asp>; acesso em 10 de outubro de 2011.

[226] A propósito, Kiyoshi Harada leciona que "em casos de acidentes, decorrentes dessas atividades, torna-se imperiosa a imediata mobilização de recursos materiais e humanos pelos poderes públicos", dispondo que "o poder público local é sempre aquele que se encontra na linha de frente para prestar os primeiros socorros à população atingida" (HARADA, Kiyoshi. *Direito financeiro e tributário*, cit., p. 55).

públicos precisam continuar sendo prestados, etc., mesmo se não houver pescados e nem turistas para gerar divisas para o setor de serviços.

A ocorrência de um acidente desse tipo não é improvável[227]. Sobretudo quando se considera a recente incidência, entre nós, de eventos de menor proporção, mas igualmente capazes de afetar a economia dos Estados e Municípios situados nas proximidades dos campos de produção de petróleo.

A propósito, cumpre referir, a título de exemplo, ao acidente recentemente provocado na Bacia de Campos pela empresa Chevron, que foi amplamente noticiado pela imprensa nacional. Confira-se, ao ensejo, o teor desta reportagem publicada pela Central Globo de Jornalismo na rede mundial de computadores em 10/11/2011:

> **"ANP investiga vazamento de óleo na bacia de Campos**
>
> RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) informou nesta quarta-feira que iniciou investigação sobre um vazamento de óleo em Campos, principal bacia marítima de produção no Brasil.
>
> A mancha de óleo no mar se encontra a cerca de um quilômetro da plataforma do campo de Frade, onde a petroleira norte-americana Chevron mantém o controle da produção.
>
> Embarcações de apoio foram deslocadas ao local para identificar a origem do vazamento e recolher o óleo do mar, informou a reguladora em comunicado.
>
> A ANP informa ainda que tomou conhecimento do acidente na manhã desta quinta-feira.
>
> A Chevron, que possui 51,7 por cento do campo de Frade, diz, em nota, que está 'ciente de um vazamento de óleo localizado entre os campos de Frade e Roncador, na bacia de Campos'.
>
> O campo de Roncador, um dos maiores produtores de petróleo do país, é operado pela Petrobras.
>
> 'A Chevron está investigando a origem do vazamento. Todas as providências estão sendo tomados', informou a companhia, em nota.

[227] Ao ensejo, Luiz Cláudio Cardoso relaciona alguns acidentes que marcaram época, referindo-se, a propósito, aos casos do Torrey Cânion (1967), da barcaça Flórida (1967), do Amoco Cádiz (1978), do petroleiro Valdez (1989), do Prestige (2002) e da explosão de uma refinaria em Noca York, no bairro de Staten Island, em fevereiro de 2003 (CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto.* Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. p. 163). Citando um exemplo local, Cardoso refere, ainda, a um acidente ocorrido na década de sessenta no litoral baiano; nos termos seguintes: "No Brasil, um campo de gás batizado Mapele, localizado na Bacia do Recôncavo, a acerca de 20 Km de Salvador e a poucos metros do acostamento da estrada Rio-Bahia, tornou-se atração turística em 1962. Na finalização da perfuração de um poço, iniciou-se um blowout que se estendeu por um ano e meio, alimentando uma chama que atingiu aproximadamente 80 metros. A pressão do reservatório superou a pressão da lama de perfuração e venceu os equipamentos de segurança, e não obstante todos os esforços para controlar o fogo (perfuração de poços para injeção de água), a chama só parou de queimar quando o reservatório se exauriu" (CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 55).

> A Petrobras possui participação acionária de 30 por cento no campo de Frade, enquanto o consórcio Frade Japão Petróleo detém os demais 18,3 por cento.
>
> O grave acidente no Golfo do México com uma plataforma da BP elevou a atenção de empresas e do órgão regulador no Brasil para a possibilidade de acidentes no país, onde a maioria da produção de petróleo ocorre em mar.
>
> A ANP tem aumentado as exigências em relação a segurança das instalações, o que inclusive provocou paradas não programadas de unidades de produção da Petrobras"[228].

Ainda não se sabe ao certo a extensão dos efeitos desse acidente. Mas os ambientalistas estimam que possa haver prejuízos à fauna marinha. Quanto ao particular, cumpre referir às declarações prestadas pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Minc, ao *site* "estadão.com.br", que relata, em reportagem publicada em 23/11/2011, que "o secretário revelou [...] que a fauna marinha também será prejudicada pelo acidente"[229]. No mesmo sentido se manifestou a bióloga Leandra Gonçalves, Coordenadora da Campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil, conforme retrata reportagem publicada no *site* "correiodopovo.com.br" em 18/11/2011[230]. Enfim, é fato que "vazamentos de petróleo prejudicam de forma intensa e duradoura a vida marinha", sendo que "desde o fitoplacton, base da cadeia alimentar, até as aves, todos sofrem nessa tristes ocorrências"[231], como leciona Luiz Cláudio Cardoso. O que se dá é que, ainda conforme Cardoso:

> "As manchas de óleo impedem ou diminuem a entrada de luz no mar, o que prejudica a fotossíntese dos vegetais, sobretudo o fitoplancton; o óleo também impregna as penas das aves, matando-as por hipotermia, entope as vias respiratórias dos mamíferos, interfere nos químio-receptores de animais migratórios, deixando-os desorientados, afeta as atividades de quem vive da pesca e do turismo, promove, enfim, uma verdadeira devastação"[232].

Disso se depreende o risco de comprometimento da atividade pesqueira desenvolvida pelas populações locais dos Municípios litorâneos situados nas proximidades das áreas de exploração de petróleo.

---

[228] Disponível na internet: <http://extra.globo.com/noticias/economia/anp-investiga-vazamento-de-oleo-na-bacia-de-campos-3174388.html>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

[229] Disponível na internet: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,vazamento-de-oleo-no-rio-pode-chegar-a-15-mil-barris-diz-minc,802152,0.htm>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

[230] Disponível na internet: <http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=361574>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

[231] CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 163.

[232] CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 163.

Especulou-se, ainda, que o óleo liberado pelo acidente poderia chegar às praias do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo; como se infere, a título de exemplo, de reportagem publicada no *site* "gazetaonline.globo.com" em 22/11/2011, da qual se extrai os seguintes excertos:

> "O óleo derramado pela petroleira Chevron no campo de Frade, na Bacia de Campos, pode chegar às praias do Espírito Santo e Rio de janeiro e São Paulo (Ubatuba) dentro de duas semanas. A informação é do Globo Online.
>
> Alerta foi dado por técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, (Ibama) e do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro em reunião com o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc.
>
> 'Cerca de dois terços de todo o óleo derramado, sobretudo aquele mais grosso, ainda está abaixo do espelho d´água. Esse óleo vai passando por processo físicoquímico e vira pelotas que vão acabar nas praias', disse Minc ao Globo Online. Ele acrescentou que tudo vai depender agora das condições climáticas para determinar o tempo que essas "bolas de piche" vão levar para chegar nas praias"[233].

Se essa expectativa se confirmasse, ter-se-ia, também, prejuízo ao turismo praticado nos Municípios litorâneos situados nas proximidades das áreas de exploração de petróleo. Sobretudo quando se tem em vista as proximidades do acidente com o verão, estação do ano em que o litoral brasileiro recebe visitantes de toda parte. Essa atividade econômica tem fundamental importância para o sustento da mão-de-obra local, inclusive daquela que se ocupa da atividade pesqueira, pois a chegada dos turistas também aumenta a venda dos pescados.

A situação de vulnerabilidade dos Estados e Municípios impactados pela indústria do petróleo frente a um acidente deste tipo é potencializada porque as investigações preliminares realizadas pelos órgãos ambientais acerca das causas desse vazamento de óleo atribuído à Chevron apontam no sentido de que a empresa não estava preparada para reagir, com a necessária prontidão, a um evento dessa natureza[234]. Tal se infere, ainda exemplificativamente, de reportagem publicada pelo *site* "uol.com.br" em 24/11/2011, da qual se destaca o seguinte trecho:

---

[233] Disponível na internet: <http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/11/noticias/minuto_a_minuto/nacional/1035212-leo-que-vazou-na-bacia-de-campos-pode-chegar-as-praias-do-espirito-santo.html>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

[234] Quanto ao particular, Luiz Cláudio Cardoso observa que é inerente à atividade de exploração de petróleo, assim como a outras atividades de grande porte, a elaboração de um plano de contingência, "que é um documento onde se define responsabilidades e informações úteis sobre a área envolvida, os recursos disponíveis e as linhas de ação para combater uma emergência de grande porte" (CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 175). E isso porque, "no momento de um acidente, saber o que fazer, isto é,

"Em audiência pública na tarde desta quinta-feira (24) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, disse que a Chevron não sabia como agir no caso do vazamento na bacia de Campos.

Segundo Minc, a Polícia Federal tem depoimentos gravados do coordenador responsável pela segurança da plataforma em que ele disse não saber o que fazer para conter o vazamento.

O representante da Chevron na audiência, Luiz Pimenta, supervisor de meio ambiente, não comentou as declarações de Minc e saiu sem falar com a imprensa. Durante sua explanação, Pimenta disse que a empresa "fez uso de todos os recursos disponíveis para conter o vazamento"[235].

Mas o mais grave disso tudo é que a própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP admitiu a ineficiência da fiscalização que exerce sobre a exploração de petróleo na costa brasileira; conforme noticia a seguinte reportagem, publicada na internet em 29/11/2011 pela central Globo de Jornalismo:

"Agência admite ineficiência na fiscalização

Jablonski, da ANP, reconheceu ainda que a agência é ineficiente na fiscalização e monitoramento de poços de petróleo, devido à falta de equipamento e pessoal. Ele afirmou que são perfurados no Brasil, por ano, 900 poços, enquanto nos Estados Unidos o total é de 20 mil.

— Não posso dizer que examinamos detalhadamente os poços. O que se faz é definir organizações em termos de gestão.

O técnico afirmou que a responsabilidade direta da Chevron no acidente "é total". Disse esperar que aconteça no Brasil o que houve no vazamento do Golfo do México, nos EUA. A BP foi multada em US$ 75 milhões, mas criou voluntariamente um fundo de US$ 20 bilhões para gastos com compensação e limpeza do meio ambiente.

Jablonski enfatizou que há, no Brasil, 78 empresas concessionárias atuando na exploração e produção de petróleo e gás natural. Do total, apenas uma empresa, a Petrobras, detém 93% do total produzido"[236].

Na verdade, especialistas têm afirmado que o Brasil precisa se aparelhar melhor para explorar o petróleo do pré-sal. Ao ensejo, o Secretário Carlos Minc declarou ao *site* "www.istoedinheiro.com.br", em reportagem publicada em

---

ter um plano de ação pré-concebido é condição essencial para o sucesso no combate e eliminação dos seus efeitos", pois "seja um incêndio, vazamento de gás, derrame de óleo no mar ou qualquer outro acidente, a ação tem que ser imediata, a fim de evitar conseqüências desastrosas" (CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 176), como observa Cardoso na seqüência. Por isso é que, conforme Cardoso, "a convocação e movimentação rápida de pessoal e dos equipamentos devem ser objetivos prioritários em qualquer plano de ação" (CARDOSO, Luiz Cláudio. *Petróleo: do poço ao posto*, cit., p. 176).

[235] Disponível na internet: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/11/24/responsavel-da-chevron-disse-que-nao-sabia-como-agir-afirma-minc.jhtm>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

[236] Disponível na internet: <http://oglobo.globo.com/economia/chevron-podera-voltar-explorar-petroleo-no-brasil-diz-anp-3345372>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

24/11/2011[237], que esse acidente deve servir de "alerta vermelho" para as autoridades brasileiras, pois se "um só poço teve problemas, [...] o pré-sal terá mil deles". De seu turno, Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, declarou à mesma reportagem que "o acidente da Chevron mostra que extrair petróleo do mar não é uma tarefa simples"[238]. Segundo Pires, "nem o Brasil nem o resto do mundo estão preparados para responder rapidamente a um acidente petroleiro no mar, e com o pré-sal as dificuldades serão ainda maiores devido à profundidade"[239]. Pires recobra, na seqüência, o acidente ocorrido no golfo do México, também citado por Barroso, e acrescenta que muito embora as empresas exploradoras venham desenvolvendo métodos sofisticados para a extração do petróleo em alto mar, os métodos para enfrentar vazamentos e proteger o ambiente "deixam a desejar"[240]. Opinião semelhante foi manifestada, na oportunidade, por Alessandra Magrini, professora de planejamento energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para Magrini, "é preciso preparar melhor os organismos de controle", com destaque para a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP[241]. A propósito, Magrini ressalta que apesar de a legislação brasileira fixar critérios para a aplicação de multas às empresas exploradoras, "não há nada para avaliar os danos causados", e conclui que "o Brasil ainda possui muito a evoluir em relação aos trabalhos no pré-sal"[242].

Portanto, é factível que acidentes dessa natureza voltem a se repetir. Aliás, conforme também restou noticiado pela imprensa nacional, no ano de 2010

---

237 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

238 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

239 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

240 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

241 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

242 Disponível na internet: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/74191_VAZAMENTO+DE+PETROLEO+DA+CHEVRON+FAZ+O+ALARME+DE+ALERTA+SOAR+NO+BRASIL>; acesso em 06 de dezembro de 2011.

a Petrobrás teria derramado no mar quase o dobro da quantidade de óleo liberada nesse acidente com a Chevron. É o que se colhe de reportagem publicada na internet pela Central Globo de Jornalismo em 26/11/2011, da qual se destaca o seguinte trecho:

> **"Petrobras derramou em 2010 quase dobro de óleo da Chevron**
>
> RIO — Os vazamentos de petróleo no Brasil são mais comuns do que se pensa. Só a Petrobras, a maior empresa do setor, encerrou o ano passado poluindo mais e recebendo um grande volume de autos de infração dos órgãos de fiscalização. Em 2010, a estatal registrou 57 vazamentos, contra 56 ocorrências em 2009. O volume de petróleo e derivados derramado cresceu cerca de 163%, pulando de 1.597 mil barris, em 2009, para 4.201 mil barris espalhados na natureza no ano passado, quase o dobro dos 2.400 barris que teriam vazado do poço da Chevron no campo de Frade (Bacia de Campos), onde a Petrobras tem 30% de participação no consórcio de exploração.
>
> O óleo vazado pela Petrobras em 2010 foi o maior em pelo menos quatro anos, segundo levantamento do GLOBO com base em seus relatórios de sustentabilidade. O número ficou acima do Limite Máximo Admissível, índice anual usado pela estatal, de 3.895 mil barris. Especialistas dizem que as empresas não estão investindo o suficiente em sistemas de segurança e ressaltam que os desafios são maiores com o pré-sal.
>
> Segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2010, o Sistema Petrobras recebeu, em 2010, 21 autos de infração ambientais, que geraram multas de R$ 80,75 milhões. O número é 131,04% maior em relação a 2009, quando três autos totalizaram R$ 34,95 milhões. Esses números consideram multas com valores iguais ou superiores a R$ 1 milhão"[243].

Esse quadro se agrava, ainda, porque, como relatou a "Comissão Especial de Análise do Projeto de Lei do Marco Regulatório do Pré-Sal" instituída no âmbito da OAB/ES, e coordenada pelo Conselheiro Federal Luiz Cláudio Allemand, há também o problema das "manchas órfãs", assim consideradas aquelas decorrentes de incidentes de menor magnitude, comumente provocados por fontes não identificadas, e que por isso não são detectados pelos órgãos de fiscalização, não integrando, destarte, as estatísticas oficiais de vazamentos de petróleo no litoral. Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do Relatório publicado por essa Comissão Especial:

> "[...] A comoção social normalmente é associada aos grandes desastres ecológicos, em que ficaram gravadas na memória da sociedade imagens de aves e animais cobertos de óleo, como nos casos dos acidentes envolvendo os navios Torrey Canyon (Reino Unido, 1967), Amoco Cádiz (França, 1978), Exxon Valdez (Alaska, 1989) e o Prestige (Bretanha, 2002), principais responsáveis pela evolução normativa no plano internacional acerca da necessidade do disciplinamento de medidas preventivas de proteção ambiental no mar.
>
> Outros desastres, como o vazamento da BP - British Petroleum (2010), no Golfo do México, continuam a assombrar a sociedade com toneladas de óleo lançadas diariamente no mar, trazendo danos incalculáveis para a comunidade do seu entorno.

[243] Disponível na internet: < http://oglobo.globo.com/economia/petrobras-derramou-em-2010-quase-dobro-de-oleo-da-chevron-3332275>; acesso em 08 de dezembro de 2011.

Contudo, pouco se fala da ocorrência contínua de incidentes de menor monta, que ocorrem principalmente em operações de rotina como carga e descarga e abastecimentos de navios em instalações portuárias e outros procedimentos de praxe, levando-se em conta que 'a maioria dos acidentes marítimos são de pequenas dimensões (menos de sete toneladas)'.

Tal fenômeno se agrava, quando constatado que estes acidentes são relegados a um segundo plano, e em grande parte dos casos não são comunicados às autoridades portuárias e ignorados.

Quando não comunicados e, conseqüentemente, não identificados os agentes promotores daquela poluição, há a ocorrência das chamadas manchas órfãs:

> 'O termo 'manchas órfãs' vem sendo empregado, genericamente como referência ao aparecimento de substâncias oleosas em águas marinhas, estuarinas ou fluviais, cuja fonte poluidora não foi identificada. Por se tratar de uma mancha de óleo 'sem dono', não há a quem se responsabilizar pelo fato. É preciso então haver um consenso prévio entre as autoridades portuária, marítima, ambiental e municipal, bem como entre os representantes dos terminais e operadores portuários, no sentido de estruturar um plano de ação de emergência integrado para este fim específico, quando houver acionamento, bem como para avaliar as despesas relativas aos custos de ações de contenção, remoção, destinação e tratamento dos resíduos gerados'[244].

A gravidade dessas manchas reside no fato de que: (1) Por serem pequenas, não sensibilizam a população, de maneira que em grande parte dos casos são ignoradas e o órgão fiscalizador não é acionado; (2) São danos de ação contínua; (3) Quando analisadas individualmente não apresentam grandes impactos, porém, quando visto o contexto ambiental como um todo, no qual se tem diversas manchas 'pequenas' de variadas origens e tipologias, equivale-se a uma mancha de grande proporção e mitigação mais complexa; (4) quando acionado o órgão fiscalizador, o mesmo demanda tempo para identificar o responsável e autuá-lo para apresentar as medidas compensatórias, conforme o princípio do poluidor pagador[245]; (5) não sendo identificado o agente causador do dano, os custos de reparação recaem sobre a sociedade, por meio do ente lesado, que, nesse caso, teria a necessidade de se utilizar de recursos públicos que não estariam previstos para aquela destinação. Tal fato significa que, para a realização deste ato, haverá a necessidade se retirar recursos que seriam destinados para outras áreas que, quando não atendidas, podem gerar riscos para a vida ou a sua qualidade, como são os casos envolvendo saúde, educação, saneamento básico e outros direitos fundamentais.

Portanto, a sociedade normalmente se preocupa com os vazamentos de óleo em grande escala, cujo medo da ocorrência se pauta em termos emocionalmente apelativos (imagens de animais encobertos de óleo e paisagens naturais degradas, por exemplo), enquanto se esquece dos recorrentes incidentes de menor escala, cuja probabilidade de ocorrência é infinitamente maior. Tal enfoque resulta na formulação de medidas regulatórias pautadas em uma falsa estimativa da probabilidade, apresentando-se, dessa forma, insatisfatórias aos casos mais corriqueiros.

Daí a importância de se dar maior atenção na regulação da precaução e prevenção com a questão dos acidentes de pequenas dimensões envolvendo óleo, em especial as 'manchas órfãs', que tem se tornado cada vez mais constantes e imperceptíveis.

---

[244] CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Manchas órfãs. Disponível em: <www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/mancha/mancha.asp+%22manchas+%C3%B3rf%C3%A3s%22&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br>. Acesso em: 15 de julho de 2008.

[245] BORGES, Orlindo Francisco. *A utilização dos royalties do petróleo na gestão de riscos ambientais decorrentes da atividade petrolífera: uma ponderação a partir da problemática envolvendo "manchas órfãs"*. In: BENJAMIN, Antonio Herman; IRIGARAY, Carlos Teodoro; LECEY, Eladio; CAPPELI, Sílvia (Orgs). 15º Congresso Internacional de Direito Ambiental - Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos: Homenagem ao professor Leonardo Boff. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, v. 02. p. 407-427.

> Logo, não restam dúvidas que os riscos envolvendo derramamento de óleo no mar, principalmente na costa de estados e municípios produtores de petróleo, não são improváveis. Muito pelo contrário, sua potencialidade é inquestionável, motivo pelo qual se torna imperiosa uma regulação voltada à prevenção e precaução desses danos, o que gera custos ao ente produtor, maior lesado pela potencialidade de tais impactos"[246].

São, pois, evidentes os riscos ambientais da atividade de exploração de petróleo no litoral brasileiro. Também são manifestos os seus reflexos sobre as contas públicas dos Estados e Municípios situados nas proximidades dos campos de produção desse recurso natural, que vêem afetado o modo de vida das suas respectivas populações, e que por isso necessitam dos recursos financeiros corporificados nos *royalties* e participações especiais advindos da exploração petrolífera. Se o pior acontecer, as populações locais só contam com os seus respectivos Estados e Municípios para minimizar os impactos da repercussão de acidentes desse tipo. Até porque, como cediço, nada há no ordenamento jurídico-positivo que obrigue os demais Estados e Municípios a socorrem-nas num evento dessa natureza.

Mas mesmo quando se desconsidera a possibilidade de ocorrência de incidentes desse tipo, que certamente têm reflexos sobre a economia local, não se pode refutar a evidência de que a atividade de exploração de petróleo e gás afeta as contas públicas dos Estados e Municípios produtores e o modo de vida das suas respectivas populações. Com efeito, a implantação/ampliação das plantas empresariais mantidas pela indústria petrolífera nessas unidades federadas por si só induz a elevação do seu gasto público, sendo que, nesse contexto, a única contrapartida financeira que lhes é direcionada são os *royalties* e participações especiais que os dispositivos legais impugnados pretendem distribuir em maior proporção a Estados e Municípios não impactados[247].

---

[246] ALLEMAND, Luiz Cláudio (Coord.). *Relatório da Comissão de Análise do Projeto de Lei do Marco Regulatório do Pré-Sal.* Vitória, OAB/ES, 2010. Disponível na internet: <http://www.oabes.org.br/arquivos/legislacao/legislacao_47.pdf>; acesso em 02 de dezembro de 2010. p. 21-24.

[247] Não sobeja lembrar, a propósito, que os Estados produtores foram privados pela Constituição da receita tributária auferida com tributação pelo ICMS das saídas de petróleo e derivados para outras unidades federadas CRFB, art. 155, p. 2°, X, "b").

Poder-se-ia argumentar, ao ensejo, que a indústria do petróleo traz investimentos, e que isso é bom para a economia local, porque há geração de emprego e renda. Mas essa afirmação é apenas em parte verdadeira.

Não há dúvidas de que a indústria do petróleo gera empregos. Mas não necessariamente para a população local de um Município com esse tipo de estruturação econômica. Seus trabalhadores não têm, em regra, a formação técnica necessária para serem aproveitados na atividade petrolífera e nas atividades de apoio à indústria do petróleo. Por isso, o Município e o Estado precisarão investir recursos financeiros na qualificação da mão-de-obra local, com vistas a tentar minimizar o problema.

Aliás, é muito pouco provável que a atual geração de trabalhadores economicamente ativos desses Municípios (que é composta, como regra, de pescadores e empregados do comércio) possa ser aproveitada pela indústria do petróleo, dadas as naturais deficiências na sua formação básica. Nesse contexto, o papel do poder público será o de qualificar as gerações futuras e de procurar minimizar os efeitos da chegada de novos trabalhadores sobre o ambiente social, como forma de garantir que a geração atual tenha meios de manter os seus filhos na escola, para que eles possam, no futuro, serem integrados como mão-de-obra à indústria do petróleo.

E isso porque, outro efeito da chegada da indústria do petróleo, ou da sua ampliação na base territorial de um Município com essas características, é a elevação do custo de vida. De modo geral, os engenheiros e técnicos que trabalham na indústria do petróleo recebem salários mais altos que os rendimentos da atividade pesqueira e que salários pagos pela indústria do turismo local. Assim, a pressão da demanda sobre o comércio local, quando conjugada a uma maior capacidade financeira dos novos residentes no Município, tende a provocar um aumento nos preços dos alimentos e demais itens de consumo básico. Além disso, esses profissionais passarão a disputar moradias com os trabalhadores que compõem a mão-de-obra local, o que tem a potencialidade de induzir uma elevação dos custos dos aluguéis e dos imóveis. Com isso, parte da população local tende a ser empurrada para bairros mais afastados, gerando um problema de mobilidade urbana. Para minimizar esse problema urbanístico, o Município, com o apoio do Estado, precisará investir na construção de moradias populares, e

também instituir, ou ampliar, serviços de transporte urbano. Pode ocorrer, ainda, de parte da população local vir a concentrar-se nas encostas dos morros, em moradias improvisadas, gerando favelização, com reflexos sobre a criminalidade; o que exigirá mais investimentos em programas de inclusão social e maiores gastos com segurança pública.

Nesse mesmo sentido se pronunciou a "Comissão Especial de Análise do Projeto de Lei do Marco Regulatório do Pré-Sal" instituída no âmbito da OAB/ES; como se infere do seguinte trecho do seu Relatório:

> "[...] os impactos sociais decorrentes do desenvolvimento de uma atividade econômica desproporcional, como a petrolífera, são concretos.
>
> É inegável que a atividade petrolífera atrai outras indústrias de suporte, e, juntamente com elas, demanda uma abundante mão-de-obra. Em atendimento a esta demanda, há um fluxo de trabalhadores para estas cidades, muitas vezes, não-especializados e com renda insuficiente para suportar um mercado imobiliário supervalorizado.
>
> Quando não enquadrados aos padrões imobiliários existentes na localidade, esta população tende a se instalar em áreas invadidas, bem como em manguezais, morros, e encostas, acarretando em um crescimento desordenado dessas cidades.
>
> Ademais, além da significativa demanda por serviços públicos e obras de infraestrutura, há um aumento nos índices de desemprego local, acarretando o surgimento de bolsões de pobreza e aumento da criminalidade local.
>
> Exemplo disso é o município de Macaé, no Rio de Janeiro, escolhido na década de 1970 pela Petrobras para sediar suas atividades de prospecção e exploração na Bacia de Campos. Chamada de capital brasileira do petróleo, Macaé teve um aumento demográfico de 75.000 habitantes em 1980, para mais de 150.000 em 2005, possuindo 14 grandes favelas e ocupando a 815ª posição nacional do Índice de Desenvolvimento Municipal (17ª do Estado). No ano de 2006, 53% do orçamento do município decorreram de royalties do petróleo, com os quais precisa criar 4.000 novas vagas nas escolas todo ano para novos alunos e 3.000 imóveis para acabar com as invasões[248].
>
> Este fenômeno é o principal fator responsável pelos principais impactos sociais decorrentes da instalação destas indústrias. Isto porque, este deslocamento abrupto de trabalhadores para uma localidade ainda desestruturada para comportar este fluxo, resta por vitimizar toda uma sociedade.
>
> Por tais razões, há a necessidade de implementação de políticas estruturantes, não só para receber esta atividade, como para diversificar a sua atividade, posto se tratar da exploração de um bem finito"[249].

Mas há, ainda, um último aspecto que deve ser mencionado a propósito da identificação dos impactos da atividade de exploração de petróleo e gás sobre os chamados Estados e Municípios produtores.

[248] FILGUEIRAS, Sofia Varejão. *A vinculação dos municípios aos direitos sociais e os royalties do petróleo.* Dissertação de Mestrado, FDV, 2006. p. 122.

O petróleo e o gás natural são recursos naturais não-renováveis, o que faz com que, com o decurso do tempo, sua produção se encerre. Assim, são necessários, também, investimentos para prevenir os efeitos do declínio da produção, como forma de preservar direitos fundamentais das gerações futuras, em especial o seu direito a uma existência digna, reproduzido, na Constituição, sob a expressão "dignidade da pessoa humana" (art. 1º, III[250]), assim como o seu direito ao trabalho (art. 5º, XIII[251]) e ao meio ambiente equilibrado (art. 170, VI[252]).

Ao ensejo, vejamos o exemplo do Município de Macaé, situado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

Conforme estudo publicado por Fernando Marcelo Manhães Tavares no *site* da Universidade Federal Fluminense – UFF[253], Macaé era "uma pequena cidade de economia voltada basicamente para a agricultura (cana), pecuária bovina e pesca", que passou "a sofrer os primeiros impactos a partir de 1974, principalmente no que diz respeito à especulação imobiliária fomentada pelas primeiras movimentações da Petrobras na cidade"[254]. Ainda segundo Tavares, "a exploração da Bacia de Campos começou, entretanto, no final de 1976, com o poço 1-RJS-9-A, que deu origem ao Campo de Garoupa, situado em lâmina d'água de 100 metros", ao passo que "a produção

[249] ALLEMAND, Luiz Cláudio (Coord.). *Relatório da Comissão de Análise do Projeto de Lei do Marco Regulatório do Pré-Sal*, cit., p. 26-27.

[250] CRFB. "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana".

[251] CRFB. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

[252] CRFB. "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)".

[253] TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. *Impactos locais: a experiência de Macaé. Lições para o pré-sal.* Disponível na internet: <http://www.uff.br/macaeimpacto/OFICINAMACAE/pdf/28_FernandoTavares.pdf>; acesso em 03 de dezembro de 2012.

[254] TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. *Impactos locais: a experiência de Macaé. Lições para o pré-sal*, cit., p. 01.

comercial, começou em agosto de 1977, através do poço 3-EM-1-RJS, com vazão de 10 mil barris por dia, no Campo de Enchova"[255].

Essa atividade econômica imprimiu profundas modificações no ambiente econômico e social de Macaé. A propósito, Tavares relata que "Macaé, foi, sem dúvida, o município brasileiro que mais cresceu da década de 1970 aos dias de hoje", registrando crescimento populacional de "cerca de 440% em 36 anos, numa média anual, no período, de 12,23%, passando de 47 mil habitantes em 1974 a 206 mil em 2010" [256].

Esse crescimento populacional desordenado, preordenado por ciclos migratórios de trabalhadores que pretendiam se incorporar à indústria do petróleo, afetou o ambiente local. Quanto ao pormenor, Tavares relata que, ao longo dos anos, Macaé presenciou a invasão de áreas de risco e de preservação permanente, o surgimento de favelas e de bairros periféricos sem infraestrutura, o aumento das demandas por serviços públicos, o aumento da violência, a elevação do custo de vida, a especulação imobiliária[257], entre outros impactos.

Esses impactos vêm sendo suportados, na medida do possível, com recursos provenientes do recebimento de *royalties* e participações especiais. Mas é fato que a qualidade de vida nas cidades litorâneas produtoras de petróleo e gás ainda é ruim.

Quanto ao particular, cumpre referir aos dados apresentados em outro importante estudo sobre o tema, publicado por Faber Paganoto e Olga Maria Schild Becker no *site* da Universidade de Campinas – UNICAMP[258]. Esse trabalho revela que "os

---

[255] TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. *Impactos locais: a experiência de Macaé. Lições para o pré-sal*, cit., p. 01.

[256] TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. *Impactos locais: a experiência de Macaé. Lições para o pré-sal*, cit., p. 02.

[257] Cfr.: TAVARES, Fernando Marcelo Manhães. *Impactos locais: a experiência de Macaé. Lições para o pré-sal*, cit., p. 03.

[258] PAGANOTO, Faber; BECKER, Olga Maria Schild. *Dinâmica Migratória na Capital do Petróleo*. Disponível na internet:

municípios da região Norte Fluminense figuram entre os de maior quantidade de famílias pobres e indigentes, os de piores índices de qualidade de vida e os de piores colocações no IDH dentro do estado do Rio de Janeiro"[259]. Tal se infere desta passagem da exposição de Paganoto e Becker:

> "De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, no norte do estado do Rio de Janeiro e nos seus municípios-pólo, em 1970, os percentuais de indigência (população com renda per capita inferior a 80 reais mensais) eram de 30,80% em Campos e 17,91% em Macaé. Em 1980, Campos passou para 38,13% e Macaé para 33,24%, refletindo o período de expansão e modernização da agroindústria açucareira na região, que eliminou antigos cultivos e gerou um contingente de milhares de bóias-frias, expulsos do campo para a cidade, vivendo em condições precárias de vida e de renda. Em 1991, o índice de indigência de Campos disparou para 52,34% e o de Macaé caiu para 31,88%"[260].

Em verdade, o próprio Município de Macaé admite, em seu *site* oficial, que apesar dos investimentos feitos nas últimas décadas, a qualidade de vida ainda é um problema a ser enfrentado pelo poder público local; como sobressai do seguinte excerto, colhido da apresentação da sua Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico:

> "A cidade de Macaé é o principal ponto de operações *offshore* no Estado do Rio desde a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, no final da década de 70. A indústria do petróleo trouxe muitos impactos positivos, como investimentos e geração de trabalho e renda. Porém, também trouxe o crescimento desordenado do município, passivo social e ambiental, além da desestruturação de segmentos tradicionais como a agricultura e a pesca.
>
> Pela grande oferta de empregos das empresas instaladas, houve também expressivo contingente de pessoas vindas de outros municípios em busca de oportunidade, porém não alocadas no mercado de trabalho pela baixa qualificação e nível de escolaridade, acarretando favelização de algumas localidades. Entre as conseqüências, aumento da violência urbana e a diminuição da qualidade de vida"[261].

Ora, se esses problemas são depreendidos agora, quando ainda está ativa a indústria petrolífera, é de se imaginar que, no futuro, quando se exaurirem as reservas desse recurso natural, o quadro enfrentado por Macaé, assim como pelos demais Municípios produtores de petróleo, com reflexos sobre seus respectivos Estados, será ainda mais grave. Como empregar esse enorme contingente de mão-de-obra que

---

<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/5EncNacSobreMigracao/public_din_mig_cap.pdf>; acesso em 03 de dezembro de 2012.

[259] PAGANOTO, Faber; BECKER, Olga Maria Schild. *Dinâmica Migratória na Capital do Petróleo*, cit., p. 10.

[260] PAGANOTO, Faber; BECKER, Olga Maria Schild. *Dinâmica Migratória na Capital do Petróleo*, cit., p. 10.

[261] Disponível na internet: <http://www.macae.rj.gov.br/sedec/conteudo?id=1391>; acesso em 03 de dezembro de 2012.

migrou para as frentes de produção do petróleo? Como sustentar os custos da elevada demanda social por serviços públicos provocada por esse acréscimo populacional?

Por isso é que, como exposto, a distribuição de *royalties* e participações especiais aos Estados e Municípios impactados (Estados e Municípios produtores) também tem por finalidade a construção de alternativas econômicas para a utilização dessa mão-de-obra, de modo a que, no futuro, essas unidades federadas ostentem condições materiais para fazer frente às necessidades dessa população. Essa demanda não se estende aos Estados e Municípios que não são impactados pela exploração de petróleo (Estados e Municípios não-produtores), que não amargam ampliação do seu contingente populacional e que, por isso, não suportam elevação do seu gasto público com as prestações básicas que devem ser garantidas ao cidadão.

Por todo o exposto, é patente a desequiparação entre Estados e Municípios produtores e não-produtores frente aos riscos e custos inerentes à atividade de exploração de petróleo e gás; o que torna não-isonômica a iniciativa do legislador por procurar conferir a um e outro grupo de entes federados tratamento legislativo paritário: os Estados e Municípios produtores, porque suportam os riscos e os ônus próprios dessa atividade econômica, merecem, certamente, tratamento diferenciado por parte do legislador, como mereceram do constituinte originário quando da concepção do texto do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição[262].

2.2.2.2. Desequiparação entre Estados e Municípios produtores e não-produtores frente ao discrimine estabelecido pela alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição.

Esse quadro se agrava quando se tem em vista que, pelas razões dantes expostas, o constituinte privou os Estados produtores da tributação pelo ICMS das saídas de petróleo e derivados para outras unidades federadas, dada a imunidade

[262] CRFB. "Art. 20 [...] § 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

tributária prevista na alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição[263-264]. E isso porque, como dito:

> **(a)** esse dispositivo impôs aos Estados e Municípios produtores, como salvaguarda dos interesses de Estados e Municípios não-produtores, relevante perda financeira, pautada na imunidade para a tributação pelo ICMS das operações relativas às saídas de petróleo para outras unidades federadas, quando estabeleceu que esse imposto não incide sobre operações que destinam petróleo e derivados a outros Estados;
>
> **(b)** esses recursos acabam destinados, na prática, a Estados não-produtores de petróleo, porque o ICMS é tributo não-cumulativo, por disposição expressa do inciso I do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição[265], o que autoriza o contribuinte a deduzir o imposto cobrado nas operações anteriores (que, para a hipótese, seria recolhido pelos Estados produtores) do imposto devido nas operações subseqüentes, mediante creditamento[266], e faz com que

[263] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[264] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 102-103, passim.

[265] CRFB. "Art. 155 [...] §2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal".

[266] Reitere-se, quanto ao particular, o posicionamento pretoriano consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para quem a imunidade contemplada pela aliena "a" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição foi instituída apenas para efeito de evitar a tributação do petróleo pelo Estado de origem, possibilitando, com isso, ao Estado destino a cobrança do tributo em sua totalidade; como se infere, a título exemplificativo, do seguinte julgado: "TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. **Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo**. Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido" (STF. RE 198088/SP. Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento: 17/05/2000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação DJ 05-09-2003 PP-00032).

a referida desoneração tributária acabe beneficiando toda a cadeia de consumo, favorecendo, com isso, todo e qualquer Estado em cujo território se realizarem operações de circulação de petróleo e derivados (gasolina, gás natural, lubrificantes, etc.);

(c) também os Municípios situados nos Estados não-produtores acabam beneficiados, porque o inciso IV do artigo 158 da Constituição confere a eles parcela do ICMS arrecadado pelos seus respectivos Estados[267].

Assim, o que se depreende da leitura conjugada do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição com aliena "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155 é que o constituinte conferiu aos Estados e Municípios produtores as participações governamentais advindas da exploração do petróleo (*royalties*, participações especiais, etc.) e aos Estados e Municípios não-produtores a arrecadação do ICMS incidente sobre as referidas operações, inclusive daquelas que seriam originalmente tributadas pelos Estados produtores. Essa intenção do constituinte foi externada pelo Ministro Nelson Jobim ao Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 24.312/DF[268], a que dantes se referiu.

---

[267] CRFB. "Art. 158. Pertencem aos Municípios: [...] IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

[268] A propósito, recobre-se que o Ministro Jobim, reportando-se à sua experiência pessoal como parlamentar constituinte, fez o seguinte relato aos seus pares no Supremo Tribunal Federal: "Em 1988, quando se discutiu a questão do ICMS, o que tínhamos? Houve uma grande discussão na constituinte sobre se o ICMS tinha que ser na origem ou no destino. A decisão foi que o ICMS tinha que ser na origem, ou seja, os Estados do Sul continuavam gratuitamente tributando as poupanças consumidas nos Estados do Norte e do Nordeste. Aí surgiu um problema envolvendo dois grandes assuntos: energia elétrica - recursos hídricos – e petróleo. Ocorreu o seguinte: os estados onde ficasse sediada a produção de petróleo e a produção de energia elétrica acabariam recebendo ICMS incidente sobre o petróleo e energia elétrica. O que se fez? Participei disso diretamente, lembro-me que era, na época, o Senador Richard quem defendia os interesses do Estado do Paraná e o Senador Almir Gabriel quem defendia os interesses do Estado do Pará, além do Rio de Janeiro e Sergipe, em relação às plataformas de petróleo. Então, qual foi o entendimento político naquela época que deu origem a dois dispositivos na Constituição? Daí porque preciso ler o § 1° do Art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos da Constituição Federal. O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados - petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica, - ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. [...] Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos Estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o § 1° do artigo 20 [...]".

2.2.2.3. A distribuição dos *royalties* e participações especiais em maior proporção a unidades federadas não impactadas pela exploração de petróleo e gás como escolha não-isonômica.

Por um e outro argumento, isto é, seja porque os Estados e Municípios produtores e não-produtores não se encontram em situação semelhante frente aos riscos e custos inerentes à exploração petrolífera, pois somente os primeiros são impactados pelo exercício dessa atividade econômica, seja porque a própria Constituição os distinguiu, quanto a esse aspecto, quando concebeu, na aliena "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155[269], imunidade para a tributação das saídas de petróleo e derivados pelos Estados produtores, o legislador não pode atribuir tratamento normativo mais vantajoso aos Estados e Municípios não-produtores acerca da destinação da compensação financeira prevista pelo parágrafo 1º do artigo 20 da mesma Carta Política[270], de modo a distribuir-lhes, em maior proporção, receitas financeiras decorrentes do pagamento *royalties* e participações especiais. O que se dá é que, como a verdadeira igualdade pressupõe o tratamento paritário aos iguais e tratamento diferenciado aos desiguais, a distribuição de *royalties* e participações especiais em maior proporção a unidades federadas que não são impactadas pelo exercício dessa atividade econômica (Estados e Municípios produtores) é também ofensiva ao princípio da isonomia, de que trata o artigo 5º da Lei Maior[271].

2.2.3. Ofensa ao princípio federativo (CRFB, art. 1º e art. 60, p. 4º, I).

Essas mesmas circunstâncias (de os Estados e Municípios produtores e não-produtores não se encontrarem em situação semelhante frente aos

[269] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[270] CRFB. "Art. 20 [...] § 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

[271] CRFB. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]".

riscos e custos inerentes à exploração petrolífera e de a própria Constituição os haver distinguido quando concebeu a imunidade tributária prevista na aliena "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155[272]) induzem a conclusão de que a distribuição dos *royalties* e participações especiais em maior proporção a Estados e Municípios não impactados pela exploração de petróleo e gás é também ofensiva ao princípio federativo[273], a que referem os artigos 1º e 18 da Carta de 1988, e também o inciso I do parágrafo 4º de seu artigo 60; que têm a seguinte redação:

> **CRFB**
>
> **Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...].
>
> [...]
>
> **Art. 18.** A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição".
>
> [...]
>
> **Art. 60** [...]
>
> [...]
>
> **§ 4º** - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
>
> **I** - a forma federativa de Estado.

O princípio federativo advém da idéia Federação. A propósito, Michel Temer leciona que o Estado Federal surgiu com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos da América[274], tendo por base o seguinte retrospecto histórico:

> "As treze colônias inglesas, ao se liberarem da dominação inglesa, constituíram Estados soberanos (ordens jurídicas independentes) que firmaram um tratado internacional criando a Confederação.
>
> Posteriormente, em face das dificuldades para a execução daquele tratado internacional, políticos e juristas norte-americanos, como John Jay, Alexander Hamilton e James Madison pregaram a necessidade do estabelecimento de outro pacto entre os Estados contratantes de modo a que a união entre eles fosse duradoura.
>
> Convocou-se uma reunião dos Estados em Filadélfia para a discussão dessa tese e, eventualmente, de uma Constituição reunificadora, pois pretendia-se a revisão dos 'Artigos da Confederação'.

---

[272] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[273] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 105-115, passim.

[274] TEMER, Michel. *Elementos de Direito Constitucional.* 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 68.

A essa Convenção os Estados mandaram representantes, verdadeiros embaixadores seus, que levavam a ela a manifestação da vontade dos Estados norte-americanos.

Vencida a resistência de alguns Estados que não pretendiam abdicar de sua soberania, foi editada a Constituição, a qual previu que 'os poderes legislativos conferidos pela presente constituição serão atribuídos ao Congresso dos EUA, composto do Senado e da Câmara dos Representantes'" (art. I, seção I)[275].

Segundo Dalmo de Abreu Dallari, "etimologicamente, federação (do latim *foedus*) quer dizer pacto, aliança"[276]. Entre as suas características, descritas por Dallari na seqüência[277], merece ser destacado, no que interessa à discussão empreendida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, que "no Estado Federal as atribuições da União e as das unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competências", e que, por isso, "a cada esfera de competência se atribui renda própria". A propósito, Dallari considera indispensável "que se assegure a quem tem os encargos uma fonte de rendas suficientes, pois do contrário a autonomia política se torna apenas nominal, pois não pode agir, e agir com independência, quem não dispõe de recursos próprios"[278].

Luiz Henrique Travassos Machado atribui a essa correlação entre encargos e fontes de financiamento a expressão "federalismo fiscal", que, em suas próprias palavras, "abrange o aspecto financeiro do relacionamento dos entes federados, além da compatibilidade entre os recursos auferidos e os encargos a serem desempenhados, cujos fundamentos advêm da Constituição Federal, refletindo a forma de Estado adotada"[279]. Machado, como Dallari, adverte que "a autonomia, mormente no seu aspecto financeiro, e a isonomia dos demais entes federados, em cotejo com os encargos que lhes foram atribuídos pela CF/1988, somente podem ser concretizadas através do estabelecimento de um regular fluxo de recursos financeiros, em montante suficiente à manutenção de um equilíbrio fiscal entre receitas e despesas" [280]. Por isso é que se afirma que o princípio federativo remete à autonomia das unidades federadas[281].

---

[275] TEMER, Michel. *Elementos de Direito Constitucional*, cit., p. 68-69.

[276] DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado.* 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 255.

[277] DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, cit., p. 257-259.

[278] DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, cit., p. 259.

[279] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. *Federalismo e os royalties do petróleo,* cit., p. 37.

[280] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. *Federalismo e os royalties do petróleo,* cit., p. 37.

[281] A propósito, confira-se a seguinte passagem doutrinária: "A autonomia, por outro lado, significa autodeterminação conferida ao Estado-membro dentro das fronteiras de competência traçadas pela Constituição

É também por esse motivo que essa autonomia compreende a idéia de autonomia financeira, que, na lição de Fernando Gonzaga Jayme, pressupõe a distribuição de receitas aos entes federativos, conferindo-lhes a possibilidade de "investir os recursos públicos de acordo com as prioridades e os projetos eleitos"[282].

Conforme Michel Temer, essa expectativa de certa forma foi atendida no texto da Carta Política de 1988, que "confere maior soma de competências administrativas e legislativas aos Estados," e lhes dá, em contrapartida, "mais recursos tributários na tentativa de pautar-se por uma verdade: não há verdadeira autonomia sem numerário para a execução de suas tarefas constitucionais"[283].

A propósito, a Constituição dispôs, em seus artigos 153[284], 154[285], 155[286] e 156[287], sobre os impostos que podem ser instituídos por cada uma das unidades

---

Federal, como produto resultante do poder soberano, não se confundindo, portanto, com soberania. Carreia a descentralização, coexistindo uma duplicidade de esferas normativas, uma vez que aos Estados-membros é conferida a capacidade de executar e de elaborar leis, inclusive constituições, mas sempre dentro da competência inscrita na Lei Fundamental, além daquela proveniente da União. Aliás, o grau de autonomia será medido pela profundidade da descentralização político-administrativa, sem interferência de nenhum outro ente da federação, configurando-se verdadeira viga mestra do federalismo, expressando-se através da capacidade de autogoverno, autoadministração, auto-organização e autolegislação. Ao mesmo tempo, em que propicia liberdade de ação, dentro dos limites das competências traçadas pela Constituição, sem interferência jurídica de qualquer outra esfera de poder, requer a disponibilidade de meios financeiros necessários à execução das atividades e das competências que lhe tenham sido fixadas. Do contrário, a descentralização assim operada se constituirá em verdadeira ilusão, servindo, apenas, de justificativa para a posterior centralização das atividades que o ente federado, por falta daqueles recursos, não pôde realizar" (MACHADO, Luiz Henrique Travassos. Federalismo e os *royalties* do petróleo, cit., p. 36).

[282] JAYME, Fernando Gonzaga. *Comentários aos arts. 18 e 19.* In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura. *Comentários à Constituição Federal de 1988.* Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 532.

[283] TEMER, Michel. *Elementos de Direito Constitucional*, cit., p. 72.

[284] CRFB. "Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar".

[285] CRFB. "Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação".

[286] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; III - propriedade de veículos automotores".

federadas, e lhes conferiu, ainda, a instituição de taxas e contribuições de melhorias (art. 145[288]), e também de contribuições destinadas ao custeio da seguridade social (art. 195[289] c/c art. 40[290]), entre outras espécies tributárias[291]. O constituinte também previu a repartição do resultado da arrecadação de tributos federais com os Estados (art. 157[292] e art. 159, I, "a"[293]) e com os Municípios (art. 158, I e II[294]; art. 159, I, "b"[295] e art. 159, p. 3º[296]), e a repartição dos tributos estaduais com os Municípios (art. 158, III e IV[297])[298].

---

[287] CRFB. "Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar".

[288] CRFB. "Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas".

[289] CRFB. "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro; II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; III - sobre a receita de concursos de prognósticos; IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar".

[290] CRFB. "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo".

[291] A União Federal também pode instituir, nos termos da Constituição, contribuições sociais gerais, contribuições especiais de intervenção no domínio econômico (art. 143, p. 2º e 4º), contribuições especiais instituídas em benefício de categorias profissionais (OAB e demais conselhos de classe) e econômicas (IBAA, IBC e SEBRAE) e empréstimos compulsórios (art. 148). De seu turno, os Municípios e o Distrito Federal podem instituir, ainda, a chamada contribuição de iluminação pública (art. 149-A).

[292] CRFB. "Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I".

[293] CRFB. "Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal".

[294] CRFB. "Art. 158. Pertencem aos Municípios: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III".

Mas essas não são as únicas receitas públicas conferidas pelo poder constituinte às unidades federadas como forma de financiar o exercício das suas competências constitucionais. Com efeito, também as receitas patrimoniais atribuídas pelo parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição aos entes federados (contexto em que se inserem os *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás) destinam-se à cobertura de encargos que lhe são atribuídos pelo ordenamento jurídico-positivo[299]. É que essas receitas, na opinião dos constituintes e na designação que correntemente lhe é atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, têm por finalidade compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pela exploração de recursos naturais pelos reflexos dessa atividade econômica sobre suas contas públicas e sobre o modo de vida das suas respectivas populações. Sendo assim, também lhes é aplicável a "verdade" destacada por Temer, na passagem doutrinária dantes referida, pelo que, a supressão desses recursos financeiros, ou de parte deles, aos seus destinatários constitucionais, priva-os dos meios necessários para o desempenho de tais competências, o que afeta a sua autonomia financeira, com reflexos sobre o equilíbrio federativo, pois, reiterando a observação de Temer, "não há verdadeira autonomia sem numerário para a execução de suas tarefas constitucionais"[300].

Nesse sentido manifestou-se, em sede doutrinária, Luiz Henrique Travassos Machado, para quem esse parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição "afina-se com o princípio federativo, presente ao longo da história constitucional brasileira"; conclusão que decorre "do reconhecimento de que as atribuições outorgadas pela Constituição de 1988 aos entes federados demandam recursos para sua execução,

---

[295] CRFB. "Art. 159. A União entregará: I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: [...] b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios".

[296] CRFB. "Art. 159. A União entregará: [...] § 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II".

[297] CRFB. "Art. 158. Pertencem aos Municípios: [...] III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

[298] MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 18-19.

[299] Cfr., a propósito: MACHADO, Luiz Henrique Travassos. *Federalismo e os royalties do petróleo*, cit., p. 38.

[300] TEMER, Michel. *Elementos de Direito Constitucional*, cit., p. 72.

questão central para garantia da autonomia dos entes periféricos"[301]. Machado destaca, ainda, que essas receitas destinam-se à cobertura de danos ambientais e do gasto público necessário à construção/manutenção da estrutura de serviços públicos que dá suporte à exploração de recursos naturais, dispondo, em arremate, que os Estados e Municípios contribuem, com esses recursos, para a "busca pela efetividade de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: garantir o desenvolvimento nacional"[302]. Por isso é que, conforme Machado, "previu-se na própria Constituição Federal, de maneira inédita num diploma dessa categoria, o direito de participação na exploração de recursos naturais, ou compensação financeira, pela exploração de bens pertencentes à União"[303].

Se é verdade que os Estados e Municípios produtores e não-produtores não se encontram em situação semelhante frente à exploração de petróleo[304] e que a própria Constituição os distinguiu quando concebeu a imunidade tributária prevista na aliena "b" do inciso X do parágrafo 2º do seu artigo 155[305], uma iniciativa do legislador por suprimir dos Estados e Municípios produtores parte dos recursos destinados pelo constituinte a cobrir os riscos e os custos da atividade de exploração de petróleo e gás[306] resulta em inadmissível interferência em sua autonomia financeira, com evidente repercussão sobre a estruturação da Federação Brasileira[307].

Não restam dúvidas quanto a ser a União Federal proprietária dos recursos naturais explorados no País, entre eles o petróleo e o gás natural (CRFB, art.

---

[301] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. *Federalismo e os royalties do petróleo*, cit., p. 42.

[302] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. Federalismo e os *royalties* do petróleo, cit., p. 46-47.

[303] MACHADO, Luiz Henrique Travassos. Federalismo e os *royalties* do petróleo, cit., p. 47.

[304] Somente esses e não aqueles suportam os riscos e custos inerentes à atividade.

[305] Nas palavras ao Ministro Nelson Jobim (MS 24.312/DF), a intenção do constituinte foi conferir a esses (Estados e Municípios produtores) as participações advindas da exploração do petróleo e àqueles (Estados e Municípios não-produtores) o ICMS incidente sobre essa atividade econômica.

[306] Essa é a interpretação correntemente atribuída pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal às retribuições financeiras de que tratam o parágrafo 1° do artigo 20 da Constituição.

[307] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 109-113, passim.

20, V, VIII, IX e X[308]). Essa circunstância, aliás, confere ao ente federal parte considerável dos recursos advindos da atividade petrolífera.

Ocorre que a Constituição, no parágrafo 1º de seu artigo 20, conferiu ao legislador federal a tarefa de promover a distribuição de parte desses recursos aos Estados e Municípios. O que se dispôs, a esse respeito, na Carta Política, foi que o legislador federal deve conferir a Estados e Municípios "participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".

A regra é bastante clara: a distribuição de recursos decorre exploração de petróleo e gás[309] no território do Estado ou Município impactado pela atividade extrativista, ou na plataforma continental correspondente ao território, ou no mar territorial correspondente ao território, ou na zona de econômica exclusiva correspondente ao território. E isso porque, como demonstrado anteriormente nesta pela processual, a função conferida ao parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição pelos constituintes e pela interpretação correntemente atribuída a esse dispositivo pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é compensar (ou indenizar) as unidades federadas impactadas pelos reflexos da exploração de determinados recursos naturais sobre as suas contas públicas e sobre o modo de vida de suas respectivas populações, ou seja, pelos riscos e custos inerentes ao exercício dessa atividade econômica.

A propósito, deve ser destacado, ainda, que a distribuição de *royalties* e participações especiais em maior proporção a unidades federadas que não são impactadas pela indústria petrolífera (Estados e Municípios não-produtores) fará com que os Estados e Municípios impactados (Estados e Municípios produtores) tenham que cobrir os riscos e custos inerentes ao exercício dessa atividade econômica com suas receitas

[308] CRFB. "Art. 20. São bens da União: [...] V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; [...] VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos".

[309] Ou de recursos hídricos para geração de energia elétrica, e também de recursos minerais.

ordinárias, já bastante debilitadas pela perda tributária preordenada pela imunidade para a tributação das operações de saída de petróleo e derivados, de que trata a alínea "b" do inciso X do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição[310], com sérios prejuízos à prestação dos serviços públicos básicos às suas respectivas populações (saúde, educação, moradia, saneamento básico, infraestrutura viária, etc.).

Também se demonstrou, anteriormente, a desequiparação entre os Estados e Municípios impactados pela exploração de petróleo e os Estados e Municípios não-impactados, que decorre, entre outros fatores, da circunstância de a implantação/ampliação em seus territórios de plantas produtivas do setor petrolífero impor às unidades federadas impactadas a realização de uma série de despesas com vistas à proteção das suas respectivas populações contra os reflexos dessa atividade econômica, que compreendem, por exemplo, gastos com a preservação da estabilidade da economia local em caso de um acidente ecológico[311], gastos com a qualificação da mão-de-obra local[312], gastos com a construção de moradias populares e com a instituição/ampliação de serviços de transporte urbano[313], etc. Por isso é que, como

[310] CRFB. "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] X - não incidirá: [...] b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".

[311] A propósito, observou-se que um vazamento de óleo numa pequena cidade litorânea, que tem por atividades principais e a pesca e o turismo, tem a potencialidade de desagregar o funcionamento da economia local, vez que tanto a pesca quanto o turismo dependem de praias limpas, e que, conquanto um evento dessa natureza imponha a reparação dos prejuízos ambientais e econômicos pela empresa exploradora, até que isso ocorra o Município, com o apoio do Estado, precisará lançar mão de recursos financeiros para, de alguma forma, minimizar o sofrimento daqueles que tiveram seu meio de vida prejudicado.

[312] Quanto ao particular, assentou-se que a ampliação da base produtiva do petróleo gera gasto público mesmo sem a ocorrência de um acidente dessa natureza, pois a indústria do petróleo não gera empregos imediatos para a população local de um Município com esse tipo de estruturação econômica, vez que seus trabalhadores não têm, em regra, a formação técnica necessária para ser aproveitada pela indústria do petróleo, o que faz com que o Município e o Estado afetados tenham investir recursos financeiros na qualificação da mão-de-obra local.

[313] Ao ensejo, afirmou-se que outro efeito da chegada da indústria do petróleo, ou da sua ampliação na base territorial de um Município com essas características é a elevação do custo de vida, pois, de modo geral, os engenheiros e técnicos que trabalham na indústria do petróleo recebem salários mais altos que os rendimentos da atividade pesqueira e que os salários pagos pela indústria do turismo local, e que, por isso, a pressão da demanda sobre o comércio local pode provocar um aumento nos preços dos alimentos e demais itens de consumo básico. Enfatizou-se, ainda, que esses profissionais passarão a disputar moradias com os trabalhadores que compõem a mão-de-obra local, o que tem a potencialidade de induzir uma elevação dos custos dos aluguéis e dos imóveis, o que fará com que parte da população local seja empurrada para bairros mais afastados, gerando um problema de mobilidade urbana, ou se concentrará em moradias improvisadas, gerando favelização; e que, para minimizar esse problema urbanístico, o Município, com o apoio do Estado, precisará investir na construção de moradias populares, e também instituir, ou ampliar, serviços de transporte urbano.

exposto, os recursos de que dispõem os Estados e Municípios, compostos, em sua maioria, por suas receitas tributárias, destinam-se ao custeio das contraprestações devidas pelo poder público aos cidadãos, como saúde, educação, moradia, saneamento básico, infraestrutura viária, etc; de modo que o que se arrecada em cada um dos Estados e Municípios que compõem a Federação deve ser empregado no custeio dos serviços públicos e em investimentos, com vistas à consecução desses objetivos.

Afirmou-se, ainda, que os *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás destinam-se à cobertura de despesas extraordinárias, decorrentes do impacto da indústria petrolífera sobre as contas públicas das unidades federadas impactadas por essa atividade econômica e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. E que por isso tais prestações não podem ser custeadas com o emprego das receitas ordinárias dos Estados e Municípios produtores, destinadas pela Constituição ao financiamento da saúde, da educação, de moradias, do saneamento básico, da infraestrutura viária, entre outras prestações.

Assim, a pretensão do Parlamento de suprimir, por lei federal, parte substancial do pagamento dessas receitas aos Estados e Municípios impactados (Estados e Municípios produtores) pela indústria petrolífera restringe a autonomia dessas unidades federadas para a execução dos seus próprios recursos orçamentários, que, em vez de serem aplicados em benefício das suas respectivas populações, precisarão ser alocados, forçadamente, para cobrir os riscos e custos de atividade extrativista exercida por particulares, mas sob autorização e em benefício do ente federal. Disso decorre a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio federativo, da distribuição dos *royalties* e participações especiais em maior proporção aos Estados e Municípios que não são impactados por essa atividade econômica (Estados e Municípios não-produtores).

2.2.4. Ofensa ao princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, *caput* e inciso XXXVI).

As modificações implementadas pela Lei nº 12.734/2012 no texto da Lei nº 9.478/1997 também induzem ofensa ao princípio da segurança jurídica,

consagrado no inciso XXXVI do artigo 5º da Carta Política[314], que veda a interferência legislativa no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e na coisa julgada[315]; nos termos seguintes:

> **CRFB**
>
> **Art. 5º** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Com efeito, a aplicação conjugada do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único e do artigo 50-F e parágrafo único, todos da Lei nº 9.478/1997, na redação que lhes conferiu a Lei nº 12.734/2012, fará com que os novos critérios concebidos pelo legislador para a distribuição de *royalties* e participações especiais aos Estados e Municípios sejam aplicados também a áreas já licitadas e que já se encontram em produção. Esses dispositivos prevêem, assim, a modificação das regras no "meio do jogo", com o avanço das demais unidades federadas sobre receitas que já compõem a expectativa de gastos e investimentos dos Estados e Municípios produtores.

José Afonso da Silva leciona que "a segurança é um dos valores que informa o direito positivo", e que, "em verdade, a positividade do direito é uma exigência dos valores da ordem, da segurança e da certeza jurídicas"[316]. O professor paulista observa, ainda, que a segurança jurídica assume, em sentido amplo, "o sentido geral de garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do adjetivo que a qualifica", e que "consiste na garantia de estabilidade e de

---

[314] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 117-127, passim.

[315] CRFB. "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

[316] SILVA, José Afonso. *Constituição e segurança jurídica.* In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coord.). *Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence.* 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 15.

certeza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam de antemão que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se mantém estável, mesmo se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu"[317]. Sob essa ótica, a segurança jurídica relaciona-se com a boa-fé objetiva[318].

Mas a segurança jurídica também se reveste da condição de instrumento de proteção do indivíduo contra o abuso estatal. Quanto ao particular, Regina Maria Macedo Nery Ferrari observa que "a idéia de segurança jurídica está ligada à concepção de Estado de Direito, isto é, com a noção de que em um determinado estado, a lei nasce por todos e para todos e submete todos, inclusive os governantes, o Poder Público, ou seja, a legitimidade do exercício do poder repousa na legalidade, na sua juridicidade"[319]. Mesmo o abuso cometido sob a forma da edição de atos legislativos encontra-se sobre a censura desse princípio jurídico, vez que, como dito, a Constituição veda qualquer intervenção legislativa no direito adquirido, no ato jurídico perfeito e na coisa julgada (art. 5º, XXXVI).

2.2.4.1. Segurança jurídica e boa-fé objetiva.

Barroso considera questionável, em referência ao princípio da segurança jurídica, nos seus desdobramentos sobre a lealdade e a boa-fé, a mudança das regras após a descoberta de novas reservas[320], dispondo, ao ensejo, ser fora de propósito "que a nova disciplina venha a colher os direitos que o Estado do Rio de Janeiro já desfruta em relação aos contratos de concessão em curso"[321]. E acentua que, para essa unidade federada, "a supressão do direito a *royalties* e participações especiais acarretaria grave frustração de expectativa legítima em relação a receitas que aufere há

[317] SILVA, José Afonso. *Constituição e segurança jurídica*, cit., p. 17

[318] A propósito, cfr., por todos: MARTINS-COSTA, Judidth. *A boa-fé no direito privado: Sistema e tópica no processo obrigacional*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

[319] FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. *O ato jurídico perfeito e a segurança jurídica no controle de constitucionalidade*. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coord.). *Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence*. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 215

[320] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 119-120, passim.

[321] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 24.

muitos anos", de modo que a "sua interrupção súbita, sem que se tenha sequer cogitado de uma transição razoável, traz consequências dramáticas", que incluem a "impossibilidade de cumprir obrigações assumidas, tanto de custeio como de investimentos" (conseqüências econômicas) e "a impossibilidade de cumprimento das normas constitucionais orçamentárias (artigo 165, §§ 1º, 2º, 4º e 5º), de normas de direito financeiro (Lei 4.320/64), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e da Lei 9.496/97, que dispõe sobre o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados" (conseqüências jurídicas)[322].

Barroso destaca, nesse contexto, a celebração de contratos entre o Rio de Janeiro e a União Federal, com vistas à antecipação de recursos federais sob a forma de financiamento, mediante prestação de garantia consistente justamente os *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás em áreas já licitadas[323]. Também o Estado do Espírito Santo fez projeções de gastos e assumiu compromissos financeiros tendo em vista as receitas advindas dos campos de exploração confrontantes com seu território; e de igual modo assinou contrato de antecipação de recursos com a União Federal. Nessas oportunidades, o ente federal reconheceu a validade e a segurança dos referidos créditos, o que deu a essas unidades federadas, por ocasião da celebração desses ajustes, a clareza e a segurança de que poderiam contar, no futuro, com os recursos financeiros advindos da produção de petróleo e gás em áreas já licitadas.

Sendo assim, uma modificação ulterior nas regras de distribuição de *royalties* e participações especiais, porque capitaneada pela União Federal[324], mostra-se ofensiva à boa-fé objetiva, que evoca a proibição de *venire contra factum proprium* (ou de voltar contra seus próprios passos). A propósito, Menezes Cordeiro leciona que a locução *venire contra factum proprium* traduz o exercício de uma posição jurídica em

[322] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 24-25.

[323] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 26.

[324] Muito embora o Governo Federal tenha manifestado, por ocasião dos vetos presidenciais opostos à matéria, a sua desconformidade com a opção político-legislativa encartada no artigo 64 da Lei nº 12.351/2010 e com esse particular do texto do PL nº 2564, cuja aprovação pelo Congresso Nacional redundou na conformação atual da Lei nº 12.734/2012, o veículo utilizado para implementá-la é uma lei federal.

contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente[325]. De seu turno, Judidth Martins-Costa, acentua que "a proibição de toda e qualquer conduta contraditória seria, mais do que uma abstração, um castigo", um instrumento tendente a "enrijecer todas as potencialidades da surpresa, do inesperado e do imprevisto na vida humana"[326].

Posto isso, a União Federal, seja porque licitou áreas para a exploração de petróleo e gás nas proximidades das praias dos Estados e Municípios produtores, aplicando, na oportunidade, os critérios de distribuição de recursos previstos na legislação pretérita, e gerando, com isso, a expectativa de receitas para essas unidades federadas, seja porque concedeu os referidos financiamentos aos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tomando como garantia *royalties* e participações especiais advindos da exploração do petróleo e gás em áreas licitadas, não está autorizada a voltar sobre seus próprios passos, para atingir, por opção legislativa ulterior, a receita pública decorrente da exploração desses recursos naturais nas áreas licitadas.

2.2.4.2. Segurança jurídica e intervenção legislativa.

Deve ser destacado, ainda, que essas operações auferem, em tudo e por tudo, a conotação de atos jurídicos perfeitos, visto que consolidadas sobre a lei do tempo do fato (*tempus regit actum*)[327]. E por isso não podem ser alcançadas, validamente, por opções político-legislativas subseqüentes, vez que, como dito, a Constituição põe a salvo de modificações unilaterais, inclusive daquelas promovidas pelo Poder Legislativo, como medida de segurança jurídica, "o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5º, XXXVI).

[325] CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. *Da boa-fé no direito civil*. Coimbra: Almedina, 1984. p. 743.

[326] MARTINS-COSTA, Judidth. *A boa-fé no direito privado: Sistema e tópica no processo obrigacional*, cit., p. 469.

[327] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 120-127, passim.

O conteúdo desse instituto resta explicitado, entre nós, por interpretação autêntica colhida do ordenamento jurídico-positivo, mais especificamente do texto Decreto-lei nº 4.657/42, tradicionalmente designado como Lei de Introdução ao Código Civil, e atualmente qualificado, por modificação legislativa introduzida pela Lei nº 12.376/10, como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nos precisos termos da lei, o ato jurídico perfeito é ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, como se infere do texto do parágrafo 1º do seu artigo 60, que tem a seguinte redação:

> **LICC**
>
> **Art. 6º** A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
>
> [...]
>
> **§ 1º** Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Essa circunstância é destacada por Regina Maria Macedo Nery Ferrari, quando dispõe, em doutrina, que a configuração do ato jurídico perfeito relaciona-se à verificação concreta de "se o ato cumpriu todas as exigências previstas na lei em vigor quando de seu nascimento"[328].

Assim, se o ato foi praticado com base na lei vigente ao tempo da sua consolidação, os seus efeitos estabilizam-se no tempo, não sendo atingidos por novas opções político-legislativas dimanadas pelo Parlamento. O que ocorre é que, conforme Maria Helena Diniz, ato jurídico perfeito é "o negócio, ou ato, jurídico consumado, segundo a norma vigente, ao tempo em que se efetuou, produzindo seus efeitos jurídicos, uma vez que o direito gerado foi exercido"[329].

Em idêntica direção se posiciona Misael Montenegro Filho, para quem o ato jurídico perfeito "representa um direito consumado pela prática de um ato", ou seja, "um direito que nasceu, mas que ainda não foi exercitado"[330]; representa, ainda,

---

[328] FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. *O ato jurídico perfeito e a segurança jurídica no controle de constitucionalidade*, cit., p. 226.

[329] DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado.* 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1.402.

[330] MONTENEGRO FILHO, Misael. *Comentários ao artigo 5º, incisos XXXIV ao XXXVII.* In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura. *Constituição Federal de 1988.* Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 176.

"a prática de um ato, sob a égide de uma legislação, como a concessão da aposentadoria a um servidor; que preencheu todos os requisitos disponíveis na lei velha, que foi revogada pela lei nova"[331]. Na hipótese, adverte Montenegro Filho, "como o ato já foi praticado (concessão da aposentadoria), a lei nova não pode determinar que o servidor volte à ativa"[332]. Nesse mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da prolação do seguinte julgamento:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - MILITAR - ETAPA DE ASILADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ATO JURÍDICO PERFEITO - ALTERAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS [...] 2 - No caso, concluiu-se que, **se no momento da obtenção do benefício o recorrente preencheu todos os requisitos necessários de acordo com a lei em vigor, caracterizando-se como ato jurídico perfeito, não pode a legislação superveniente estabelecer novos critérios, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum** [...] (STJ - EDcl-AgRg-REsp 962.149 - (2007/0142309-4) - 6ª T. - Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura - DJe 01.06.2011 - p. 905) (destaques pessoais).

A propósito, não prospera a alegação de que o ato jurídico perfeito não pode ser invocado, na hipótese, em razão da tese da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, tantas vezes acolhida em julgados do Supremo Tribunal Federal relativos a direitos de servidores públicos[333]. E por duas razões muito simples.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do Tribunal Constitucional não aplica esse entendimento quando está em discussão o regramento, por lei nova, dos efeitos de atos/contratos celebrados sob a égide de regramento pretérito. Tal se infere, a título de exemplo, dos seguintes julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório:

> AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.030/1990. RETROATIVIDADE MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. **É firme, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que não cabe a aplicação da Lei 8.030/1990 a contrato já existente, ainda que para atingir efeitos futuros, pois redundaria em ofensa ao ato jurídico perfeito**. Agravo regimental a que se nega provimento (STF. RE 388607 AgR / BA. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 21/03/2006. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 28-04-2006 PP-00043, EMENT VOL-02230-04 PP-00749) (destaques pessoais).

---

[331] MONTENEGRO FILHO, Misael. *Comentários ao artigo 5º, incisos XXXIV ao XXXVII*, cit., p. 175.

[332] MONTENEGRO FILHO, Misael. *Comentários ao artigo 5º, incisos XXXIV ao XXXVII*, cit., p. 176.

[333] A propósito, cfr., a título de exemplo, o AI- AgR 737404/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, o ARE-AgR 639736/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, o AI 807.800-AgR, Relator Ministra Ellen Gracie, o AI-AgR 633501, Relator Ministro Gilmar Mendes, o AI-AgR 765.708, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e o AI-AgR 720.940, Relatora Ministra Cármen Lúcia.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA - CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - **ATO JURÍDICO PERFEITO - INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL** - CF/88, ART. 5º, XXXVI - **INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES DO AJUSTE NEGOCIAL** - RECURSO IMPROVIDO. - **Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As conseqüências jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação. Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, em sua integralidade, inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda constante do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.** Doutrina e precedentes. - **A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas.** Precedentes (STF. AI 363159 AgR / SP. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 16/08/2005. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação DJ 03-02-2006 PP-00035, EMENT VOL-02219-07 PP-01359) (destaques pessoais).

- Compromisso de compra e venda. Rescisão. Alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição. - Sendo constitucional o princípio de que a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem pública. De outra parte, **se a cláusula relativa a rescisão com a perda de todas as quantias já pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor deste, a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato jurídico perfeito**, porquanto **a modificação dos efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de retroatividade mínima que também é alcançada pelo disposto no artigo 5º, XXXVI**, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e provido (STF. RE 205999/SP. Relator(a): Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 16/11/1999. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJ 03-03-2000 PP-00089, EMENT VOL-01981-05 PP-00991) (destaques pessoais).

- Agravo regimental. - Não tem razão o agravante. Com efeito, **o ato jurídico perfeito a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da Constituição diz respeito ao ato que se aperfeiçoou em período anterior a uma lei que, para não ser retroativa, não pode alcançá-lo, nem aos seus efeitos futuros**. Está, pois, esse conceito ligado ao direito intertemporal, o que não ocorre no caso, em que se sustenta que a não-aplicação de um enunciado do TST - que sintetiza a jurisprudência da Corte e não é norma jurídica posterior ao ato jurídico em causa - é que teria desconstituído a homologação administrativa. Agravo a que se nega provimento (STF. AI 240302 AgR / SP. Relator(a): Min. MOREIRA ALVES. Julgamento: 09/11/1999. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJ 26-11-1999 PP-00092, EMENT VOL-01973-06 PP-01246) (destaques pessoais)[334].

Ao ensejo, deve ser esclarecido que conquanto os contratos celebrados para a exploração de petróleo e gás sob os auspícios da legislação pretérita tenham como partes a União Federal (poder concedente) e as empresas exploradoras (ditas concessionárias), o ente federal atua, neste contexto, como "curador" dos interesses dos Estados e Municípios impactados pela exploração desses recursos

[334] Nesse mesmo sentido: RE- AgR 393021/SP, AI- ED 292979/RS e AI- AgR 340709/SP, todos relatados pelo Ministro Celso de Mello.

naturais, a quem a própria Constituição atribui parcela das receitas patrimoniais auferidas com o exercício desta atividade econômica. Assim, no limite, os Estados e Municípios produtores são representados nesses contratos pela União Federal, precisamente porque os efeitos (notadamente o pagamento de *royalties* e participações especiais pelas empresas exploradoras) também lhes são extensíveis. Mesmo que assim não fosse, a circunstância, referida no tópico anterior, de a União Federal haver firmado contratos de antecipação de receitas com os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tomando como garantia os *royalties* e participações especiais que lhes seriam distribuídos como decorrência da exploração de petróleo e gás nas áreas já licitadas, torna vinculados também os efeitos desses outros contratos, igualmente celebrados sob a vigência da legislação pretérita, o que obsta a sua afetação por lei posterior que estabeleça novos critérios para a distribuição desses recursos a Estados e Municípios.

Em segundo lugar, porque não se cogita, na hipótese, da atribuição de direito adquirido a regime jurídico, mas apenas e tão-somente da preservação dos efeitos da lei antiga, ou, como disse Celso Antônio Bandeira de Mello, "da persistência de seus efeitos em casos concretos, durante o império da nova lei"[335]. Quando ao particular, cumpre referir à lição de Maria Helena Diniz, que adverte, em comentários ao artigo 2.035 do Código Civil Brasileiro[336], que não se pode confundir o ato/contrato em curso de execução com o ato/contrato em curso de constituição, dispondo, a propósito, que a lei nova apenas poderá alcançar este (o ato/contrato em curso de constituição) e não aquele (o ato/contrato em curso de execução), que se qualifica como ato jurídico perfeito[337]. Em suas próprias palavras:

> "[...] se o contrato ou ato jurídico estiver em curso de formação ou de constituição (fato pendente) por ocasião da entrada em vigor da nova lei, esta, quanto aos seus efeitos, se lhe aplicará, por ter efeito imediato, pois não há que se falar em ato jurídico perfeito, nem em direito adquirido, que impede que se perca o que já se adquiriu, visto que nenhum efeito (formalidade intrínseca) foi produzido sob o manto da lei anterior. Mas, em sua formalidade extrínseca (validade) reger-se-á

[335] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Ato Administrativo e o Direito dos Administrados.* São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 114.

[336] CCB. "Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução".

[337] DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado*, cit., p. 1.402.

pela lei velha, pois a nova não poderá alcançar validade ou invalidade de negócio iniciado antes de sua vigência"[338].

Essa advertência de Diniz é perfeitamente aplicável à investigação acerca da preservação dos efeitos do ato jurídico perfeito frente a alterações legislativas posteriores à sua constituição, ou seja, no curso da execução desses efeitos. Afinal, como se sabe, o artigo 2.035 da lei material civil, comentado pela professora paulista na passagem doutrinária dantes referida, procura estender a aplicação da lei nova sobre os efeitos de atos praticados sobre o império da lei antiga, quando prescreve, em literalidade, que "a validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução". A isso, Maria Helena Diniz objetou que somente podem ser afetados por essa regra os atos/contratos em curso de constituição, e não aqueles em curso de execução.

Assim, se o ato já está constituído, ou seja, "já se tornou apto a produzir efeitos, gerando, modificando ou extinguindo direitos", esses efeitos "não poderão ser alcançados por lei posterior", como expressa Diniz na seqüência[339]. Não sobeja lembrar, a propósito, que Kelsen, em sua "Teoria Pura do Direito", qualifica o negócio jurídico como norma jurídica[340]. E que, para Kelsen, é válida a norma posta (negócio jurídico) por autoridade considerada competente por norma superior (lei), desde que observado o procedimento estabelecido nessa mesma norma superior[341]. Sendo assim, somente seria possível afetar a validade dessa norma jurídica (negócio jurídico), e também a sua eficácia, acaso se depreendesse contraposição entre ela e a norma superior (lei) que regulou a sua constituição, isto é, entre o ato/contrato e a lei do tempo do fato. Por isso é que, para Diniz, o artigo 2.035 do Código Civil Brasileiro somente se aplica, de modo a atingir os efeitos de ato/contrato praticado sob o império da lei antiga, quando se depreender a incompatibilidade entre esse ato/contrato e o ordenamento jurídico positivo, vez que os atos/contratos concluídos sob a égide da legislação pretérita somente poderão ser considerados atos jurídicos perfeitos quando se depreender que

[338] DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado*, cit., p. 1.402.

[339] DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado*, cit., p. 1.402.

[340] KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito.* 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 284-290, passim.

[341] KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*, cit., p. 79-119, passim.

esses atos/contratos foram praticados em conformidade com a lei vigente ao tempo da sua concretização, isto é, com a lei do tempo do fato[342].

Transportando essa discussão teórica para a hipótese analisada, tem-se que não pode a lei nova pretender cancelar os atos/contratos celebrados, sob os auspícios da legislação pretérita, com vistas à exploração de petróleo e gás sob o regime de concessão; mesmo que essa exploração ocorra dentro do perímetro designado pelo ordenamento jurídico-positivo como "área do pré-sal"[343], e que a lei disponha que a exploração de petróleo na "área do pré-sal" deva se dar sob o regime de partilha de produção[344]. E isso porque, em razão do princípio da segurança jurídica, e em especial da proteção conferida pela Constituição ao ato jurídico perfeito, a lei nova não atinge da validade dos atos praticados sob o império da lei anterior. De igual modo, o legislador não pode pretender alcançar os efeitos de ato/contrato consolidado sob a legislação pretérita, contexto em que se destaca o pagamento aos Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás nos campos de produção relativos às áreas já licitadas, que persistem regidos pela lei do tempo do fato. Do contrário, ter-se-ia, na espécie, a afetação de ato perfeito e acabado por nova vontade legislativa, em contrariedade ao comando do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição, que dispõe, taxativamente, que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

[342] Tal se infere dessa outra passagem dos comentários da Professora Maria Helena Diniz aos dispositivos analisados: "Convém, contudo, salientar que, para gerar direito adquirido, o ato ou negócio jurídico deverá não só ter acontecido e irradiado seus efeitos em tempo hábil, ou seja, durante a vigência da lei que contempla aquele direito, mas também ser válido, ou seja, conforme aos preceitos legais que os regem" (DINIZ, Maria Helena. *Código Civil anotado*, cit., p. 1.402).

[343] Lei 12.351. "Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: [...] IV - área do pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico".

[344] Lei 12.351. "Art. 3º A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União sob o regime de partilha de produção, na forma desta Lei".

2.2.4.3. A modificação nos critérios de distribuição dos *royalties* e participações especiais relativos a áreas já licitadas como opção político-legislativa ofensiva ao princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto, a modificação na sistemática de distribuição dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração do petróleo, sem por a salvo as operações atinentes às áreas já licitadas, assim como aos contratos firmados tendo por base as receitas inerentes a tais operações, também se contrapõe ao princípio da segurança jurídica, de que trata o precitado inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição.

Esses atos/contratos devem ser preservados, assim como seus efeitos, como medida de segurança jurídica. Afinal, reproduzindo a indagação formulada por Luís Roberto Barroso no parecer dantes referido, "se o princípio da segurança jurídica não for apto a estancar as desastrosas, imprevisíveis e inevitáveis conseqüências narradas acima, difícil imaginar a que fim serviria"[345].

Sendo assim, são inconstitucionais, por ofensa ao princípio da segurança jurídica, os artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, o artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, o artigo 49-B e parágrafo único, o artigo 49-C e parágrafo único, os parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, o artigo 50-A e parágrafo único, o artigo 50-B e parágrafo único, o artigo 50-C e parágrafo único, o artigo 50-D e parágrafo único, o artigo 50-E e parágrafo único e o artigo 50-F e parágrafo único, todos da Lei nº 9.478/1997, na redação que lhes conferiu a Lei nº 12.734/2012.

2.3. Necessidade da atribuição à Lei nº 12.351/2010 de interpretação conforme à Constituição.

O acolhimento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos argumentos anteriormente alinhavados induzirá a declaração da inconstitucionalidade da redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, entre outros dispositivos impugnados, ao artigo 42-B

[345] BARROSO, Luís Roberto. *Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações na distribuição de royalties do petróleo*, cit., p. 25-26.

e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, ao artigo 42-C, bem como ao inciso IV e ao parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, que estabelecem critérios para a distribuição dos *royalties* e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção.

Ocorre que o atendimento do pleito quanto a esse pormenor fará com que a exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, disciplinado pela Lei nº 12.351/2010, instrumentalize-se sem que se dê cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que, como exposto, assegura aos Estados e Municípios a participação no resultado da exploração do petróleo e gás ou compensação financeira pelo exercício dessa atividade econômica. Confira-se, novamente, a redação literal do dispositivo:

> **CRFB**
>
> **Art. 20.** [...]
>
> [...]
>
> **§ 1º** - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

Em síntese, a Constituição expressa que se houver exploração de petróleo e gás (antecedente) deve haver distribuição de participações governamentais (*royalties*, participações especiais, etc.) a Estados e Municípios (conseqüente). Assim, cumpre ao legislador, quando da especificação das condições para a exploração desse recurso natural, dispor sobre a distribuição dessas participações governamentais a Estados e Municípios. Do contrário, o exercício dessa atividade econômica far-se-á em desconformidade com esse parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição.

Como, dadas as inconstitucionalidades suscitadas nos tópicos anteriores, não há na Lei nº 12.351/2010 norma válida a disciplinar a distribuição a Estados e Municípios dessas receitas que a própria Constituição lhes atribuiu, configura-se, na hipótese, a existência de lacuna no ordenamento jurídico-positivo, lacuna essa que, dada a posição de supremacia da Constituição, em tese torna inconstitucional a integralidade do texto da Lei nº 12.351/2010 e, por conseguinte, o próprio regime de partilha de produção. Com efeito, a instituição de um novo regime de exploração desses

recursos naturais sem que, para tanto, sejam previstas regras válidas para distribuição de participações governamentais a Estados e Municípios corresponderia a admitir que a exploração de petróleo e gás pode ocorrer sem que sejam direcionados aos Estados e Municípios a participação no resultado dessa atividade econômica ou compensação financeira pelo seu exercício, que lhes é garantida pelo parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição.

No entanto, a questão pode ser solucionada, tecnicamente, com a atribuição à Lei nº 12.351/2010 de interpretação conforme a Constituição[346], de modo a que sejam preservadas, ao mesmo tempo, as demais opções político-legislativas encartadas nesse ato legislativo e a regra constitucional que garante aos Estados e Municípios impactados a percepção de participação no resultado da exploração de petróleo e gás ou de compensação financeira pelo exercício dessa atividade econômica (art. 20, p. 1º)[347]. Na falta de norma específica a dispor sobre a distribuição desses recursos sob o regime de partilha de produção[348], cumpre ao intérprete recorrer às regras de integração especificadas no Decreto-Lei nº 4.657/1942, tradicionalmente designado como Lei de Introdução ao Código Civil, e atualmente qualificado como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dadas as modificações legislativas que lhe foram impressas pela Lei nº 12.376/2010.

[346] Semelhante atuação embasa-se em método interpretativo de ampla utilização no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quer em controle difuso, quer em controle concentrado de constitucionalidade, que visa à preservação do princípio da constitucionalidade das leis. Com efeito, se é certo que uma norma legal não tem validade quando estiver em choque com o que prescreve o texto constitucional, também é verdade que os operadores do Direito devem evitar, a todo custo, afirmar a invalidade constitucional de tais prescrições normativas abstratas, em favor das quais milita presunção de constitucionalidade. Diante desse paradoxo, surgiu, na Alemanha, a teoria da "interpretação conforme a Constituição", que prescreve que, diante de normas com várias significações possíveis, caberá ao intérprete encontrar um significado que apresente conformidade com o ordenamento constitucional, evitando, assim, a declaração da sua inconstitucionalidade (A propósito, cfr., por todos: MENDES, Gilmar Ferreira. *Jurisdição Constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha*. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 346-349).

[347] Tese jurídica sustentada na obra "Royalties de petróleo e Federação" (MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit.).

[348] À míngua da edição de norma válida sobre o tema, as operações realizadas sob o regime de concessão persistem regidas pela Lei nº 9.478/1997.

A propósito, o legislador impõe ao aplicador reportar-se, como critério integrativo, à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito[349], como se infere do texto do artigo 4º desse diploma legal:

> **LICC**
>
> **Art. 4º** Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Quanto ao particular, a professora Maria Helena Diniz leciona que "para integrar a lacuna, o juiz recorre, preliminarmente, à analogia"[350-351]. Conforme Diniz, esse critério integrativo "consiste em aplicar, a um caso não contemplado de modo direto ou específico por uma norma jurídica, uma norma prevista para hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado"[352]. Assim, "a analogia não cria norma alguma; simplesmente desvenda, ou descobre, a norma implícita existente", e por isso "serve à expansão lógica das leis, mas nunca elabora direito novo; é um veículo de explicitação de norma latente, revelando o já, virtualmente, contido na norma jurídica, que possui a potencialidade de adaptar-se ao caso não previsto pelo seu elaborador"[353], como expressa Diniz na seqüência.

Na hipótese, em razão do veto aposto pela Presidência da República aos dispositivos da Lei nº 12.351/2010 que tratavam da distribuição a Estados e Municípios das participações governamentais advindas da exploração de petróleo e gás (cuja redação foi extraída da chamada Emenda Ibsen-Simon[354]), e dadas as

---

[349] Sobre a argumentação que se segue, cfr., MADUREIRA, Claudio Penedo. *Royalties de petróleo e Federação*, cit., p. 140-148, passim.

[350] DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica. Norma jurídica e aplicação do direito.* 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 461.

[351] Sobre o assunto, ler também: DINIZ. Maria Helena. *As lacunas no direito.* 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 141-142.

[352] DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*, cit., p. 461.

[353] DINIZ. Maria Helena. *As lacunas no direito*, cit., p. 155-156.

[354] Como exposto, a chamada Emenda Ibsen-Simon advém, na verdade, de duas Emendas Parlamentares: uma primeira, proposta à Câmara dos Deputados pelo Deputado Federal Ibsen Pinheiro (Emenda Ibsen), e uma outra, apresentada no Senado pelo Senador Pedro Simon (Emenda Simon). O seu tratamento conjunto pelos meios de imprensa, qualificando-as simplesmente como Emenda Ibsen-Simon, decorre da circunstância de serem idênticos os seus conteúdos, com exceção, apenas, de um acréscimo promovido pelo Senador Pedro Simon, que previu o pagamento de compensações financeiras aos Estados e Municípios produtores pelas suas perdas de recursos em termos nominais. Em síntese, ambas as Emendas previam a distribuição indistinta a todos os Estados e Municípios dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo. Essa

inconstitucionalidades que contaminam os dispositivos legais modificados/instituídos pela Lei nº 12.734/2012, não há norma válida a disciplinar o pagamento dessas retribuições financeiras quando a exploração de petróleo se der sob o regime de partilha de produção.

Ocorre que a Lei nº 9.478/1997, que disciplina a exploração de petróleo sob o regime de concessão, prevê critérios para o pagamento dessas retribuições aos seus destinatários constitucionais, inclusive aos Estados e Municípios. Tal se infere do texto de seus artigos 48 e 49, e respectivos parágrafos, que têm a seguinte redação:

> **Lei 9.478**
>
> **Art. 48.** A parcela do valor do *royalty*, previsto no contrato de concessão, que representar cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. (Vide Lei nº 10.261, de 2001) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)
>
> **Art. 49.** A parcela do valor do *royalty* que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001)
>
> **I** - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:
>
> **a)** cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção;
>
> **b)** quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;
>
> **c)** sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
>
> **d)** 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao meio ambiente por essas indústrias; (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)
>
> **II** - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
>
> **a)** vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores confrontantes;
>
> **b)** vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios produtores confrontantes;
>
> **c)** quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)
>
> **d)** sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

expressão cunhada pela imprensa (Emenda Ibsen-Simon) acabou consagrada, de igual modo, nos meios políticos e jurídicos, e por isso também será empregada neste trabalho, no qual, de um modo geral, as referências a essa opção político-legislativa pela distribuição indistinta de *royalties* e participações especiais a todas as unidades federadas serão atribuídas à chamada Emenda Ibsen-Simon.

e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios;

f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide Decreto nº 7.403, de 2010)

[...]

§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte proporção:

I - 40% (quarenta por cento) ao Ministério de Minas e Energia, sendo 70% (setenta por cento) para o financiamento de estudos e serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fósseis, a serem promovidos pela ANP, nos termos dos incisos II e III do art. 8º desta Lei, e pelo MME, 15% (quinze por cento) para o custeio dos estudos de planejamento da expansão do sistema energético e 15% (quinze por cento) para o financiamento de estudos, pesquisas, projetos, atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos no território nacional; (Redação dada pela lei nº 10.848, de 2004)

II - 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio Ambiente, destinados, preferencialmente, ao desenvolvimento das seguintes atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo as consequências de sua utilização: (Redação dada pela lei nº 12.114, de 2009)

a) modelos e instrumentos de gestão, controle (fiscalização, monitoramento, licenciamento e instrumentos voluntários), planejamento e ordenamento do uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

b) estudos e estratégias de conservação ambiental, uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de danos ambientais; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

c) novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de sistemas de controle de poluição, incluindo eficiência energética e ações consorciadas para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e outras substâncias nocivas e perigosas; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

d) definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental sistemático, agregando o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental específicos, na escala das bacias sedimentares; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

e) sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e combate e resposta à poluição por óleo; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

f) mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

g) estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como para mitigação da mudança do clima e adaptação à mudança do clima e seus efeitos, considerando-se como mitigação a redução de emissão de gases de efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

h) estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacionados ao desmatamento e à poluição atmosférica; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (Incluído pela lei nº 12.114, de 2009)

III - quarenta por cento para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;

IV - dez por cento para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção.

Dada essa referência do artigo 48 da Lei nº 9.478/1997 aos critérios estipulados pela Lei nº 7.990/1089, cumpre referir, em complementação à exposição da disciplina atual da distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios, ao prescreve o artigo 7º desse diploma legal, que confere redação atual artigo 27 da Lei nº 2.004/1953:

> **Lei 7.990**
>
> **Art. 7º** O art. 27 e seus §§ 4º e 6º, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pelas Leis nºs 3.257, de 2 de setembro de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
>
> "**Art. 27.** A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios:
>
> **I** - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;
>
> **II** - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;
>
> **III** - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural".

Esses enunciados prescritivos não têm aplicação direta ao regime de partilha de produção, vez que o legislador, quando o concebeu, construiu regramento paralelo àquele aplicável ao regime de concessão. Mas lhes podem ser aplicados, por analogia, visto que há, na espécie, "caso não contemplado de modo direto ou específico por uma norma jurídica", mas abrangido por "norma prevista para hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado"[355].

Não se desconhece que, para Maria Helena Diniz, a analogia não se presta à integração de normas de ordem pública[356]. Mas isso não impede a aplicação desse método integrativo à hipótese analisada. É que, conquanto a decisão política pelo pagamento de *royalties* e participações especiais aos Estados e Municípios impactados pela exploração de petróleo e gás possa ser qualificada, sob certa ótica, como norma de ordem pública, a supressão da lacuna depreendida na espécie não diz respeito à adoção

[355] Cfr.: DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*, cit., p. 461.

[356] Tal se infere, a título de exemplo, das observações da professora paulista a propósito da aplicação analógica do instituto da união estável a casais homossexuais, colhidas do Volume 5 do seu "Curso de Direito Civil Brasileiro" (DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 5, Direito de Família*. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 51-53).

dessa opção legislativa, que já se encontra assente no ordenamento jurídico-positivo, mais especificamente no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, mas à extensão ao regime de partilha de produção dos critérios de distribuição de recursos atribuídos ao regime de concessão, previstos em normas de cunho eminentemente financeiro, ou patrimonial.

Se tal não puder prevalecer, ou seja, acaso se considere que as regras jurídicas dantes transcritas encerram, sim, conteúdo de norma de ordem pública, porque são indispensáveis para se aferir a existência do direito subjetivo dos Estados e Municípios impactados pela exploração de petróleo e gás quanto ao recebimento de *royalties* e participações especiais, será o caso de se promover a interpretação extensiva daqueles enunciados prescritivos, de modo a torná-los aplicáveis também ao regime de partilha de produção.

A propósito, Maria Helena Diniz observa que "a doutrina não tem tratado com nitidez a questão da interpretação extensiva frente à analogia, confundindo, muitas vezes, esses dois mecanismos"; dada a conotação contemporaneamente atribuída à interpretação, que se desenvolve num plano objetivo e atual bem mais extenso do que aquele que lhe era conferido pela escola tradicional, que procurava atingir a "vontade do legislador"; com o que se estabeleceu "uma grande afinidade entre a interpretação concebida modernamente e a analogia, já que ambas procuram descobrir a vontade da lei, considerando a razão, o espírito e o fim da norma", o que "tornou difícil saber onde termina a interpretação e começa a analogia"[357]. Para Diniz, a analogia e a interpretação extensiva devem ser tidas como espécies de complementação da norma; sendo que, como critério diferenciador, deve-se ter em vista que "a interpretação extensiva, ao admitir que a norma abrange certos fatos-tipos ainda que implicitamente dentro do espírito da lei (*ratio legis*), não é considerada como instrumento integrador", pois, nela, "a norma possui um cerne significativo e uma zona de penumbra, sendo que sua aplicação dentro dos limites dessa zona de penumbra é a interpretação"; ao passo que "na aplicação analógica o juiz terá que ir além do próprio texto legislativo que rege

[357] DINIZ. Maria Helena. *As lacunas no direito*, cit., p. 179-180.

situações típicas, mas que, por razões de similitude, poderia abarcar outras, indo, portanto, além dos limites da zona de penumbra"[358].

Assim, tendo em vista a hipótese analisada, a consideração de que as regras de distribuição de recursos previstas nas Leis nº 7.990/2010 e 9.478/1997 são indispensáveis para se aferir a existência do direito subjetivo dos Estados e Municípios impactados quanto ao recebimento dos *royalties* e participações especiais advindos da exploração de petróleo e gás pressupõe que se admita a possibilidade da extensão dos seus efeitos também ao regime de partilha de produção. Para o caso, os limites da aplicabilidade desses dispositivos situam-se numa "zona de penumbra". A uma porque, se, por um lado, inexiste no ordenamento norma jurídica a cuidar da distribuição de tais receitas quando a exploração de petróleo e gás se der sob o regime de partilha de produção, por outro, não há, no regime pretérito, vedação da aplicação das suas regras de distribuição de recursos a outros regimes de exploração. A duas porque esses dispositivos das Leis nº 7.990/2010 e 9.478/1997 devem ser interpretados conjuntamente com o enunciado prescritivo colhido do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que determina a distribuição dessas receitas a Estados e Municípios afetados sempre que houver exploração desses recursos naturais. Na hipótese, a conjugação desses enunciados prescritivos com a regra constitucional consignada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição aclara a "zona de penumbra" que emerge da sua análise descontextualizada, autorizando a sua aplicação também para regular a distribuição de *royalties* e participações especiais sob o regime de partilha de produção. Há, pois, sob essa ótica, interpretação extensiva, que, conforme Maria Helena Diniz, "desenvolve-se em torno de uma norma para nela compreender casos que não estão expressos em sua letra, mas que nela se encontram, virtualmente, incluídos, atribuindo assim à lei o mais amplo raio de ação possível"[359].

Numa ou noutra hipótese, isto é, admitindo-se ser o caso, quer da integração do direito, com recurso à analogia, quer da sua interpretação extensiva, impõe-se, na espécie, a atribuição à Lei nº 12.351/2010 de interpretação conforme a Constituição, de modo a que, enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais aos Estados e Municípios impactados

[358] DINIZ. Maria Helena. *As lacunas no direito*, cit., p. 180-181.

[359] DINIZ. Maria Helena. *As lacunas no direito*, cit., p. 182.

como decorrência da exploração do petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, devem ser aplicadas às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha de produção as regras estabelecidas pelas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997. Do contrário, ter-se-ia de admitir que o ordenamento jurídico, tal como construído pelas autoridades consideradas competentes por norma superior (Kelsen), é incapaz de regular a exploração desses recursos naturais sob o regime de partilha de produção, vez que, como demonstrado, a Lei nº 12.351/2010 não contempla norma válida que discipline a distribuição de participações governamentais (*royalties*, participações especiais, etc.) aos Estados e Municípios impactados, contrariando, assim, o disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que garante a essas unidades federadas o recebimento de parcela dessa receita pública sempre que houver exploração de petróleo e gás.

Posto isso, além de declarar da inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelas razões alinhavadas nos tópicos precedentes, esse Excelso Pretório também deve atribuir à Lei nº 12.351/2010 interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que, enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e de partilha de produção os critérios de distribuição estabelecidos pelas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997.

3. Medida cautelar.

O direito brasileiro autoriza a concessão da medida cautelar em Ações Diretas de Inconstitucionalidade, mesmo sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Tal se infere da leitura conjugada da alínea "p" do inciso I do artigo 102 da Constituição da República com os artigos 10, 11 e 12 da Lei 9.868/1999, que têm a seguinte redação:

CRFB

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...]

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

Lei 9.868

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

§ 1º O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias.

§ 2º No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal.

§ 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 2º A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

Na hipótese, restam presentes os requisitos necessários à concessão da medida, como se terá a oportunidade de adiante expor e demonstrar.

3.1. Fumaça do bom direito.

A argumentação jurídica anteriormente alinhavada deixa evidente a plausibilidade jurídica da tese defendida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade. Em síntese, demonstrou-se:

(a) que os dispositivos legais impugnados são inconstitucionais, porque contrariam do disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, porque ofendem o princípio da isonomia (CRFB, art. 5º, *caput*), porque ofendem o princípio federativo (CRFB, art. 1º e art. 60, p. 4º, I) e porque ofendem o princípio da segurança jurídica (art. 5º, *caput* e inciso XXXVI);

(b) que o reconhecimento da inconstitucionalidade desses dispositivos faz com que a exploração de petróleo e gás sob regime de partilha de produção contraponha-se ao disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, dada a ausência de previsão na Lei nº 12.351/2010 de regra válida para a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios, o que torna necessária a atribuição àquele diploma legal de interpretação conforme a Constituição, de modo a que se estabeleça que enquanto não for editada regra válida a disciplinar a distribuição dessa receita pública a Estados e Municípios devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha de produção os critérios de distribuição estabelecidos pelas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997.

Apenas por esse motivo já se justificaria a concessão da medida cautelar neste processo.

Contudo, esse não é o único argumento a orientar a suspensão liminar da eficácia dos dispositivos legais impugnados, com a conseqüente atribuição à Lei nº 12.351/2010 de interpretação conforme a Constituição[360].

[360] Registre-se, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal adite a concessão de Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade para conferir ao texto impugnado interpretação conforme à Constituição; como se infere, a título de exemplo, dos seguintes julgamentos: "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME** AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE

A propósito, cumpre acrescentar que os dispositivos legais impugnados vinculam a distribuição de *royalties* e participações especiais aos chamados Estados e Municípios não-produtores à observância dos critérios aplicáveis aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 875/DF, 1.987/DF, 2.727/DF e 3.243/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 62/1989, que disciplina o Fundo de Participação dos Estados. Eis a literalidade da ementa do julgamento:

SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. **MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA**. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), **concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa**, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS" (ADI 4389 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 RDDT n. 191, 2011, p. 196-206 RT v. 100, n. 912, 2011, p. 488-505) e "**AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR**. ART. 91-A, CAPUT, DA LEI 9.504, DE 30.9.1997, INSERIDO PELA LEI 12.034, DE 29.9.2009. ART. 47, § 1º, DA RESOLUÇÃO 23.218, DE 2.3.2010, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. OBRIGATORIEDADE DA EXIBIÇÃO CONCOMITANTE, NO MOMENTO DA VOTAÇÃO, DO TÍTULO ELEITORAL E DE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DO LIVRE EXERCÍCIO DA SOBERANIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. **NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DAS NORMAS IMPUGNADAS**. PERIGO NA DEMORA CONSUBSTANCIADO NA IMINÊNCIA DAS ELEIÇÕES GERAIS MARCADAS PARA O DIA 3 DE OUTUBRO DE 2010. 1. A proximidade das eleições gerais de 3 de outubro de 2010 e a invulgar importância do tema enfrentado na presente ação direta, relativo ao livre exercício da cidadania pela expressão do voto, autorizam o procedimento de urgência previsto no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/99, a fim de que o Tribunal possa se manifestar antes de eventual perecimento de direito. 2. A segurança do procedimento de identificação dos eleitores brasileiros no ato de votação ainda apresenta deficiências que não foram definitivamente solucionadas. A postergação do implemento de projetos como a unificação das identidades civil e eleitoral num só documento propiciou, até os dias atuais, a ocorrência de inúmeras fraudes ligadas ao exercício do voto. 3. A apresentação do atual título de eleitor, por si só, já não oferece qualquer garantia de lisura nesse momento crucial de revelação da vontade do eleitorado. Por outro lado, as experiências das últimas eleições realizadas no Brasil demonstraram uma maior confiabilidade na identificação aferida com base em documentos oficiais de identidade dotados de fotografia, a saber: as carteiras de identidade, de trabalho e de motorista, o certificado de reservista e o passaporte. 4. A norma contestada, surgida com a edição da Lei 12.034/2009, teve o propósito de alcançar maior segurança no processo de reconhecimento dos eleitores. Por isso, estabeleceu, já para as eleições gerais de 2010, a obrigatoriedade da apresentação, no momento da votação, de documento oficial de identificação com foto. 5. Reconhecimento, em exame prefacial, de plausibilidade jurídica da alegação de ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade na interpretação dos dispositivos impugnados que impeça de votar o eleitor que, embora apto a prestar identificação mediante a apresentação de documento oficial com fotografia, não esteja portando seu título eleitoral. 6. **Medida cautelar deferida para dar às normas ora impugnadas interpretação conforme à Constituição Federal**, no sentido de que apenas a ausência de documento oficial de identidade com fotografia impede o exercício do direito de voto" (ADI 4467 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011).

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n.° 875/DF, ADI n.° 1.987/DF, ADI n.° 2.727/DF e ADI n.« 3.243/DF). Fungibilidade entre as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Fundo de Participação dos Estados - FPE (art. 161, inciso II, da Constituição). **Lei Complementar n° 62/1989. Omissão inconstitucional de caráter parcial. Descumprimento do mandamento constitucional constante do art. 161, II, da Constituição**, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2°, incisos I e II, §§ 1°, 2° e 3°, e do Anexo Único, da Lei Complementar n.° 62/1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012 (destaques pessoais).

O que se discutiu, em apertada síntese, naquelas ações de inconstitucionalidade, foi que o critério estabelecido pela Lei Complementar n° 62/1989 não traduz a vontade do legislador constituinte, à consideração de que o inciso II do artigo 161 da Constituição impõe ao Poder Legislativo que o estabelecimento dos critérios de rateio dos fundos deve promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios. Veja-se a redação desse dispositivo constitucional:

CRFB

Art. 161. Cabe à lei complementar:

[...]

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;

Argumentou-se, nas precitadas ações de inconstitucionalidade:

(a) que aquele ato legislativo deveria ter sido elaborado com base em dados objetivos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, mas foi editado, às vésperas do Censo previsto para o ano de 1990, por meio de acordo político entre o Governo Federal e Governos Estaduais;

(b) que, por isso, os coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal, que foram estabelecidos por acordo político e inseridos na Lei Complementar n° 62/1989, deveriam ter vigência provisória, até o exercício financeiro do ano de 1991, de maneira que os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de 1992, seriam fixados em lei

específica, com base na apuração do Censo de 1990 (LC 62, art. 2º, p. 2º);

(c) que, no entanto, sucessivas leis complementares (LC nº 71/1992, LC nº 72/1993 e LC nº 74/1994) prorrogaram as regras previstas pela Lei Complementar nº 62/1989;

(d) que, em resumo, os critérios que deveriam ser estipulados por lei complementar, visando a promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios, nunca foram devidamente fixados, no que reside violação ao disposto no inciso II do artigo 161 da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal acolheu essa argumentação, e declarou a inconstitucionalidade do referido diploma legislativo; como se depreende dos seguintes trechos do Voto condutor daquele julgamento, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:

> "[...] Passados quase vinte anos da edição da lei, ela continua a reger a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, até hoje são aplicados os índices previstos, inicialmente, apenas para os exercícios de 1990 e 1991.
>
> Também chama a atenção o fato de os índices adotados na referida lei não decorrerem da análise de dados e informações que efetivamente retratavam a realidade socioeconômica dos Estados brasileiros à época. Extrai-se, dos autos, que os índices foram definidos, mediante acordo entre os entes federativos, formalizado no âmbito do CONFAZ, com base na média histórica dos coeficientes aplicados anteriormente à Constituição de 1988, quando a apuração se dava tendo como parâmetro os artigos 88 e seguintes do Código Tributário Nacional.
>
> A natureza provisória e o caráter eminentemente político dos índices fixados pela Lei Complementar n. º 62 foram expressamente reconhecidos pelo relator do projeto, Deputado Firmo de Castro, que, nas razões que embasaram a referida proposta, deixou consignado o seguinte:
>
> > (...) Optou-se através deste projeto, de acordo com a sugestão unânime das Secretaria de Fazenda e de Finanças dos Estados, fixar-se, provisoriamente, os coeficientes individuais de participação de cada unidade da Federação no FPE. Isso porque os parâmetros básicos, população e inverso da renda per capita, hoje desatualizados, não proporcionariam o grau de distributividade que todos desejam. Em razão das transformações significativas ocorridas na presente década, as quais estão afetando os perfis especiais de renda e população, será prudente e benéfico para todos que os critérios de distribuição do FPE sejam revistos em profundidade depois da apuração do censo de 1990, com dados atualizados e melhor avaliados após os dois de vigência do novo sistema tributário, o que também se propõe ocorra com o FPH.
>
> Tudo indica, portanto, que se trata de lei editada em virtude do decurso do prazo previsto pelo art. 39, parágrafo único, do ADCT, para viger por período determinado.

O fato de a lei ter sido editada nessas circunstâncias, por si só, não a macula com a pecha da inconstitucionalidade. Até mesmo porque o § 3° ao art. 2° da Lei Complementar n.° 62, consoante salientado, previu a ultra-atividade dos coeficientes de participação então definidos, caso não fosse editada a lei que definiria novos coeficientes de participação com base no censo de 1990.

Vício de inconstitucionalidade parece haver, contudo, no atendimento inadequado da exigência contida no final do art. 160, II, da Constituição, segundo o qual os critérios de rateio dos fundos de participação deveriam promover o equilíbrio socioeconômico entre Estado e entre Municípios.

Da leitura do referido dispositivo constitucional, extrai-se que os critérios escolhidos pelo legislador para o rateio dos fundos de participação somente serão constitucionais se aptos a promoverem a redução das desigualdades regionais e a equalização da situação econômico-financeira dos entes federativos. Trata-se de um comando constitucional de cumprimento obrigatório pelo legislador.

[...]

Por uma questão de lógica, é possível concluir que os únicos critérios de rateio aptos ao atendimento da exigência constitucional são aqueles que assimilem e retratem a realidade socioeconômica dos destinatários das transferências, pois, se esses critérios têm por escopo a atenuação das desigualdades regionais, com a conseqüente promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes federados, revela-se primordial que eles permitam que dados fáticos, apurados periodicamente por órgãos ou entidades públicas (o IBGE, por exemplo), possam influir na definição dos coeficientes de participação. Não se pode pretender a modificação de um determinado status quo, sem que se conheçam e se considerem as suas peculiaridades.

Ademais, deve haver a possibilidade de revisões periódicas dos coeficientes, de modo a se avaliar criticamente se os até então adotados ainda estão em consonância com a realidade econômica dos entes federativos e se a política empregada na distribuição dos recursos produziu o efeito desejado.

Todavia, está claro que não é essa a situação com a qual nos deparamos no tocante à atual disciplina legislativa dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Conforme salientado, há lei destinada a viger apenas por dois exercícios (1990 e 1991) e que, por inércia legislativa, continua a produzir efeitos e a determinar o montante de recursos a ser repassado aos Estados e ao Distrito Federal.

Viola o bom senso imaginar que lei editada em 1989 - apenas com base em médias históricas apuradas à época - ainda possa retratar a realidade socioeconômica dos entes estaduais.

[...]

Verifica-se, ademais, que, apesar de dispor que oitenta e cinco por cento dos recursos serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Lei Complementar n.° 62/1989 não estabelece os critérios de rateio exigidos constitucionalmente; ela apenas define, diretamente, os coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal.

Não parece ser esse o comando constitucional do art. 161, II. Não há dúvida de que o vocábulo "critérios" refere-se a parâmetros, balizas, diretrizes para a definição dos coeficientes de participação. Não competiria, portanto, à lei complementar estabelecer diretamente esses coeficientes. Até mesmo porque, conforme salientado, a participação dos entes estaduais no fundo deve ser lastreada em informações que retratem a realidade, exigência que não se coaduna com a morosidade do processo legislativo.

A fixação de coeficientes de participação mediante a edição de lei complementar, além de não atender à exigência constitucional do art. 161, II, somente se justificaria se aceitável a absurda hipótese segundo a qual os dados atinentes à população, à produção, à renda per capita, à receita e à despesa dos entes estaduais se mantivessem constantes com o passar dos anos.

[...]

Não há dúvida, pois, de que a manutenção de coeficientes de participação fixos há mais de vinte anos revela-se em descompasso com o que determina o art. 161, II, da Constituição, uma vez que tais coeficientes fixados com base na média histórica dos coeficientes aplicados anteriormente à Constituição de 1988, quando a apuração se dava tendo como parâmetro os artigos 88 e seguintes do Código Tributário Nacional - não mais retratam a realidade socioeconômica dos entes federativos.

[...]

Ademais, cumpre registrar que a fixação dos percentuais da LC n.° 62 deveu-se mais a contingências históricas do que a estudos efetivamente realizados à época com a finalidade de apurar a disparidade socioeconômica entre as regiões brasileiras. Segundo os relatos da Assembléia Nacional Constituinte, o projeto inicialmente apresentado limitava o rateio do FPE aos entes estaduais que apresentassem renda per capita inferior à média nacional (basicamente, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Tal projeto foi, no entanto, alterado, com a exclusão, do texto final, da destinação dos recursos do FPE apenas aos Estados mais pobres, mas com a ampliação do percentual do Imposto de IR e do IPI afetados ao Fundo. A Lei Complementar n.° 62, ao definir a destinação de 85% dos recursos do Fundo aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apenas revigorou as disposições do projeto originário, pois 85% do FPE, considerados os novos percentuais do IR e do IPI afetados, representaria o que os Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste receberiam se aprovado o projeto original.

Ante o exposto, outra não pode ser a conclusão senão a de que o art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e o Anexo Único da Lei Complementar n.° 62, de 28 de dezembro de 1989, passados vinte anos de sua edição, não atendem satisfatoriamente à exigência constante do art. 161, II, da Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos.

[...]

Assim, julgo procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI n.° 1.987/DF, ADI n.° 875/DF, ADI n.° 2.727/DF e ADI n.° 3.243/DF), para, aplicando o art. 27 da Lei n.° 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2o, incisos I e II, §§1°, 2a e 3o, e do Anexo Único, da Lei Complementar n. ° 62/1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012".

Essas mesmas razões podem ser invocadas para sustentar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 91/1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios, cujo artigo 1º atribui aos Municípios o coeficiente individual estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 91 da Lei nº 5.172/1966, que tem redação dada pelo Decreto-lei nº 1.881/1981. Eis a redação literal desses dispositivos:

LC 91

Art. 1º Fica atribuído aos Municípios, exceto os de Capital, coeficiente individual no Fundo de Participação dos Municípios - FPM, segundo seu número de habitantes, conforme estabelecido no § 2° do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981.

Lei 5.172

Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o art. 86, serão atribuídos: (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

I - 10% (dez por cento) aos Municípios das Capitais dos Estados;

II - 90% (noventa por cento) aos demais Municípios do País.

[...]

§ 2º - A distribuição da parcela a que se refere o item II deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte:

CATEGORIA DO MUNICÍPIO, SEGUNDO SEU NÚMERO DE HABITANTES	COEFICIENTE
a) Até 16.980	
Pelos primeiros 10.188	0,6
Para cada 3.396, ou fração excedente, mais	0,2
b) Acima de 16.980 até 50.940	
Pelos primeiros 16.980	1,0
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais	0,2
c) Acima de 50.940 até 101,880	
Pelos primeiros 50.940	2,0
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais	0,2
d) Acima de 101.880 até 156.216	
Pelos primeiros 101.880	3,0
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais	0,2
e) Acima de 156.216	4,0

Assim, também quanto ao Fundo de Participação dos Municípios não houve deliberações periódicas fundadas nos Censos do IBGE, o que faz com que o seu critério de distribuição de recursos padeça do mesmo vício de inconstitucionalidade apontado pelo Supremo Tribunal Federal quando da declaração da inconstitucionalidade dos critérios de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados.

É certo que o Supremo Tribunal Federal não se posicionou em controle direto de constitucionalidade sobre a invalidade constitucional dos critérios de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, cuja invalidade constitucional é aferida, para efeito da construção do argumento formulado nesta peça processual, da *ratio decidendi* do julgamento proferido por aquele Tribunal Constitucional quando reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados. Mas, como cediço, o que vincula, ou quando menos orienta, o julgador quando tem em vista a aplicação do Direito com base em precedentes judiciais é a *ratio decidendi* do caso paradigma, e não o seu dispositivo[361-362], donde se

[361] Como leciona José Rogério Cruz e Tucci, o precedente é composto pelas "circunstâncias de fato que embasam a controvérsia" e pela tese ou princípio jurídico assentado na motivação (*ratio decidendi*) do provimento decisório (TUCCI, José Rogério Cruz e. *Precedente judicial como fonte do Direito*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 12), sendo que a submissão do intérprete ao precedente, "comumente referida pela expressão *stare decisis*, indica o dever jurídico de conformar-se às *rationes* dos precedentes (*stare rationibus decidendi*)" (TUCCI, José Rogério Cruz e. *Precedente judicial como fonte do Direito*, cit., p. 175-176). Conforme Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, essa *ratio decidendi* está nos fundamentos jurídicos que sustentam a decisão, e que, portanto, carregam a opção hermenêutica adotada no

infere que esse julgamento em que o Excelso Pretório declarou a inconstitucionalidade dos critérios de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados também afeta, para os efeitos pretendidos nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a eficácia do critério de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios.

Disso se infere que o legislador, quando vinculou a distribuição dos recursos financeiros provenientes da atividade de exploração de petróleo e gás aos Estados e Municípios não impactados pela exploração desses recursos naturais (Estados e Municípios não-produtores) à observância dos parâmetros aplicáveis aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, tomou por base critério de distribuição de recursos que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Tal circunstância torna ineficaz a opção político-legislativa consignada nos dispositivos legais impugnados.

Não se olvida que o Excelso Pretório, em juízo político, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos critérios de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados, permitindo, assim, a aplicação da Lei Complementar nº 62/1989 até 31 de dezembro de 2012. E que esse prazo foi estendido por mais 150 (cento e cinqüenta dias) pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Vice Presidente dessa Corte, então no exercício na Presidência. Mas, considerando que o Parlamento, até a presente

---

julgamento do caso paradigma (DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processo civil, v.* 2. Salvador: JusPODIVM, 2008. p. 350). E constitui-se, na precisa definição de Cruz e Tucci, como "a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto", ou como a regra de direito (*Rule of Law*) que vincula os julgamentos (TUCCI, José Rogério Cruz e. *Precedente judicial como fonte do Direito*, cit., p. 175). Destarte, a decisão do caso concreto apenas aproveita *ratio decidendi* do caso paradigma, não sendo afetada pelos fatos que conformaram o seu julgamento, ou por argumentos "expostos apenas de passagem na motivação da decisão, consubstanciando juízos acessórios, provisórios, secundários, impressões ou qualquer outro elemento que não tenha influência relevante e substancial para a decisão", os quais, como anotam Didier, Braga e Oliveira, caracterizam o *obter dictum* (DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processo civil, v.* 2, cit., p. 350). A distinção se faz importante, pois, se no que toca à coisa julgada as partes tornam-se vinculadas ao dispositivo da decisão, "quando se estuda a força vinculativa dos precedentes judiciais (enunciados da súmula da jurisprudência predominante de um tribunal, por exemplo), é preciso investigar os seus fundamentos, isto é, a sua *ratio decidendi*" (DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processo civil, v.* 2, cit., p. 351). Isso porque a vinculação cogitada repousa-se exclusivamente sobre os fundamentos da decisão paradigma, dos quais o intérprete extrai, por indução, a regra geral (*Rule of Law*) que pode ser aplicada a outras situações semelhantes (DIDIER JÚNIOR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. *Curso de direito processo civil, v.* 2, cit., p. 351).

[362] Sobre o assunto, ler também: MADUREIRA, Claudio Penedo. *Direito, processo e justiça: o processo como mediador adequado entre o direito e a justiça* (Dissertação de Mestrado). Vitória: UFES, 2009. Disponível na internet: <http://www.ccje.ufes.br/direito/posstrictosensumestrado/Links/dissertacaoclaudiomadureira.pdf>; acesso em 27 de novembro de 2012. p. 196-197.

data, não se desincumbiu da edição de nova lei complementar para disciplinar os critérios de distribuição de recursos aplicáveis ao Fundo de Participação dos Estados, e considerando, ainda, que as razões expostas nos julgamentos dantes referenciados também induzem a inconstitucionalidade dos critérios aplicáveis ao Fundo de Participação dos Municípios, impõe-se, também por esse motivo:

(a) a suspensão da execução do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012; e

(b) a atribuição à Lei nº 12.351/2010 interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios para a exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, como determina o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha os critérios de distribuição estabelecidos pela Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997.

Disso decorre a fumaça do bom direito.

3.2. Perigo da demora.

O perigo da demora reside no fato de a aplicação conjugada dos dispositivos legais impugnados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade representar interferência ilegítima na economia do Estado do Espírito Santo, na dos demais Estados produtores de petróleo e gás e na dos Municípios impactados pela exploração desses recursos naturais (Municípios produtores), com evidente repercussão sobre suas contas públicas e sobre a sua capacidade de atender a sociedade nas prestações que a Constituição lhes atribui, em especial no que se refere à disponibilização às suas respectivas populações de investimentos em educação, saúde, moradia, saneamento básico, infraestrutura, etc.

Para se ter uma idéia do impacto financeiro dessa nova sistemática de distribuição de *royalties* e participações, estima-se:

> **(a)** que o Estado do Espírito do Espírito Santo e os Municípios Capixabas produtores de petróleo deixariam de arrecadar até o ano de 2020 aproximadamente R$ 23.700.000.000,00 (vinte e três bilhões e setecentos milhões de reais) em *royalties* e participações especiais[363];
>
> **(b)** que o Estado do Rio de Janeiro e os Municípios Fluminenses produtores de petróleo deixariam de arrecadar, no mesmo período, aproximadamente R$ 75.400.000.000,00 (setenta e cinco bilhões e quatrocentos milhões de reais) em *royalties* e participações especiais[364].

[363] Números apurados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, e divulgados em seu *site* oficial (Disponível na internet: <http://www.sedes.es.gov.br/index.php/noticias/461-comite-em-defesa-do-es-estara-na-manifestacao-dos-royalties-no-rio-de-janeiro>; acesso em 28 de novembro de 2012).

[364] Números apurados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e divulgados pelo *site* "O Dia" (Disponível na internet: <http://odia.ig.com.br/portal/economia/estado-do-rio-pode-perder-r-75-4-bi-at%C3%A9-2020-1.558197>; acesso em 09 de março de 2013).

Essa perda financeira afeta a previsão orçamentária desses Estados e Municípios para investimentos nos próximos anos, de que tratam os seus respectivos planos plurianuais. Em especial, tornam-se ineficazes os orçamentos aprovados para a execução de políticas públicas neste ano de 2013, visto que as modificações legislativas introduzidas pela Lei nº 12.734/2012 na sistemática de distribuição de *royalties* e participações especiais aos Estados e Municípios tem aplicação imediata, o que impede que essas unidades federadas honrem as promessas que fizeram à sociedade, contidas em suas respectivas previsões de gastos.

Bem demonstra a gravidade dessa situação inusitada porque passam os Estados e Municípios produtores de petróleo e gás o anúncio pelo Governador Sérgio Cabral de que o Estado Rio de Janeiro está suspendendo todos os seus pagamentos; como retrata esta reportagem publicada na rede mundial de computadores pela Central Globo de Jornalismo:

> "**Cabral suspende todos os pagamentos do governo do estado**
>
> O Rio já sofre com a perda dos royalties do petróleo: nesta quinta-feira, **o governador Sérgio Cabral (PMDB) determinou a suspensão de todos os pagamentos do estado**, mantendo em dia apenas salários de servidores e transferências a municípios. A decisão do governador ocorre no dia seguinte à derrubada, pelo Congresso, dos vetos da presidente Dilma Rousseff à lei que fixou novas regras de distribuição dos recursos do petróleo, inclusive para campos já licitados. **Os cortes**, que pegaram de surpresa até secretários de governo, **serão indiscriminados e atingirão da mesma forma o pagamento de merenda e material hospitalar, investimentos, viagens e mobiliário, por exemplo**. Apenas ontem deixaram de ser pagos R$ 82 milhões, de um total de R$ 470 milhões previstos para este mês – valor que não incorpora a folha de ativos e inativos (R$ 1,7 bilhão) e as transferências para municípios (R$ 922 milhões), a serem executados normalmente.
>
> [...]
>
> Conforme comunicado do órgão, **trata-se de uma medida preventiva, "em função da grave ameaça à solvência do Estado decorrente da decisão de ontem (quarta-feira) do Congresso Nacional"**. "Tal providência se impõe em face da possibilidade de redução significativa das receitas de royalties já no próximo dia 12. Os pagamentos estão suspensos até que se tenha clareza do fluxo de recursos com que o Estado poderá efetivamente contar para honrar seus compromissos", conclui a nota [...]"[365].

No Espírito Santo não chegaremos, por enquanto, a esse estremo; porque, dado o caráter recente de nossa produção petrolífera, ainda somos menos dependentes de receitas com *royalties* e participações especiais do que o Rio de Janeiro; e também porque nos preparamos financeiramente para suportar por alguns meses uma

[365] Disponível na internet: <http://oglobo.globo.com/economia/cabral-suspende-todos-os-pagamentos-do-governo-do-estado-7769763>; acesso em 09 de março de 2013.

possível queda nessa receita pública. Mas certamente não conseguiremos executar o nosso orçamento de 2013, e por isso já estamos revendo nosso cronograma de investimento com recursos próprios, com graves prejuízos para o atendimento de necessidades básicas da população capixaba.

De todo modo, é muito provável que os Municípios produtores de petróleo situados nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo adotem medidas semelhantes àquelas anunciadas pelo Governador Sérgio Cabral. Em primeiro lugar porque esses Municípios são, como regra, muito dependentes de recursos provenientes de *royalties* e participações especiais. Em segundo lugar porque, dada a redução do montante de *royalties* e participações especiais destinados aos Estados produtores, esses Municípios terão maiores dificuldades em obter auxílio financeiro de seus respectivos Estados para arcar com as despesas extraordinárias dos impactos decorrentes da exploração petrolífera.

Aliás, essa última circunstância (a redução da capacidade de financiamento dos Estados produtores) tende a afetar, ainda, a capacidade que tem os Municípios capixabas e fluminenses de arcar com as prestações básicas de suas respectivas populações (com saúde, educação, moradia, infraestrutura, saneamento básico, etc.), que muitas vezes são executadas com o reforço de recursos estaduais. Quanto ao particular, não serão afetados apenas os Municípios produtores de petróleo e gás, mas todos os Municípios situados nos Estados impactados.

Disso se verifica que a perda financeira decorrente da modificação dos critérios para a distribuição de *royalties* e participações especiais afetará de forma muito incisiva as finanças públicas dos Estados e Municípios produtores. E que também poderá afetar, residualmente, Municípios não produtores situados nos Estados produtores.

Mas esse não é o único problema causado pela imediata aplicação das novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional para a distribuição de *royalties* e participações especiais.

O que se dá é que essa perda financeira, além de repercutir negativamente sobre as finanças públicas dos Estados e Municípios prejudicados, afeta, pelas razões dantes expostas, o modo de vida das suas respectivas populações.

E tal se dá porque, como demonstrado:

(a) as participações governamentais advindas da exploração dos recursos naturais, entre eles o petróleo e o gás natural (CRFB, art. 20, p. 1º), na opinião dos constituintes e na interpretação que lhe é correntemente atribuída pela doutrina jurídica e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade compensar (ou indenizar) os Estados e Municípios impactados pelos reflexos dessa atividade econômica, qualificando-se, assim, como contraprestação pelos riscos e custos inerentes ao seu exercício por particulares, mas sempre sob autorização e em benefício da União Federal;

(b) a instalação/ampliação da indústria petrolífera enseja para o poder público, entre outras despesas, o aumento no gasto com infraestrutura, por exemplo, em razão da necessidade de construção e manutenção de estradas, de incremento das estruturas urbanas, da construção de novas escolas, de mais unidades de saúde, e também de moradias populares para abrigar as populações locais, que correm sério risco de serem marginalizadas pela elevação do custo de vida proporcionada pelo incremento da produção petrolífera em sua região;

(c) essas despesas adicionais devem ser custeadas com as receitas advindas do recebimento de *royalties* e participações especiais, pois, do contrário, ter-se-ia a quebra de sua autonomia financeira, com reflexos sobre o princípio federativo, vez que, nessa hipótese, os Estados e Municípios impactados seriam obrigados a utilizar-se de suas receitas ordinárias (destinadas ao custeio das necessidades básicas de suas respectivas populações,

com saúde, educação, segurança, moradia, infraestrutura, saneamento básico, etc.) para a cobertura dessas despesas extraordinárias provocadas pela exploração petrolífera.

No entanto, a aplicação conjugada dos dispositivos legais impugnados fará com que parte considerável desses recursos seja retirada dos Estados e Municípios produtores. Por isso, a distribuição das participações governamentais advindas da exploração de petróleo e gás em maior proporção a unidades federadas que não são impactadas pela exploração desse recurso natural, além de ser inconstitucional, pelas razões dantes explicitadas, tem a potencialidade de prejudicar, de forma direta e imediata, as populações dos Estados e Municípios afetados por essa atividade econômica.

Assim, a modificação dos critérios de distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios impõe aos Estados e Municípios produtores relevante perda financeira, afetando, com isso, a realização de serviços públicos básicos, restando evidente, na hipótese, a excepcional urgência para a concessão da medida cautelar, de que trata o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.869/1999, que caracteriza o perigo da demora.

3.3. Conformação do pedido cautelar.

Posto isso, impõe-se, na espécie, a concessão de medida cautelar neste processo, "sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado", para efeito de:

(a) suspender a eficácia do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D

e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão das alegadas violação à regra jurídica consignada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e ofensa ao princípio da isonomia, ao princípio federativo e ao princípio da segurança jurídica;

(b) nessa hipótese, atribuir à Lei nº 12.351/2010 interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios pela exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, como determina o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha de produção os critérios de distribuição estabelecidos pela Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997;

(c) subsidiariamente, caso não possam ser acolhidos os pedidos anteriores, o que apenas se admite por argumentar, suspender a eficácia do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C, bem como do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão da alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica.

4. Requerimentos.

Por todo o exposto, visando resguardar a Constituição da República, a qual todos os órgãos do Estado Brasileiro devem obediência, REQUER-SE:

a) liminarmente, a concessão da medida cautelar:

a.1) determinando-se a suspensão da eficácia do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão das alegadas violação à regra jurídica consignada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e ofensa ao princípio da isonomia, ao princípio federativo e ao princípio da segurança jurídica;

a.2) nessa hipótese, também com vistas a atribuir à Lei nº 12.351/2010 interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios pela exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, como determina o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha de produção os critérios de distribuição estabelecidos pelas Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997;

a.3) subsidiariamente, no caso da rejeição dos pedidos anteriores, para suspender a eficácia do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C, bem como do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão da alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica;

b) que sejam solicitadas as informações pertinentes ao Congresso Nacional, e que seja ouvido o Advogado Geral da União e a Procuradoria Geral da República;

c) que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a medida cautelar deferida:

c.1) para efeito de declarar a inconstitucionalidade do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C e do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, bem como do artigo 48 e parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 49 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do artigo 49-A e parágrafo único, do artigo 49-B e parágrafo único, do artigo 49-C e parágrafo único, dos parágrafos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 50, do artigo 50-A e parágrafo único, do artigo 50-B e parágrafo único, do artigo 50-C e parágrafo único, do artigo 50-D e parágrafo único, do artigo 50-E e parágrafo único, do artigo 50-F e parágrafo único da Lei nº 9.478/1997, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão das alegadas violação à regra jurídica consignada no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição e ofensa ao princípio ao princípio da isonomia, ao princípio federativo e ao princípio da segurança jurídica;

c.2) acolhido esse primeiro pedido, também com vistas a atribuir à Lei nº 12.351/2010 interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que enquanto não for editada norma válida a disciplinar a distribuição de *royalties* e participações especiais a Estados e Municípios pela exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção, como determina o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha de produção os critérios de distribuição estabelecidos pela Leis nº 7.990/1989 e 9.478/1997;

c.3) subsidiariamente, no caso da rejeição dos pedidos anteriores, para suspender a eficácia do artigo 42-B e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 42-C, bem como do inciso IV e do parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei nº 12.351/2010, todos com redação conferida pela Lei nº 12.734/2012, em razão da alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica;

Dá-se á presente causa o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)[366].

Termos em que, pede-se e espera deferimento.

Vitória/ES, ___ de março de 2013.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
Procurador Geral do Estado
OAB/ES nº 7.513

ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS
Procurador-Chefe da Procuradoria do Estado na Capital Federal
OAB/ES nº 4.150

GUSTAVO CALMON HOLLIDAY
Procurador-Chefe da Procuradoria de Petróleo, Mineração e outros Recursos Naturais – PPETRO
OAB/ES nº 7.526

ANDERSON SANT'ANA PEDRA
Procurador-Chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas – CEI
OAB/ES nº 9.712

CLAUDIO PENEDO MADUREIRA
Procurador do Estado
OAB/ES nº 11.377

[366] Valor correspondente ao prejuízo a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo e pelos Municípios Capixabas nos próximos doze meses, como decorrência da modificação dos critérios para a distribuição de *royalties* e participações especiais relativos à exploração de petróleo e gás, conforme estimativa divulgada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.